Supremo Tribunal Federal

ADC 51

AUDIÊNCIA PÚBLICA

SOBRE CONTROLE DE DADOS DE USUÁRIOS

POR PROVEDORES DE INTERNET NO EXTERIOR

RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES

10/02/2020

PRIMEIRA PARTE - MANHÃ

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Bom dia a todos!

Como já foi ressaltado, e todos estão informados, a ADC 51 discute a constitucionalidade da utilização de Acordos de Assistência Legal Mútua MLAT, para o compartilhamento de dados controlados por provedores de acesso a *internet* sediados no exterior.

O debate travado nessa ação tem, como pano de fundo, o crescimento e dependência da obtenção desses dados como elemento de evidência na persecução criminal.

A territorialidade dos dados representa importante desafio à efetividade da aplicação da lei, em perspectiva transnacional, que tem dado ensejo a batalhas judiciais entre provedores de acesso à *internet* e o Poder Judiciário nacional. De um lado, a competência da jurisdição brasileira para compelir unilateralmente empresas estrangeiras a divulgarem dados armazenados tem sido colocada em dúvida. Por outro, o Estado alega que os Acordos de Assistência Mútua MLAT tem-se revelado mecanismo moroso e pouco eficaz para a obtenção de evidências.

Portanto, a audiência pública busca esclarecer e informar a Corte sobre essas questões técnicas e fáticas de alta complexidade, de modo a diminuir a assimetria informacional existente quando Tribunais são chamados a decidir sobre importantes demandas que surgem no núcleo da sociedade, da economia e do Estado.

Busca-se, ainda, dar oportunidade de manifestação direta a todos os envolvidos e interessados, com base em critérios previamente estabelecidos de representatividade, especialização técnica, diversidade de gênero, expertise e pluralidade de opiniões, com paridade de pontos de vista a serem defendidos. Trata-se, portanto, de instrumento de democratização da jurisdição constitucional e de aperfeiçoamento das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal.

De acordo com a programação, teremos manifestação de 36 diferentes expositores, que trazem a esta sessão visão dos mais variados órgãos e componentes do Estado, setor privado, Academia e sociedade civil sobre o assunto.

Considerando o significativo número de expositores, a brevidade do tempo e a paridade a serem observados em relação à participação de cada um dos inscritos, é importante reforçar a necessidade de observância ao tempo conferido a cada um dos senhores, que será rigorosamente

fiscalizado para garantir o cumprimento do cronograma e bom andamento dos trabalhos.

Por fim, ressalto que a realização de intervenções ou esclarecimento de dúvidas somente serão permitidos por intermédio da Presidência desta audiência, no tempo estabelecido na programação, ao final de cada bloco ou período de exposições, sendo destinado exclusivamente a questões de interesse do processo e do Tribunal a serem definidas pelo Relator.

Solicito a todos que observem essas e as demais regras previamente estabelecidas de modo que possamos ter um dia de trabalho profícuo.

Com essas palavras, declaro aberta a Audiência Pública e desejo um bom-dia e um bom trabalho a todos.

Passamos agora a ouvir o primeiro representante da Cespro Nacional, Professor e Ministro Ayres Britto, que terá prazo de dez minutos.

DOUTOR CARLOS AYRES BRITTO (PRESIDENTE DA ASSESPRO NACIONAL) – Bom dia a todos.

Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, que bom o cumprimentá-lo, Vossa Excelência que foi mentor da lei na parte que dispôs sobre a possibilidade de convocação de audiências públicas no âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal.

Doutora Luísa, meus cumprimentos, todos os membros da Mesa, senhores advogados, juristas, jornalistas, enfim, todos os que se encontram aqui.

Conforme antecipou o Ministro Gilmar Mendes na sua fala introdutória, cuida-se de ação direta de constitucionalidade, ADC, proposta pela Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação - ASSESPRO. Em síntese, o que se busca na ação é assentar a constitucionalidade de normas de cooperação jurídico-internacional entre autoridades judiciárias brasileiras e estrangeiras, mais de perto, entre autoridades brasileiras e autoridades norte-americanas judiciárias.

O pedido central é o reconhecimento da constitucionalidade do ato normativo, também já anunciado pelo Ministro Gilmar, em que se traduz o MLAT, um acordo bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil em matéria de Direito Penal, de execução do Direito Penal e Processual Penal, mas na perspectiva do MLAT mesmo como um devido processo legal, um devido processo legal instituído à luz da Constituição brasileira e da Constituição norte-americana, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista material, e que nunca teve, jamais teve a sua inconstitucionalidade reconhecida, proclamada, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Complementarmente, o que se pede, ainda por via diplomática, é a aplicabilidade das cartas rogatórias

pertinentes, de previsibilidade, cartas rogatórias tanto no Código de Processo Civil brasileiro quanto no Código de Processo Penal.

Como o tempo é muito curto, o que me cabe dizer é que o MLAT, que é o documento central em torno do qual vamos desenvolver nossas exposições, é um mecanismo de colaboração, de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, ali já previsto no art. 4º da Constituição brasileira, às expressas, uma espécie de solução pacífica das controvérsias por antecipação, também princípio expresso no art. 4º da Constituição brasileira.

Em verdade, eu chego a ver o MLAT como uma espécie de apogeu, de ápice, desse movimento planetário do antropocentrismo para o datacentrismo. Estamos falando aqui sobre dados, comunicação de dados - dados armazenados, dados coletados, dados sob tratamento, por uma empresa norte-americana, que é controladora, que é sócia majoritária do Facebook do Brasil, mas o Facebook do Brasil, atuando num plano de funcionalidade muito restrita para os usuários, apenas servindo-se da plataforma, agora, sim, explorada pelo Facebook Inc. para fazer anúncios comerciais, propaganda, *marketing*, divulgação de produtos e serviços.

E o que defendemos na nossa petição inicial é que esse devido processo legal substantivo, em que consiste o MLAT, é também de previsibilidade constitucional brasileira, pelo menos no § 2º do art. 5º cuja

dicção é conhecida de todos: "Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime" - que deve ser o democrático - "e dos princípios" - notadamente, no caso, os princípios do Título II da Constituição, Dos Direitos e Garantias Fundamentais , "dos princípios" - assim literalmente grafados no plural pelo art. 4º da mesma Constituição brasileira.

E esse § 2º diz, portanto, "os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios" - e vem o que interessa - "... ou dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte."

Então, o fundamento de validade do MLAT, em última análise, é a Constituição brasileira. E o que se tem dito contra o MLAT e, até por extensão, as cartas rogatórias é que são documentos atentatórios da soberania nacional.

Ora, eu devo dizer: é no exercício da soberania nacional que se assina um tratado, um acordo, ou bilateral ou multilateral. É exatamente no exercício da soberania nacional. E quanto às cartas rogatórias, são veiculadas por lei de um Estado soberano de nome República Federativa do Brasil.

Por último, eu me permito, já fiz a distinção de que a coleta, o armazenamento, o tratamento, o processamento eletrônico de dados, tudo se faz, em rigor, fora do Brasil e não dentro do Brasil.

E eu me permito dizer, com todo respeito também, não vi ninguém citar o art. 181 da Constituição, nunca vi em nenhuma decisão, nem do STJ, nenhuma decisão, e que me parece fundamental para a discussão, pelo menos o encaminhamento da discussão do tema. É o art. 181 da Constituição, sobre as relações comerciais, sobre relações protagonizadas por empresas no âmbito da livre iniciativa, portanto.

O art. 181 faz parte do Título VII da Constituição, versante, como sabemos, sobre a Ordem Econômica e Financeira. E no âmbito, na esfera, no círculo dos princípios gerais da atividade econômica o que diz no artigo 181?

"O atendimento de requisição de documento" - o atendimento de requisição de documento - "ou informação de natureza comercial" - que é o caso -, "feita por autoridade administrativa ou judiciária" - feita por autoridade administrativa ou judiciária - "estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País" - ou seja empresa brasileira recebendo da administração estrangeira ou da jurisdição estrangeira uma requisição de documento ou um pedido de informação, o que diz a

Constituição? Que esse tipo de requisição de documento ou pedido de informação "dependerá de autorização do Poder competente", no nosso caso, do Ministro da Justiça, ou seja, dependerá da via diplomática. É de se fazer por via diplomática, art. 181 da Constituição brasileira. Pré-exclui essa alegação de ofensa à soberania nacional, pré-exclui a via direta entre a autoridade judiciária ou autoridade administrativa a essa ou àquela empresa. Às expressas, a Constituição também, por mais um título, chancela esse tipo de solução pacífica das controvérsias via diplomática.

Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Passo, agora, a palavra ao Professor Francisco Rezek. Disporá também de 10 minutos.

O SENHOR FRANCISCO REZEK (ASSESPRO NACIONAL) - Ministro-Presidente, Excelências, Senhoras e Senhores.

O só fato de estarmos, aqui, convocados por Vossa Excelência - e esse fato associado aos termos lapidares da convocatória -, isso faz ver como superado todo o debate prévio que se estabeleceu em torno de preliminares. Tudo aquilo que os opositores dessa ação declaratória levantaram a respeito da legitimidade dos proponentes, a respeito da

propriedade do objeto e, sobretudo, Presidente, a respeito do nível constitucional ou não deste debate.

Alguns aqui pretenderam que isso é matéria ordinária e não deveria ser alçada a esta Corte, muito menos, creio, dar-lhe o trabalho de uma audiência pública; isso deveria resolver-se nas instâncias ordinárias, como tem sido resolvido erraticamente e culminar, na melhor das hipóteses, no Superior Tribunal de Justiça. Não! Não é nada disso!

Estamos aqui convocados pelo Ministro-Relator para uma audiência pública cuja só realização extirpa, tira da mesa esse debate, hoje, totalmente desnecessário.

Sim, é uma ação declaratória de constitucionalidade singularíssima, quase surreal. A parte proponente pede ao Supremo Tribunal Federal que declare a constitucionalidade de coisas cuja constitucionalidade ninguém jamais discutiu, nem poderia tê-lo feito.

O que há de inconstitucional no Tratado Bilateral Brasil-Estados Unidos, celebrado em 97, promulgado em 2001, depois da aprovação do Congresso Nacional? O que há de inconstitucional nele? Nada! O que há de inconstitucional nas velhas regras dos códigos de processos relacionadas à mecânica das cartas rogatórias? Nada, nada!

Qual é o discurso, então, daqueles que acham que a ação declaratória deveria ser julgada improcedente? Para quê? Para que fins?

Na realidade, aquilo que está se passando não é uma declaração formal de inconstitucionalidade desses textos e, sim, um contorno habilidoso dessas normas. Vamos passar ao largo delas, vamos fingir que elas não existem e adotar mecanismos extravagantes de coação em benefício do bom e rápido andamento do processo, da mais fácil e mais rápida obtenção da prova, da maior expediência das coisas, como se, no geral, o foro brasileiro fosse um modelo de expediência.

Por conta disso, decretam-se constrições severas. Chega-se, às vezes, à decretação da prisão de dirigentes da empresa brasileira afiliada à empresa internacional detentora dos dados. E se faz isso em nome desse interesse na celeridade do processo penal, mas com uma total e comovente abstração do conjunto da ordem jurídica. O que estão fazendo determinados ativistas, togados ou não, é mais ou menos aquilo que faria um juiz no foro criminal se, vendo o seu réu evadir-se para o exterior, fingisse que não existem mecanismos para ele se dirigir ao Ministro da Justiça e desencadear o processo de pedido de extradição e preferisse fustigar, prender, quem sabe, familiares do trânsfuga, a fim de forçar o seu retorno espontâneo. A equação é exatamente a mesma.

No que se apoiam, afinal? Qual é a norma jurídica em que se apoiam para esse tipo de atitude? É o art. 11 da lei que significa o Marco Civil da Internet e que diz apenas algo não menos óbvio: em tais e tais circunstâncias envolventes do Brasil, de brasileiros, de coisas aqui acontecidas, a legislação brasileira é aplicável. Claro que é aplicável, Senhor Presidente! Ninguém nega que a legislação brasileira é aplicável. Mas isso não significa que os mecanismos de ação executiva, efetiva do Brasil possam se estender além de nossas fronteiras e desafiar um território alheio não menos soberano. É isso que acontece tantas vezes no foro contemporâneo. Os entusiastas do discurso da soberania se esquecem olimpicamente de que nós não estamos sozinhos no planeta e de que, ao lado dessa soberania, existem outras 192 unidades não menos soberanas e de que há coisas que não podem ser decididas isoladamente por esse ou aquele Estado, têm de ser trabalhadas em comum.

Senhor Presidente, o que desejam realmente os objetantes da ação declaratória? Certamente não é ver o Tribunal declarar a inconstitucionalidade do Tratado ou das normas processuais; o que desejam é convalidar o comportamento de alguns juízes que fustigam a empresa brasileira, afiliada à empresa norte-americana, como se acreditassem realmente que a empresa brasileira detém esses dados e não os fornece por má vontade, por obstinação, quando isso é evidentemente falso. Não há, aí, nada parecido

com uma insubordinação voluntária ou caprichosa. Os dados não estão aqui. Os dados não são disponíveis para nós.

O que parecem ignorar é que a matriz à qual a empresa brasileira é afiliada, a detentora do cofre dos dados, que fica em território americano, não se submete nem mesmo a esse tipo - eu quero evitar a palavra chantagem, Senhor Presidente, mas a filosofia da coisa é mais ou menos a mesma - de constrição a que se submete uma empresa brasileira na esperança de que isso comova a sua associada norte-americana e ela forneça espontaneamente os dados desejados no interesse do processo penal.

Mas, Presidente, ainda que eu quisesse, ela não poderia fazê-lo. E não poderia fazê-lo porque a legislação norte-americana é idêntica à nossa, inspirada no art. 181 da Constituição, que o Ministro Carlos Britto acaba de citar. Lá, eles fazem exatamente a mesma coisa que nós fazemos, há um paralelismo absoluto. O que, na realidade, querem, Senhor Presidente, não é isso. Se lhes fosse exigido que dissessem exatamente o que esperam do desfecho dessa ação direta, talvez confessassem, com base em um conceito rupestre de soberania e em uma interpretação delirante do art. 11 do Marco Civil da Internet, que querem que seja impossível que qualquer empresa, instituição, complexo empresarial funcione, trabalhe no Brasil sem que todo o

seu acervo, material e incorpóreo, esteja ao alcance direto e imediato da mão forte da autoridade brasileira.

Tem jeito? Claro que tem! Isso exige uma revolução na ordem jurídica a partir da Carta Magna. E existem modelos - a Coreia do Norte é o mais notório dos modelos. É isso o que queremos? Bom, se for, o Congresso Nacional traduzirá a nossa voz na hora oportuna, manipulando a Constituição e a legislação ordinária com consequências apocalípticas. Mas é possível fazer isso e nos transformar num gigantesco campo de concentração em matéria de informática, quando o próprio inciso I do art. 2º da Lei do Marco Civil da Internet esclarece que é preciso honrar a ideia da necessidade do reconhecimento da escala mundial da rede, para não falar no parágrafo único do art. 3º, que diz da necessidade de se honrarem os tratados internacionais que vinculam a República.

Senhor Presidente, terminando, acham que o Congresso Nacional, tomado, quem sabe, um dia, por uma psicose coletiva, vai querer fazer isso? É claro que não acham. E se isso não acontecer, não há outro caminho para nos encapsular do mundo em matéria de informática. Isso, com todas as vênias, não é tarefa para o Poder Executivo, tampouco para magistrados, sentados ou de pé, não é para a magistratura, por maior que seja a nossa homenagem reverente a essas instituições e por mais que

reconheçamos que os seus objetivos são nobres, que suas ideias são boas, que os seus propósitos são bons. Mas, Senhor Presidente, como este Tribunal não ignora - e uma boa parte dos brasileiros parece ignorar nos últimos quinze ou vinte anos -, os fins não justificam os meios.

Senhor Presidente, eu terminei e agradeço a paciência de todos.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Agora ouviremos o Professor Todd Hinnen.

PROFESSOR TODD HINNEN (ASSESPRO NACIONAL)* transcrição feita com base em tradução simultânea - Bom dia. Agradeço a oportunidade de apresentar este depoimento. É um prazer falar a esta Corte. Por mais de duas décadas, trabalhei como advogado, palestrante, promotor e especialista temático em matérias relacionadas a democracia, tecnologia e justiça. Por dois anos, como chefe da delegação americana junto a um grupo de especialistas em crime cibernético da Organização dos Estados Americanos, tive o prazer de trabalhar com meus homólogos brasileiros do Governo brasileiro.

O tema da presente audiência, que é a cooperação entre autoridades de investigação criminal entre dois governos, é, portanto, de particular interesse e importância para mim. Embora o tema envolva o MLAT

Brasil-Estados Unidos, os princípios em questão relativos à governança da internet, soberania e assistência jurídica internacional e ao Estado de Direito têm ramificações mais amplas, que serão sentidas em todo mundo.

Uma lei americana chamada SCA rege a divulgação, por um provedor de serviços baseado nos Estados Unidos, de metadados relativos a comunicações e seus conteúdos. O SCA permite que um provedor divulgue metadados, a saber, coisas como nome de um cliente, seu endereço, número de telefone, método de pagamento e endereços de IP e *login* a qualquer pessoa que não entidade governamental americana, incluída aqui uma entidade de governo estrangeiro, como os órgãos de investigação criminal brasileiros. Tais informações podem ser de imenso valor numa investigação criminal. Como promotor de crimes cibernéticos, com frequência usava tais metadados para identificar suspeitos ou comparsas de um crime, para localizar computadores e dispositivos para busca e apreensão.

Em contraste às amplas permissões relativas a metadados, o SCA, de um modo geral proíbe que os provedores baseados nos Estados Unidos divulguem o conteúdo de comunicações dos usuários. O SCA afirma que, na ausência de uma exceção expressa, os provedores de serviços não poderão divulgar o conteúdo de comunicação eletrônica a qualquer outra pessoa ou entidade. Quando o Congresso americano promulgou a lei SCA,

entendia que a parte mais sensível e privada de uma comunicação era justamente essa e, portanto, a parte que merecia a proteção mais rigorosa, a saber, o conteúdo da comunicação.

A lei americana define o conteúdo de comunicação como uma parte da comunicação que transmite o significado, o teor, a substância, o propósito. Por exemplo, o conteúdo inclui mensagem de texto, postagem em um *site* de rede social como o Facebook, foto, ou corpo ou linha de assunto de um e-mail. Justamente porque o conteúdo é a parte mais sensível, o SCA proíbe que um provedor americano o divulgue a qualquer pessoa, a menos que determinadas exceções muito estreitas e limitadas se apliquem. E, como o professor Gidari explicará em seu depoimento mais tarde, a menos que uma divulgação de conteúdo se encaixe incontroversamente nessas estreitas exceções, a divulgação poderá representar risco significativo de responsabilidade legal ao provedor.

Como as exceções representam apenas a possibilidade de divulgação em coerência com a legislação americana, serei muito breve aqui. Essas exceções estão contidas na Seção 2702, "b", do Código Penal americano.

A primeira exceção permite a divulgação em resposta a um mandado de busca obtido por uma corte americana. Não inclui exceção

semelhante para divulgação a um governo ou autoridade estrangeira. Tal dispositivo poderia violar a lei americana.

Até 2018, quando o congresso americano aprovou a lei CLOUD, o único meio pelo qual uma entidade governamental não americana - como as autoridades brasileiras de investigação penal - podia obrigar, de forma coerente com a lei americana, um provedor baseado nos Estados Unidos a divulgar conteúdo era justamente quando se trabalhava com autoridades americanas para se obter um mandado de busca, independentemente dos métodos de investigação.

Para assegurar que a cooperação jurídica fosse efetiva, os Estados Unidos e Brasil assinaram, aqui em Brasília, o MLAT, o tratado de assistência jurídica mútua, em 14 de outubro de 1997, que é o tema da presente audiência.

Discutirei a seguir as exceções em potencial.

Um provedor poderá divulgar o conteúdo com o consentimento de uma parte da comunicação. Para proteger plenamente, o consentimento deve ser específico, plenamente informado e não ambíguo, ou seja, o provedor deve notificar o cliente de que a aplicação da lei ou a investigação criminal busca a divulgação do conteúdo; e o cliente deve concordar com tal divulgação. Raramente ocorre o caso de um consentimento

pelo cliente, porque, se for o caso, o cliente certamente saberá que é o alvo de uma investigação. De igual modo, o sujeito alvo da investigação raramente concordará que tais comunicações sejam divulgadas às autoridades. Do ponto de vista prático, portando, a exceção de conteúdo ou a cessão de consentimento raramente se aplica.

Um provedor poderá divulgar o conteúdo quando necessário para proteger os seus próprios direitos ou bens ou proteger o serviço. Essa estreita exceção permite que um provedor que tenha descoberto fraude ou abuso de seu serviço possa divulgar o conteúdo na medida necessária para protegê-lo contra fraude e abuso.

O SCA também permite que um provedor informe aparentes casos de violação de leis americanas que proíbem a pornografia infantil ou a exploração de crianças ao Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas.

Outra exceção permite a divulgação de conteúdo quando o provedor tem uma crença em boa-fé de que tal divulgação é necessária para responder a uma emergência que envolva risco iminente de morte ou lesão grave. Os provedores, inclusive o Facebook, com frequência, fazem divulgação de conteúdos com base nessas duas exceções para a proteção a crianças e a outros de qualquer dano.

Outra exceção ainda permite que os provedores divulguem comunicações que tenham descoberto inadvertidamente relativas ao cometimento de um crime. Essa exceção não permite que um provedor, intencionalmente, busque e divulgue tais comunicações.

A última exceção permite que um provedor divulgue o conteúdo em resposta a uma ordem judicial ou de um governo estrangeiro que tenha celebrado um acordo no âmbito do CLOUD Act com os Estados Unidos. Se o governo brasileiro vier a celebrar tal acordo com os Estados Unidos, a legislação americana não mais proibirá que provedores baseados nos Estados Unidos divulguem conteúdo diretamente às autoridades de investigação criminal brasileiras em resposta a ordens brasileiras. Essa exceção só está disponível desde 2018.

Fora dos limites estreitos dessas exceções, um provedor poderá divulgar conteúdo unicamente em resposta a um mandado de busca americano. É por isso que o MLAT desempenha papel tão crucial na obtenção lícita de conteúdo de provedores baseados nos Estados Unidos.

O MLAT propicia um meio coerente com o SCA para que as autoridades de investigação penal brasileira obtenham o conteúdo de provedores americanos.

O art. 5° do Tratado exige que o governo americano faça tudo que lhe seja possível para prontamente executar ou responder a uma requisição do governo brasileiro e, assim, manter o governo brasileiro devidamente informado durante a pendência de tal requisição.

O então Presidente Clinton descreveu o Tratado como ferramenta eficaz para auxiliar na persecução penal de uma ampla gama de crimes modernos, inclusive terrorismo e outros crimes violentos, tais como: tráfico de entorpecentes e também lavagem de dinheiro.

Os dois governos contemplaram que o Tratado viria a desempenhar um papel importante na facilitação das investigações, ao mesmo tempo em que se respeitasse a soberania dos dois países e seu compromisso para com o Estado de Direito. Ambos os governos continuam a endossar a assistência internacional como meio de sustentar tais valores e facilitar as investigações.

O governo americano confirmou no CLOUD Act que, na ausência de um mandado obtido por meio de tal assistência ou de um acordo no âmbito do CLOUD Act, a lei americana proíbe que os provedores divulguem conteúdo a governos estrangeiros.

O governo do Brasil ratificou a Convenção Interamericana sobre Assistência jurídica legal, em 2007, solicitou uma exceção e foi convidado

a aderir à Convenção de Budapeste sobre crimes cibernéticos, em dezembro de 2019.

E, semana passada, publicou um decreto que aprova a estratégia nacional sobre crime cibernético, que endossa a cooperação internacional e a assistência jurídica mútua.

O MLAT é atualmente o veículo mais eficaz e eficiente para a assistência jurídica mútua entre o Brasil e os Estados Unidos. Em consonância com o apoio contínuo dos dois governos em prol da assistência internacional, tal Tratado deve ser endossado e sustentado.

O SCA não é a única lei americana que proíbe divulgação a outras jurisdições. Muitos países têm leis análogas com frequência denominadas estatutos de bloqueio ou impeditivos. E, também, leis de proteção de dados podem ter o mesmo efeito.

O conflito em potencial entre a legislação brasileira e a americana não é o único conflito potencial de leis envolvido aqui. Na internet global, a cooperação internacional continua a ser, conforme foi há décadas, a melhor esperança para superarmos essas questões e para se encontrar um equilíbrio entre os valores envolvidos e a soberania das partes em questão, ao mesmo tempo em que se corroboram as investigações penais efetivamente.

O mundo observa hoje a medida com que esta respeitável Corte considera esses temas. Suas decisões guiarão outros e reverberarão em departamento executivos, assembleias legislativas e tribunais mundo afora.

Espero que os senhores sustentem o MLAT e, em o fazendo, sugiram que a trajetória à frente resida no fortalecimento do arcabouço jurídico internacional, e não no aprofundamento de conflitos de legislação que ameaçam fraturar a internet e frustrar a cooperação internacional.

Agradeço a oportunidade.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Agora, com a palavra, o Doutor Eric Holder Júnior.

O SENHOR ERIC HIMPTON HOLDER JÚNIOR* (transcrição feita com base em tradução simultânea) - Bom-dia. Agradeço a oportunidade de expor aqui, hoje. Meu nome é Eric Holder, atualmente sócio no escritório de advocacia *Covington & Burling*, em Washington.

Como parte da minha prática, assessoro clientes em temas complexos de litígio internacional.

Comecei a trabalhar como promotor logo após a faculdade e servi como juiz por cinco anos. Também atuei como Procurador Federal chefe, no Distrito da Columbia por quatro anos, e era a segunda pessoa no comando no Ministério da Justiça americano entre 1997 e 2001, no Governo

Clinton. De 2009 a 2015, tive a honra de servir como Ministro da Justiça dos Estados Unidos da América.

Nesse papel, tive também o prazer de conviver com meus colegas promotores brasileiros, no Rio de Janeiro, em 2010, ocasião em que nos reunimos para tratar de alguns desafios conjuntos que ambos os países enfrentavam na área de direitos de propriedade intelectual.

À época e, também, agora, permaneço profundamente impressionado pelo comprometimento da comunidade de investigação penal dos dois países, no sentido de superar questões transfronteiriças desafiadoras, nessa busca comum da justiça, bem como nosso desejo compartilhado pelo Estado de Direito.

Entendo muito bem a atenção da Corte a esse importante tema. Estou aqui hoje, perante esta Corte, meritíssimo, porque entendo que a questão que se lhes apresenta é de vital importância. Não só para questões jurídicas ou de legislação entre Brasil e Estados Unidos, mas também no que se refere à capacidade de as nações soberanas continuarem podendo buscar e receber assistência em matéria de aplicação da lei e investigação penal entre si, e no que se refere ao futuro da internet, dado seu caráter internacional e impacto sobre os negócios em escala global.

Nos Estados Unidos, provedores de serviços eletrônicos de comunicações como Facebook estão sujeitos à Lei SCA, que os proíbe de divulgar conteúdo de usuários, a não ser que oito exceções enumeradas se apliquem. Essas exceções não permitem que os provedores americanos divulguem conteúdo de usuários, mesmo sequer o conteúdo de pessoas não americanas, diretamente a entidades governamentais estrangeiras.

Intuitivamente, acho que todos entendemos o que é o conteúdo de uma comunicação. A legislação americana define o termo e, aqui, cito: "qualquer informação relativa a substância, teor, propósito, significado ou sentido de tal comunicação". Coloquialmente, é o corpo da mensagem ou aquilo que uma pessoa está procurando transmitir a outra - destinatário -; o corpo e a linha assunto de qualquer *e-mail*, mas não o cabeçalho; mensagem de texto, em conversa que se tenha dado por protocolo VOIP; sobre internet, fotografia compartilhada, postagem em rede social ou qualquer indicação de que alguém curtiu essa postagem também são considerados conteúdo nos termos da lei americana.

Dada a privacidade e a sensibilidade do conteúdo das comunicações, as circunstâncias em que os provedores têm permissão para divulgar o conteúdo dessas comunicações de fato são muitíssimo limitadas nos termos da lei americana. Isso, com frequência, ocorre nos casos em que o

provedor tenha estabelecido uma subsidiária de propósito limitado numa jurisdição estrangeira.

Em minha experiência, em matéria de privacidade, segurança, em termos de eficiência e também por outras razões, as subsidiárias estrangeiras de muitos provedores americanos não têm autoridade para acessar conteúdo de usuários, por consequência, essas subsidiárias não podem atender requisições de divulgação de conteúdo, independentemente de o usuário estar nos Estados Unidos ou no Brasil.

Em 2010, um tribunal americano reconheceu, em decisão confirmada subsequentemente pelo Supremo Tribunal americano, que o cliente de um provedor de serviço de *e-mail* tem expectativa, constitucionalmente protegida, de privacidade do conteúdo de seu *e-mail*. Nos termos da Emenda nº 4 da Constituição americana, portanto, o governo não pode buscar, apreender ou obrigar um provedor a buscar ou apreender, em seu nome, o conteúdo de comunicação de um cliente sem mandado judicial de busca válido, emitido por tribunal americano, com base em demonstração de causa provável.

O mesmo princípio se aplica aqui. A exemplo do *e-mail* de um cliente, a legislação americana dispõe que um cliente tem uma expectativa razoável de privacidade em suas postagens em redes sociais, em mensagens

diretas ou em comentário não público sobre uma fotografia. O provedor está expressamente proibido de divulgar o conteúdo a qualquer pessoa na ausência de exceção legal, e o governo americano não pode obrigar o provedor a divulgar a informação sem um mandado de busca.

Embora a legislação americana crie limites sobre como o conteúdo pode ser obtido por governos americanos ou estrangeiros, a legislação também cria uma trajetória bem reconhecida que permite que os governos estrangeiros obtenham efetivamente conteúdo de comunicações de provedores de serviços americanos em consonância com o SCA e também em consonância com a Constituição americana.

O Tratado MLAT, implementado entre Brasil e Estados Unidos, permite que as autoridades de investigação criminal brasileiras trabalhem com seus homólogos americanos para obter conteúdo de modo a obrigar licitamente o provedor a divulgar o conteúdo dessas comunicações. Nesse sentido, o MLAT respeita a soberania - e, aqui, friso, a soberania tanto do Brasil quanto a dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, protege a privacidade do cliente e permite que a comunidade da investigação criminal investigue e realize a persecução penal do caso.

Como Ministro da Justiça, tive de negociar e executar uma série de MLATs em nome dos Estados Unidos com homólogos estrangeiros.

Também instruí nossos advogados a tirar proveito e, ao mesmo tempo, auxiliar os governos a tirarem o máximo proveito dos MLATs e outros mecanismos legais, em busca de provas de empresas localizadas em outros países. Os Estados Unidos atualmente são parte de MLATs com mais de 65 países e territórios em todo o mundo. Os MLATs são o principal meio, o principal instrumento pelo qual os Estados Unidos atendem a requisições estrangeiras por provas e obtém provas de outros países.

Além do MLAT que existe entre Estados Unidos e Brasil, existe uma convenção multilateral em prol da assistência jurídica mútua entre 35 Estados independentes das Américas, conhecida como Convenção Interamericana em Matéria de Assistência Jurídica Mútua. Esses acordos internacionais conferem à comunidade de investigação criminal brasileira a oportunidade de obter conteúdo de comunicações armazenadas de prestadores de serviços americanos, sem criar quaisquer conflitos com a legislação americana e sem suscitar quaisquer dificuldades na comunidade internacional.

Outro canal para cooperação transfronteiriça entre as comunidades de investigação penal foi criado em março de 2008, quando os Estados Unidos promulgaram a Lei CLOUD, CLOUD Act, um novo arcabouço legal para compartilhamento transfronteiriço de dados. O CLOUD Act

contempla acordos bilaterais adicionais entre aqueles países, de modo a permitir que os provedores americanos possam cumprir os pedidos de divulgação de conteúdo em consonância com a legislação americana. O CLOUD Act é uma ferramenta nova. Atualmente existe um acordo bilateral entre Estados Unidos e Reino Unido. Esse mecanismo, acredito, cada vez mais, virá a suplementar os MLATs como ferramenta adicional para investigações transfronteiriças que respeitem a soberania internacional.

Nesse ínterim, os MLATs têm propiciado meio lícito de obtenção de provas de jurisdições estrangeiras já há muitas décadas e vêm desempenhando papel crucial em inúmeras investigações. Não há qualquer razão, friso, qualquer razão, pela qual os MLATs não possam continuar a desempenhar esse papel na era digital.

Embora os princípios que os MLATs reflitam sejam duradouros e já existam há muito tempo, os esforços dos países para implementá-los podem ser modernos, corroborar maior cooperação entre as autoridades de investigação penal e propiciar maior celeridade nas comunicações, no processamento de comunicações eletrônicas.

O processo de obtenção de provas por meio de MLAT é bastante direto e rápido. Quando um governo solicita assistência nos termos do MLAT e oferece a prova que corrobora, conforme necessário, para um

mandado de busca, a unidade de Assuntos Internacionais do Ministério da Justiça americana irá a um Tribunal Federal, obterá um mandado e obrigará o provedor, em conformidade com a Lei americana e a Constituição americana, a divulgar as comunicações. Com base em minha experiência como Promotor-Geral do Distrito de Columbia e também como Ministro da Justiça americana, sei muito bem que esse processo funciona. Sei também que as agências brasileiras também já usaram a MLAT para obter provas importantes em investigações anteriores.

Conforme disse em depoimento anterior, em 2011, por exemplo, as autoridades de investigação criminal americana usaram o MLAT para obter provas importantes para a investigação de uma colisão aérea que se deu na Amazônia e matou 154 pessoas.

Entendo que o procedimento pode parecer complexo e muito longo, e, certamente, a era digital aumentou o volume dessas requisições no âmbito do processo MLAT. Dentro de uma década, os pedidos de assistência americana de autoridades estrangeiras aumentaram em cerca de 60% e a resposta a alguns desses pedidos, de fato, retardou-se.

Em meu mandato, no período em que atuei como Ministro da Justiça, o Ministério da Justiça solicitou e recebeu milhões de dólares adicionais para aumentar e incrementar os recursos via MLAT.

O sistema tem atendido às necessidades da comunidade de investigação penal por décadas e efetivamente tem alcançado o equilíbrio entre as questões importantes de Estado de Direito e soberania e direitos individuais que podem ser suscitadas em requisições por provas de jurisdição estrangeira, e tem funcionado adequadamente. Com o compromisso apropriado por parte dos dois países, Brasil e Estados Unidos, pode também continuar a funcionar muito bem na era da internet.

Nenhum sistema de Justiça é perfeito. Como Ministro da Justiça, havia momentos em que eu queria que a coisa fosse mais fácil ou mais célere em alguns casos, mas sabia muito bem que proteções procedimentais existiam por uma razão, a saber, proteger o governo, e assegurar que o poder do governo fosse exercido de modo responsável, e, ao mesmo tempo, proteger os direitos constitucionais das pessoas. Com certeza, dois países como os nossos, que têm relação forte e mútua, com recursos determinados e com compromisso, poderão modernizar essa cooperação com o MLAT e atender às necessidades atuais.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Agora com a palavra o Ministro Sérgio Fernando Moro.

O SENHOR SÉRGIO FERNANDO MORO (MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA) - Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, na pessoa de quem tomo a liberdade de cumprimentar todas as autoridades presentes, Senhoras e Senhores.

Penso ser importante, de início, destacar que, neste processo, discute-se basicamente a questão relativa à soberania e à jurisdição brasileiras, à soberania e à jurisdição norte-americanas e ao suposto descumprimento do tratado de cooperação mútua entre Brasil e Estados Unidos.

Não estão em questão aqui, Senhor Ministro, pontos relativos à privacidade, pois tanto a legislação brasileira como a legislação norte-americana protegem a privacidade, os dados e as comunicações dos usuários dos serviços de internet, de comunicação ou de outra natureza. Então, a questão aqui é alusiva unicamente a soberania e jurisdição e a suposto descumprimento do tratado.

Não se pode, inclusive, falar que a lei americana é mais protetora da privacidade do que a lei brasileira ou vice-versa. São tradições jurídicas diferentes, mas ambas contêm proteções significativas à privacidade. Ilustrativamente, a legislação brasileira só admite essa quebra diante de causa provável, causa fundada, dessas comunicações.

Dito isso, cabe aqui destacar que é muito oportuna essa audiência pública para discutir essas questões. Existem questões técnicas envolvidas e se observa que tanto o governo como os litigantes, como as empresas, como a sociedade civil se encontram muito bem representados. No entanto, Senhor Ministro, percebe-se, de antemão, uma ausência significativa, que ilustra muito bem o problema com a demanda trazida pelos litigantes. Não existe aqui qualquer representante do Governo dos Estados Unidos, isso em uma ação proposta pelos litigantes, na qual a questão de fundo diz respeito a um suposto descumprimento do tratado de cooperação mútua entre Brasil e Estados Unidos, um tratado que basicamente envolve a cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos para a produção de provas e outras medidas em matéria criminal.

Ora, diria eu, se houvesse, de fato, um descumprimento do MLAT, do tratado, seria natural que houvesse uma reclamação da parte do Brasil, se o violador do tratado fossem os Estados Unidos; e, da outra parte, dos Estados Unidos, se o violador do tratado fosse o Brasil. No entanto - e aqui eu posso tratar da minha experiência pessoal como Ministro da Justiça e Segurança Pública -, neste um ano de exercício, encontrei-me constantemente - Brasil e Estados Unidos são países amigos e têm interesses mútuos importantes -, encontrei-me frequentemente com representantes do Governo

dos Estados Unidos, com o Encarregado de Negócios, o Senhor William Popp, que faz as vezes do Embaixador norte-americano, com adidos policiais, com autoridades das mais diversas. Estive também em visita aos Estados Unidos, oportunidade na qual tive encontros com o diretor do FBI, tive encontros com o Procurador-Geral dos Estados Unidos, o *Attorney General*, e eu posso testemunhar aqui que, em nenhum momento, em nenhum desses inúmeros encontros, ouvi qualquer reclamação dos Estados Unidos sobre um suposto descumprimento desse tratado de cooperação mútua entre o Brasil e os Estados Unidos.

Não existe, nos registros do Ministro da Justiça e Segurança Pública, nesse período em que estou aqui trabalhando, e não é do meu conhecimento, qualquer reclamação da parte dos Estados Unidos quanto a um suposto descumprimento do tratado de cooperação mútua entre Brasil e Estados Unidos.

O que me permite dizer, e com todo respeito aos litigantes, que não há descumprimento algum no contrato, que não há nenhuma disputa quanto à constitucionalidade do decreto que incorporou esse Tratado de cooperação mútua no ordenamento jurídico brasileiro.

O que existe é uma demanda dos litigantes na qual reclamam uma interpretação que diga que o Tratado teria que ser utilizado

para obter esse tipo de prova, obtenção de dados telemáticos ou de comunicações telemáticas, providenciados por servidores, provedores de serviços sediados nos Estados Unidos, o que não é próprio - aqui tomando a liberdade de fazer um argumento jurídico - de uma ação declaratória de constitucionalidade.

O que se quer é uma interpretação vinculante desse Tratado e uma interpretação vinculante que não é reclamada sequer pela parte do Tratado, os Estados Unidos. Se houvesse realmente um problema com a utilização, ou melhor, com a não utilização desses mecanismos de cooperação bilateral do MLAT, do Tratado de Cooperação Bilateral pelas autoridades norte-americanas, para a obtenção dessa prova, seria natural que viesse da parte que entendesse que as previsões do Tratado estariam sendo violadas, ou seja, dos Estados Unidos.

Indo ao Tratado, Decreto nº 3.810, tomo a liberdade de chamar atenção para alguns aspectos. Nas considerações iniciais:

> "Desejosos de facilitar a execução das tarefas das autoridades responsáveis pelo cumprimento da lei de ambos os países, na investigação, inquérito, ação penal e prevenção do crime (...),
>
> Acordam o seguinte:"
>
> E aí vem o tratado.

Ou seja, o Tratado foi feito para facilitação da obtenção da prova, da cooperação entre Brasil e Estados Unidos e não, aqui, para que ele seja invocado como um instrumento dificultador da produção dessa prova por uma das partes envolvidas.

Item 5 do Tratado:

> "5. O presente Acordo destina-se tão somente à assistência jurídica mútua entre as Partes. Seus dispositivos não darão direito a qualquer indivíduo de obter, suprimir ou excluir qualquer prova ou impedir que uma solicitação seja atendida."

Deixando muito claro que o Tratado visa estabelecer cooperação entre as partes e não outorgar direitos a terceiros que não são partes desse Tratado, para obter qualquer supressão de prova ou dificultar a obtenção de qualquer espécie de cooperação ou de prova.

Por fim - isso é algo interessante nos tratados modelos que são feitos pelos Estados Unidos não só com o Brasil, mas com o mundo inteiro -, os Estados Unidos normalmente têm uma compreensão de que esses tratados não exaurem todas as formas de cooperação possíveis entre os países partes.

Então, não raramente se assistem, especialmente, isso não é tão comum no Brasil, mas no resto do mundo, mas se assistem cooperações entre os Estados Unidos, autoridades dos Estados e autoridade de outros países, em uma forma não prevista no tratado. E a compreensão que eles têm do Tratado é muito clara de que ele não é para ser um meio impeditivo dessas

cooperações fora do Tratado, apenas um instrumento útil para quando essa cooperação for necessária.

E o artigo 17 do Tratado deixa isso muito claro.

> "Os termos de assistência e demais procedimentos contidos nesse Acordo não constituirão impedimento a que uma Parte preste assistência à outra com base em dispositivo de outros acordos internacionais aplicáveis, ou de conformidade com suas leis nacionais. As partes podem também prestar-se assistência nos termos de qualquer acordo, ajuste ou outra prática bilateral cabível."

A avaliação do Ministério da Justiça - eu ouvi das partes técnicas envolvidas -, a nossa compreensão é de que o art. 11 da Lei nº 12.965/2014 deixa clara a viabilidade de que uma corte brasileira emita uma ordem - claro, observados requisitos legais, entre eles, resguardar a privacidade com a exigência da causa provável no processo constituído -, mas deixa clara a competência, a jurisdição das nossas cortes para emitir uma ordem de produção de conteúdo da internet a uma empresa que tenha filial no Brasil, ainda que a sua sede seja no estrangeiro.

Claro que devem ser feitas algumas observações: o crime deve ser um crime sujeito à jurisdição brasileira - evidentemente, não há nenhuma pretensão jurisdicional de investigar crimes que não se encontram sob a jurisdição brasileira; e a comunicação ou produção ou coleta de dados tenha ocorrido, pelo menos em parte, no Brasil. Por exemplo: cidadão residente

no Brasil, utilizando de serviço de informática, em território brasileiro, de provedores com sede no exterior, como Google, Facebook ou Microsoft.

Como vai ser demonstrado adiante nas exposições dos técnicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é importante destacar que o MLAT tem sido realmente um instrumento importante para a cooperação mútua entre Brasil e Estados Unidos. Mas está longe de o MLAT ser um instrumento perfeito de cooperação, dadas as naturais vicissitudes dos mecanismos de cooperação internacional, que avançaram muito, mas ainda têm muito a progredir.

Nessa perspectiva - e isso será detalhado em exposições realizadas adiante -, o Ministério da Justiça fez um levantamento de pedidos de cooperação entre 2016 a 2019, envolvendo obtenção de dados ou comunicações telemáticas do Brasil e Estados Unidos, e foi verificado que apenas 26% deles teriam sido cumpridos total ou parcialmente, ou seja, 74% deles não teriam sido cumpridos.

Por outro lado, foi também destacado que o tempo de cumprimento médio desses pedidos tem sido 10 meses, quando são cumpridos, o que, em termos de investigação criminal, que muitas vezes envolve questões urgentes, pode significar uma investigação criminal destituída de utilidade.

Para finalizar, embora não seja exatamente um especialista em direito e jurisprudência norte-americanos, cumpre destacar que não é exatamente desconhecida da prática jurisprudencial norte-americana a utilização pontual de mecanismos similares.

Em particular, há um caso famoso envolvendo não a produção de material de internet, mas documentos bancários de um banco com sede em outro país, que recebeu uma intimação de uma corte federal norte-americana para apresentação de documentos de clientes que eram mantidos em filiais em outros países, em países como Bahamas, Grand Cayman e Antígua. O caso é conhecido na jurisprudência norte-americana por United States v. Bank of Nova Scotia, de 1984, um caso decidido pela 11ª Corte Federal Norte-Americana, e esse caso acabou sendo mantido pelas instâncias recursais. E é interessante - e eu coloco, aqui, Ministro -, apenas para exemplificar, alguns argumentos que foram utilizados para justificar a manutenção da decisão, ou seja, intimar uma agência do Banco de Nova Escócia, nos Estados Unidos, para produzir documentos bancários de contas mantidas, por exemplo, em Bahamas. O que se entendeu? Que os poderes investigatórios da Corte eram amplos, poderiam incluir determinação e não haveria a necessidade de expedição de um pedido de cooperação internacional para obtenção dos documentos. Sobre o possível conflito entre a lei norte-americana, que obrigava

a apresentação de documentos, e a lei de sigilo dos demais países, que a proibia, a Corte Federal entendeu que haveria um conflito, mas isso não seria suficiente para justificar o não cumprimento da determinação, pois a condução da investigação feita nos Estados Unidos não poderia ser obstaculizada sempre que houvesse um conflito com interesse de outros países. Além disso, o "banco teria voluntariamente escolhido realizar negócios em numerosos países e aceitado o risco incidental de ser submetido a eventuais ações governamentais inconsistentes e não poderia obter os benefícios de realizar negócios aqui, nos Estados Unidos, sem aceitar as concomitantes obrigações."

Finalizando, então, Senhor Ministro e demais presentes, existe um mecanismo - e isso vivenciei mesmo como Juiz - que tem funcionado relativamente bem: Juízes entendendo que o Brasil tem jurisdição e determinando a essas filiais de provedores de serviço de internet nos Estados Unidos a produção de material relevante para investigações criminais - claro, sempre com base nos requisitos da legislação brasileira, que resguarda a proteção da privacidade.

Em geral, isso tem sido cumprido, com pontuais resistências. Eu mesmo decidi alguns casos assim enquanto Juiz e não tive problema na produção desse material. Por outro lado, existe aqui uma demanda que, em síntese, envolve uma suposta alegação de descumprimento

de tratado, que, no entanto, é trazida ao Supremo Tribunal Federal sem que haja legitimidade das partes reclamantes, já que, afinal de contas, quem teria legitimidade para efetuar qualquer reclamação seriam as Partes do Tratado.

O instrumento tem funcionado. Com todo o respeito, não vejo nenhuma razão para que as Cortes brasileiras abdiquem de sua soberania, de sua jurisdição sobre crimes praticados no Brasil em um instrumento que tem funcionado relativamente bem.

No fundo, seria uma decisão, se assim tomada - e, aqui, coloco apenas como hipótese -, que diminuiria a jurisdição e soberania brasileira em favor de outra jurisdição e de outra soberania, que sequer são reclamantes nesse processo.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Com a palavra o Doutor Marconi Costa Mello, do Departamento de Recuperação de Ativos.

DOUTOR MARCONI COSTA MELO (DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL) -Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, a quem saúdo o restante da Mesa. Por premissa de tempo, passaremos a tratar diretamente os principais aspectos relacionados com a matéria que nos toca.

Em complementação ao que disse o Senhor Ministro da Justiça, Senhor Sérgio Moro, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça e do Ministério da Justiça e Segurança Pública contém, na condição de autoridade central, todas as informações sobre como funciona a cooperação jurídica internacional no âmbito do MLAT. Essa é a razão pela qual entendemos que o DRCI tem condição de contribuir com esse debate, justamente por verificar as estatísticas de funcionamento da cooperação jurídica internacional com os Estados Unidos na matéria, especificamente a quebra de sigilo telemático.

O DRCI centraliza todas as solicitações de assistência e recebe os pedidos ativos direcionados aos Estados Unidos, tanto da Polícia Federal como do Ministério Público Federal e Ministérios Públicos estaduais, da Polícia estadual, eventualmente, e do Poder Judiciário especialmente, de forma que temos uma série de autoridades nacionais que fazem solicitações no marco do MLAT.

O que vamos ver na continuação - e talvez seja onde entendemos que podemos contribuir mais com o debate - são algumas estatísticas produzidas pelo DRCI em relação à efetividade da cooperação jurídica internacional do MLAT nessa matéria específica. Sempre pensando que existem três mecanismos pelos quais é possível a obtenção dessa

informação hoje, ou seja, de algumas decisões que vemos na jurisdição nacional. Uma delas seria através do uso da lei nacional, como o Excelentíssimo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ministro Sérgio Moro, remarcou, por meio do art. 11 do Marco Civil da Internet.

O uso de informações prestadas diretamente pelas empresas é mecanismo que também vem sendo utilizado de forma importante. Vemos que algumas empresas têm a disposição de prestar informações diretamente, mas têm o inconveniente de que a forma de prestação dessa informação depende exclusivamente da forma como a empresa entenda que o delito está sendo praticado no Brasil e qual é o alcance desse delito no País. Isso limita substancialmente a forma como a autoridade nacional, seja Ministério Público, Polícia Federal ou Poder Judiciário, encara o processo em si.

Os Estados Unidos, de acordo com nossas estatísticas, são o país do qual a maior parte desses pedidos telemáticos são realizados, por razões, inclusive, óbvias, já que conservam as principais bases de dados do mundo. O que vamos ver justamente - esse seria o gráfico -, conforme o Ministro da Justiça remarcou, é que, atualmente, entre 2016 e 2019 - essa foi a base do nosso trabalho - dos 211 pedidos existentes dessa matéria, 102 ou 108 - não leio daqui - são para os Estados Unidos. De forma que 52% dos pedidos, mais ou menos, são direcionados à jurisdição americana. Como disse, isso é

consistente com o sistema internacional, já que a maioria das bases de dados das principais empresas internacionais se encontra naquela jurisdição.

Este gráfico se refere ao percentual geral de cumprimento de diligências e não tem a ver com os dados telemáticos. Serve justamente para fazer uma comparação com o gráfico seguinte que vamos ver, sobre a efetividade do cumprimento de obrigações relacionadas com a quebra de dados telemáticos. Ou seja, atualmente o percentual geral de cumprimento de diligências estaria em torno de 65%. Se incorporamos também as parciais, passaríamos de 70%, tanto em relação aos pedidos ativos como aos passivos. Nos casos dos pedidos ativos - que é o que nos toca no diálogo de hoje -, ao redor de 71% são cumpridos adequadamente.

Vamos verificar a diferença quando esses pedidos têm a ver com a obtenção de dados telemáticos. Os senhores podem observar que entre os pedidos não cumpridos, digamos, já são mais de 30%. Se entrar na parte de cumpridos, teríamos apenas 20% dos pedidos com base em quebra de sigilo telemático, não mais que 20%. Para isso estamos utilizando 102 pedidos, de 2016 a 2019, e até tiramos da base de cálculo casos anteriores que poderiam gerar algum tipo de distorção. O sistema, como vamos ver também no gráfico posteriormente, vem melhorando, vem-se aperfeiçoando. A própria cooperação internacional em geral vem-se aperfeiçoando nos últimos anos.

Mas o que vemos é que os dados de cumprimento são muito baixos, não mais que 20% ou pouco mais que 20%. Se somarmos os parcialmente cumpridos, chegaríamos a 26% de pedidos cumpridos. Se pensarmos como ficaria a situação do investigador brasileiro nesse marco - Polícia Federal, Ministério Público ou mesmo diligência judicial - não ter acesso a esses dados geraria importante frustração. Entendemos os argumentos contrários, porém entendemos também que, como bem disse o Senhor Ministro da Justiça, não há incompatibilidade entre o sistema internacional e o sistema nacional. O Senhor Ministro também remarcou aqui que o artigo 17 do tratado internacional deixa clara a necessidade de que o tratado aceite e incorpore a legislação nacional de ambos os países. A realidade é que a exclusão das obrigações previstas na legislação de um dos países não é objeto de tratado internacional. O objeto do tratado internacional é criar mecanismos que possam cumprir com as obrigações, e não ir limitando a forma de obtenção de informação. Parece um contrassenso, contrário à própria teleologia do tratado internacional.

Trago também algumas questões. Fizemos um estudo qualitativo de quais seriam os principais temas ou assuntos que impediram a adequada aplicação do tratado internacional, ou seja, o cumprimento das medidas. Dentro desse procedimento, vimos várias causas que impedem que

esse mecanismo funcione de maneira adequada. Dentre as principais razões, remarcamos as seguintes: sem previsão do MLAT seriam 10% dos casos; retenção de dados, 14% dos dados; insuficiência de nexo causal, 12% dos casos; inadequação do pedido, 10,88% dos casos; impossibilidade legal, próximo de 7% dos casos; falta de informação, desistência do pedido e crime contra a honra - também não passível de ser cumprido.

Observamos que a maioria das razões de não cumprimento tem a ver com a impossibilidade, em muitos casos, de a autoridade nacional cumprir os requisitos presentes na legislação estrangeira. Como bem disse o Ministro da Justiça, não é que existe disparidade entre a legislação ou proteção de dados nacional e a proteção de dados internacional - neste caso, a legislação americana. O que se observa é que, em muitos casos específicos de pedidos de cooperação, exige-se, para os pedidos internacionais, mais do que se pede, inclusive, para a própria legislação americana. Isso gera dificuldades adicionais para o investigador brasileiro. Como bem citou anteriormente um dos expositores, em muitos casos os pedidos feitos por autoridades estrangeiras não são passíveis de ser cumpridos; já, se forem feitos por Corte americana... Essa é, aliás, a primeira hipótese de se ter *disclosure*, ou seja, de se ter acesso à informação de dados qualitativos, inclusive de conteúdo. Esse tipo

de situação vem gerando importantes dificuldades para os nossos investigadores.

O que vemos é um esforço grande do DRCI de buscar entender como é a legislação americana, para tentar fazer com que nossos pedidos sejam mais coincidentes com os requisitos americanos. Talvez os colegas que me sucederão falem diretamente das investigações e comprovem a dificuldade de se ter todos os elementos no momento da solicitação.

Quero deixar claro, uma vez mais, que não significa que a legislação nacional tenha menos requisitos que a legislação americana, e sim que a legislação americana, nessa matéria, é mais atenta aos próprios tribunais do que à cooperação internacional. Gostaria de remarcar também argumento do Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública de que um tratado internacional é firmado entre dois países, duas jurisdições. Não temos registros de que o Estado americano tenha feito reclamações ou qualquer coisa do gênero, inclusive ameaçado denunciar tratado, por razões de que a jurisdição nacional tem decidido de forma diversa em momentos específicos. Quer dizer, um pouco da base que utilizamos são os últimos quatro anos. Dos 108 pedidos, somente 20,8 foram integralmente cumpridos. Em média, o índice de conclusão positivo é o inverso do índice de conclusão negativo que temos em casos

normais. Em casos usuais, ao redor de 70% é cumprido. Nesse caso, ao redor de 70% não é cumprido.

Tratamos de buscar todos os casos que foram cumpridos. Dos 102 casos - 26%, então -, observamos 27, e pudemos entrar, um por um, para ver o tempo médio de cumprimento da diligência. O gráfico mostra que, de certa forma, os tempos vêm diminuindo. Esse gráfico também é temporal, ou seja, com exceção dos dois últimos, os últimos têm sido mais rápidos que anteriormente, mas os tempos ainda são muito, muito, muito extensos.

Exemplo: nos dois últimos casos, demorou-se 26 meses para obter-se informações sobre a matéria. Nossos colegas vão poder falar mais, mas para a investigação esse tempo não é proporcional, gera transtornos importantes.

Não podemos também esquecer que, considerando que a maioria das bases de dados se encontra nos Estados Unidos e que, cada vez, vai existir mais pedidos por parte de todas as jurisdições do mundo à jurisdição americana, isso gera um problema, internamente, operacional. Os pedidos de cooperação passam a ser em volume muito grande. Geram também transtornos e dificuldades. Em muitos casos, ao conversar com as autoridades americanas, podemos verificar que eles, de certa maneira, recebem pedidos não apenas do Brasil, mas de todas as partes do mundo.

Já finalizando e entrando nas conclusões, entendemos que atualmente a utilização do MLAT não vem apresentando resultados inteiramente satisfatórios. Isso não significa, em hipótese alguma, que estamos advogando que o Tratado seja inconstitucional ou algo do gênero. Entendemos, sim, que ele é complementar ao sistema nacional ou a outras formas também possíveis de cooperação internacional. A quebra de sigilo demanda tempo considerável, acima do tempo necessário para a investigação.

Por derradeiro, o MLAT prevê que os procedimentos não constituirão impedimento. Esses são justamente os termos do art. 17 do MLAT, que deveria ter conformidade com as leis nacionais dos países.

Nesse caso, se a legislação nacional prevê, no art. 11 do Marco Legal da *Internet*, a possibilidade de obtenção, deveriam os tratados internacionais também se adequarem ao arcabouço jurídico nacional também das jurisdições.

A teleologia do MLAT não é exaurir todas as possibilidades de cooperação, mas, sim, permitir a convivência delas como formas legítimas de obtenção da informação, através de outras formas de cooperação internacional ou de utilização da legislação nacional. Em nossa opinião, os mecanismos são absolutamente complementares e convivem entre si.

Muito obrigado, Senhor Ministro.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Agora, falará o Delegado Doutor Isalino Giacomet Júnior.

O DOUTOR ISALINO ANTONIO GIACOMET JÚNIOR - Excelentíssimo Senhor Gilmar Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Excelentíssimas demais autoridades judiciais, Ministério Público, Advogados e demais presentes.

Venho tentar contribuir, nesta audiência pública, do ponto de vista das autoridades de investigação, em especial da Polícia Federal.

É com grande satisfação que recebemos a notícia da designação da presente audiência pública, a fim aprofundar o debate sobre assunto de extrema importância para a sociedade civil e autoridades públicas, com reflexos diretos na atuação da Polícia Federal e demais instituições de investigação e persecução criminal.

De fato, o tema aqui tratado versa sobre mecanismos de obtenção de dados telemáticos e provas eletrônicas oriundos de ambiente virtual transnacional, cuja atuação demonstra que, apesar de serem elementos tão úteis à sociedade, constantemente são utilizados pelo crime, não apenas para a prática de delitos cibernéticos próprios ou impróprios, mas, principalmente, para a comunicação entre criminosos, das mais variadas formas de delinquência, dentre eles: pedófilos, sequestradores, associações

criminosas, tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro, crimes violentos, crimes contra a honra, eleitorais e, até mesmo, terrorismo. Assim, a obtenção de dados telemáticos e provas eletrônicas repercute cada vez mais na investigação criminal e em toda forma de combate à criminalidade. Em especial, nos delitos de associação e organização criminosa, a comunicação entre comparsas, hoje, feita muito mais por ferramentas e dispositivos de *internet*, é essencial ao êxito do crime. Em outros casos, o uso de *e-mails*, perfis sociais, dentre outros serviços de *internet*, geram e potencializam elevado número de vítimas. Para fazer frente a essa realidade, fazem-se necessários mecanismos operacionais de controle adequado e eficientes que permitam, caso seja necessário, dentro das hipóteses e limites legais, a obtenção de dados telemáticos e o monitoramento de comunicação entre delinquentes.

Para a efetiva elucidação da materialidade e autoria delitivas, o trabalho da polícia judiciária e da Polícia Federal necessita constantemente obter informações telemáticas no exterior, o que envolve fator de transnacionalidade e necessidade de cooperação internacional, tão presentes no complexo combate à criminalidade moderna atual. Para tal finalidade, a polícia, em geral, possui três canais básicos de obtenção dessas informações, como já elucidado pelo colega expositor do DRCI. A Polícia Federal se utiliza, muitas vezes, de contatos diretos com as empresas

provedoras de *internet*, que fornecem informações inclusive de conteúdo nos casos considerados emergenciais - *emergencial disclosure requests*. O problema é que, nesses casos, não há regramento específico e padronizado e o conceito do que é ou não emergencial está na mão das próprias empresas provedoras. Muitas vezes, são casos que envolvem crimes contra a vida, sequestro e cárcere privado, mas há muitos casos considerados emergenciais e urgentes que se referem a outros delitos e a Polícia Federal fica inviabilizada de obter informação em tempo adequado.

O segundo canal disponível foi versado também pelo colega do DRCI, com base no art. 11 da nossa Lei Brasileira de Marco Civil na *Internet*: possibilidade de requisição direta às empresas brasileiras subsidiárias de grupos econômicos estrangeiros, quando constituídas sob leis brasileiras e sediadas no Brasil. Neste caso, alguns provedores representados no Brasil respondem com dados cadastrais e metadados, como bem informado pelo representante americano. Porém, não atendem às solicitações de conteúdo de mensagens e, muitas vezes, justamente essas informações de conteúdo é que são elementares e básicas para que as investigações caminhem, tenham andamento. A alegação de vedação da lei dos Estados Unidos exige a elaboração de pedido formal de cooperação jurídica para a obtenção desses dados. É importante ressaltar que, via de regra, durante as investigações e no

decorrer dos processos penais, as autoridades brasileiras competentes necessitam obter informações telemáticas de pessoas relacionadas a crimes praticados ou ainda em prática no Brasil, em território brasileiro, o que significa que ao menos um dos terminais dessa comunicação está em território brasileiro, conforme exigido por nossa lei, no Marco Civil da *Internet*. Ou seja, a regra é a polícia solicitar apenas dados e informações de pessoas localizadas no Brasil e não dados de terceiros em outros países.

O terceiro canal mencionado de obtenção de dados é o próprio MLAT, cerne de nossa conversa e discussão, solicitação de diligências por intermédio de pedido formal de cooperação internacional, entre as autoridades centrais dos países, baseado em acordo internacional que temos com os Estados Unidos. Conforme os dados já trazidos pelo representante do DRCI, para uma investigação, é inconcebível a média de dez meses - apesar dos esforços das autoridades - para obtenção de dados telemáticos. Não é um problema de relacionamento entre autoridades brasileiras e americanas, pelo contrário, as autoridades centrais dos países, autoridades policiais, os homólogos, tentam trabalhar conjuntamente nessas investigações, entretanto, as dificuldades legais trazem essa realidade.

Imagine, Excelência, situação em que criminosos se comunicam ocultamente pela *internet* - porque não querem aparecer nas ruas -

, mas estão do lado da Polícia, localizados numa esquina e se comunicando com outro comparsa no mesmo bairro de uma mesma cidade - situações locais, típicas de Polícia Civil, por exemplo - e que, para o deslinde de organização criminosa local, tenha de se socorrer de ferramenta que se tem demonstrado muito lenta e com baixo índice de efetividade para esse propósito.

Nosso entendimento é de que o próprio texto do MLAT prevê, em seu art. 17 - como já bem mencionado -, que procedimentos contidos no MLAT não constituirão impedimento a que uma parte preste assistência a outra com base em dispositivos de outros acordos internacionais aplicáveis ou de conformidade com suas leis nacionais. Isso é muito importante: o MLAT não exaure todas as formas de cooperação.

Em virtude do tempo, já passamos a nos encaminhar para algumas conclusões. Ao contrário do que se imagina, pensa ou alega, conforme dados trazidos, não há resposta a nível satisfatório e em tempo plausível e razoável pelo MLAT.

Lembramos que, conforme preceitua o art. 5º, III, do próprio MLAT - Acordo Brasil/Estados Unidos -, pedidos baseados no MLAT são cumpridos de acordo com a lei do país requerido. Essa redação existe em vários outros acordos internacionais que o Brasil possui com outros países. É prática de cooperação internacional. Isso faz com que, nesses casos, a lei americana,

mais restritiva, prevaleça e limite as respostas positivas em detrimento das possibilidades da própria lei brasileira.

Na maioria das vezes, o grau de exigência do denominado Probable Cause - lei interna dos Estados Unidos, conhecida como Stored Communications Act - inviabiliza qualquer pedido de cooperação jurídica internacional, como bem demonstrado.

Apesar das alegadas limitações da lei norte-americana - que realmente existem -, o que se espera é que companhias de grupo econômico estrangeiro estabelecidas no Brasil - além de exercer atividade comercial para uma das maiores populações usuárias de *internet* do mundo - intensifiquem também sua colaboração com as autoridades nacionais e a observância da lei brasileira. Poderiam, talvez, vir ao Brasil trazendo seus bancos de dados de usuários localizados em nosso território e fornecer informações, armazenadas pelas autoridades públicas brasileiras, no âmbito da legislação brasileira, dentro das hipóteses legais.

É importante ressaltar que as dificuldades aqui trazidas, relatadas no MLAT, não são causadas pelas autoridades brasileiras ou americanas, mas são realidade para outros países estrangeiros, como europeus, asiáticos e outros da América. Participações em recentes foros internacionais sobre o tema revelam que essa dificuldade também é inerente a outros países,

então não é problema das autoridades ou da estrutura administrativa de persecução e investigação brasileiras.

Em nosso entender - aqui creio que seja ponto nevrálgico para nossa discussão -, faz-se necessário remodelar ou criar novo critério de entendimento sobre jurisdição aplicada nos casos de quebra de sigilo telemático, devendo ser valorada com ênfase no território do usuário do serviço e não na territorialidade do local de armazenamento dos dados. Esses dados podem ser encontrados disponíveis virtualmente de forma mais ampla em qualquer lugar e podem ser transferidos rapidamente, o que oculta e dificulta muito o acesso de autoridades de investigação, então o critério de territorialidade, com foco no usuário do serviço, é muito bem-vindo. Essa é a tendência de interpretação dos foros internacionais mais relevantes sobre o assunto, inclusive os que versam sobre a Convenção de Budapeste - em relação à qual o Brasil já está em fase de adesão e que possui dispositivos legais nesse sentido. Ademais, o art. 11 do comentado Marco Civil da Internet vem justamente trazer esse enfoque: a necessidade de buscarmos informações baseadas na jurisdição do usuário do serviço.

Esse tipo de concepção de jurisdição, como até comentado pelo Ministro da Justiça, não é totalmente estranha. Há preceitos na própria legislação dos Estados Unidos, no que afeta a assuntos de crimes financeiros e

lavagem de dinheiro, por exemplo, o United States Code, sessão 317, que permite aos tribunais a chamada jurisdição de longo alcance - *long-arm jurisdiction* - em relação a pessoas não pertencentes aos Estados Unidos cometedoras de crime de lavagem de capitais nos Estados Unidos, sobre bancos não norte-americanos que abrem contas bancárias nos Estados Unidos e sobre pessoas não norte-americanas que convertem ativos cujo confisco foi determinado por tribunal daquele país. Nesse dispositivo e em outros - que não vou comentar em virtude do tempo -, as próprias autoridades norte-americanas podem não se utilizar de instrumentos de cooperação jurídica internacional, via MLATs, e tentar obter informações diretamente junto às instituições financeiras sediadas nos Estados Unidos e que têm vínculos com pessoas e instituições.

Portanto, as medidas de cooperação jurídica devem ser interpretadas de forma favorável e ampliativa. Essa é a lógica da cooperação, desde que haja previsão em outros acordos internacionais ou em leis. Estamos falando de hipótese de não utilização do MLAT prevista em lei, não é algo inventado, há lei brasileira que rege o tema.

Com a utilização de obtenção de dados com base no Marco Civil da Internet, não há desrespeito aos princípios internacionais. O que se pretende é dar importância igualitária à lei nacional e ao Marco Civil da

Internet, e não o subjugar ou submeter aos limites da lei americana, o Stored Communications Act.

Nesse ponto, indagamos: por que diminuir de importância a lei brasileira em relação a esse tema, se todos os elementos necessários estão aqui - criminosos, pessoas se comunicando, entidade, associação e empresa de grupo econômico estabelecida formalmente no Brasil?

A utilização do Marco Civil da Internet para essa finalidade - opção feita por algumas autoridades investigativas e judiciais nacionais - não acarreta, salvo melhor juízo, negativa de vigência de declaração de inconstitucionalidade ao MLAT, por serem mecanismos complementares. Eventual decisão que limite a forma de obtenção de informações e quebra de sigilo telemático no exterior apenas aos procedimentos de cooperação do MLAT acarretará forte limitação aos instrumentos legais disponíveis às autoridades brasileiras no combate à criminalidade.

Parece-nos que o pedido desta ADC, na verdade, pretende, de forma transversa, declarar a inconstitucionalidade do art. 11, o que não pode ser aceito neste caso. Dessa forma, defendemos, portanto, Excelência, a constitucionalidade do MLAT, por óbvio, por ser instrumento legal e em vigor, mas considerado em texto integral - inclusive considerando seu art. 17 -, pelo

qual devemos interpretá-lo e aplicá-lo sem prejuízo de outras formas legais de cooperação previstas em lei.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado!

Faremos uma interrupção de dez minutos e voltaremos em seguida com as próximas exposições.

(INTERVALO)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Estão reabertos os trabalhos. Agora ouviremos, pelo Ministério Público, as Doutoras Fernanda Teixeira Souza Domingos e Neide Mara Cavalcanti Cardoso de Oliveira, que dividirão o tempo.

A SENHORA NEIDE MARA CAVALCANTI CARDOSO (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL) – Bom dia! Cumprimento a todos na pessoa do Excelentíssimo Relator.

A presente Ação Direta de Constitucionalidade pretende que o Decreto nº 3.810/2001 - Acordo de Assistência Mútua, em matéria penal, com os Estados Unidos da América - seja declarado constitucional e único instrumento legal a ser utilizado para obtenção de conteúdo armazenado e

comunicações em poder de empresas brasileiras, cuja empresa mãe tenha sede no exterior.

É claro que o Decreto MLAT é constitucional, sendo utilizado para obtenção de provas sobre as quais o Brasil não tem jurisdição, isto é, quando os serviços do provedor de internet são utilizados, mas esse provedor, além de não ter representação no Brasil, não está direcionando seus serviços para o Brasil, situação somente possível com o advento da internet.

Nas demais situações, em que o provedor de serviços de internet tem representação no Brasil e/ou está prestando serviços direcionados ao público em território nacional, aplica-se a jurisdição brasileira para obtenção dos dados recolhidos a partir do território nacional. Sabemos que o serviço está sendo direcionado ao público em território nacional quando, por exemplo, o serviço é prestado em português, apresenta publicidade direcionada ao público local, oferece vendas em nossa moeda, o real, ou seja, quando um provedor de internet tem contato suficiente com o território nacional. Na situação em que o provedor de internet tem representação física no País ou integra o mesmo grupo econômico da empresa que tenha representação física, a jurisdição brasileira é clara e indiscutível para obtenção de todos os dados, incluindo conteúdos recolhidos a partir do território nacional.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB - lei geral para interpretação das normas - estabelece em seu art. 12 que uma empresa, para operar no Brasil, deve estar constituída sob as leis brasileiras e a elas submetida. O art. 21 do Código de Processo Civil, na mesma linha, estabelece jurisdição sobre empresas com representação no Brasil. O art. 11 do Marco Civil da Internet - lei especial para a matéria - estipula claramente que a empresa provedora de internet que presta serviços direcionados ao público em território nacional, aqui recolhendo dados, possuindo ou não representação no Brasil, está sujeita à jurisdição nacional e deve entregar os dados às autoridades brasileiras, quando assim determinado por ordem judicial fundamentada. O critério para determinação da jurisdição brasileira, nesses casos, é o dos efeitos dos serviços, mesmo critério adotado pelo art. 18 da Convenção de Budapeste do Cibercrime - da qual, desde dezembro, o Brasil é observador -, reconhecendo que cada país signatário possui jurisdição sobre as provas coletadas em seus territórios, por empresas ali sediadas ou que prestam serviços direcionados a seu território; mesmo critério adotado pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados - GDPR - regulamento da União Europeia -, que incide sobre as empresas estabelecidas no território da União - critério territorial - e também sobre as empresas estabelecidas em outros territórios, mas que oferecem serviços às pessoas do território europeu -

critério dos efeitos do serviço; mesmo critério adotado por nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará em vigor em agosto deste ano e que é muito semelhante ao GDPR, prevendo a aplicação das regras de proteção sempre que os dados tiverem sido coletados em território nacional; mesmo critério adotado pelo *Cloud Act* - lei americana clarificadora a respeito da jurisdição americana -, que, além do critério de controle pela empresa americana, também adota o critério dos efeitos do serviço, como esclarecido no *White Paper* do Departamento de Justiça americano sobre a questão, nos termos da Convenção de Budapeste, da qual os Estados Unidos são parte; mesmo critério adotado também pelo projeto de resolução da União Europeia sobre evidências digitais, o *E-evidence*, ainda em discussão, mas segundo o qual autoridades legais dos países membros poderão expedir ordens de preservação ou de requisição direta de dados e demais provas eletrônicas, incluindo conteúdo, a provedores que ofereçam serviços no território da União Europeia, independentemente do local do estabelecimento da empresa ou do local de armazenamento dos dados.

Desta forma, o art. 11 do Marco Civil da Internet - lei específica para a matéria - está em consonância com as leis gerais nacionais e com as normativas internacionais, devendo ser utilizado nas hipóteses em que descreve, ficando o decreto de MLAT restrito às hipóteses nas quais não há

jurisdição brasileira, ou seja, quando os serviços de internet não estejam sendo direcionados ao território nacional.

Se a ADC 51 for julgada procedente, com os efeitos pretendidos pelos autores, de que o conteúdo só pode ser obtido mediante MLAT, negando-se a jurisdição brasileira, além do prejuízo a todas as investigações criminais que dependam deste conteúdo, estarão inviabilizadas as investigações por crimes de ódio, crimes eleitorais e até mesmo incitação ao terrorismo que dependam de comunicações em poder dos provedores de internet ou conteúdo armazenado, já que esbarram na Primeira Emenda à Constituição Americana e hoje não são fornecidas nem mesmo por meio de MLAT.

Diga-se de passagem, a adoção de acordos executivos bilaterais propostos no *Cloud Act* não são a melhor solução para o Brasil, pois esbarram no mesmo problema de não permitir a obtenção de conteúdo que toque a Primeira Emenda à Constituição Americana. Conflitos de lei precisam ser solucionados pelo princípio da cortesia, levando em conta os efeitos dos serviços.

DOUTORA FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL) – Boa tarde! Cumprimento também o Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, em nome de quem cumprimento todos os demais presentes.

A prevalecer o entendimento defendido na ADC 51, investigações de diversos tipos de crimes e procedimentos - em especial aqueles previstos no Código Eleitoral e leis esparsas - estarão gravemente prejudicados. Para além da questão criminal, *fake news* e desinformação nas redes sociais, por exemplo, podem configurar abuso de poder econômico no uso dos meios de comunicação social e podem redundar em cassação de diploma e inelegibilidade.

A apuração desses impactos na legitimidade das eleições, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990, dependerá diretamente de se investigar e apurar a gravidade e extensão da fraude, e, para isso, dados dos provedores de serviços, inclusive conteúdo, podem ser essenciais e devem ser entregues em tempo exíguo.

A legislação eleitoral, ao incluir no Código Eleitoral o artigo 326-A, foi alterada ano passado para punir aquele que propaga a *fake news* e prevê a denunciação caluniosa com fins eleitorais - pena de dois a oito anos e multa -, cujo § 3º diz: "incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem,

comprovadamente, ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala por qualquer meio ou forma o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído".

Da mesma forma, o Código Eleitoral prevê os crimes de calúnia, difamação e injúria para fins eleitorais. O próprio artigo 324 do Código Eleitoral diz, no § 1º, que, nas mesmas penas, incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.

Para se identificarem os autores desses crimes ou de abuso de poder na internet, resolução recente do TSE para as eleições deste ano, nº 23.610, prevê, no artigo 39: "o provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de forma autônoma ou associados a dados cadastrais, a dados pessoais, ou a outras formas, outras informações disponíveis que possam contribuir para a identificação do usuário mediante a ordem judicial". Reproduz artigo similar do nosso Marco Civil da Internet, assim como o artigo 40, que permite que a parte interessada possa sempre requerer ao juiz eleitoral que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento dos dados constantes do artigo 39 da Resolução.

Vencendo a tese dos autores, estarão inviabilizadas as investigações de crimes eleitorais e abuso de poder que dependam de conteúdo

em posse dos provedores de internet, tornando letra morta a vontade do Congresso Nacional. Iniciativas como as das ADC 51, ADPF 403, ADI 5.527 e o Projeto de Lei do Senado Federal nº 169/2017 vêm na contramão da tendência mundial que vê como necessária a assunção, pelos provedores de internet, de maior responsabilidade social, de se afastar do critério puramente territorial para fixação da jurisdição competente, aproximando-se dos critérios dos efeitos dos serviços e, por fim, de colaborar com as autoridades locais.

A Ação Declaratória de Constitucionalidade 51 é procedente porque o Decreto nº 3.810/2001 - MLAT Brasil-Estados Unidos - é constitucional. No entanto não se aplica sobre dados colhidos de pessoas em território nacional por provedores de aplicações à internet que prestam serviços a brasileiros, nos termos do Marco Civil da Internet e na esteira da atual legislação internacional, motivo pelo qual reiteramos o parecer da Procuradoria-Geral da República constante nos autos.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado. Agora falará o Doutor Bruno Calabrich.

O SENHOR BRUNO CALABRICH (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL) - Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, Relator e Presidente desta Audiência Pública, Excelentíssima Subprocuradora-Geral da República, Doutora Luísa Franchise, em nome de quem cumprimento as

demais autoridades aqui presentes, cumprimento também os nobres advogados, os ilustres professores e pesquisadores.

No breve tempo de minha exposição, pretendo tratar de um ponto bem específico que foi mencionado apenas rapidamente aqui também, mas que pode ajudar a esclarecer alguns temas para nossa reflexão.

Em 2013, o Departamento de Justiça Norte-Americano conduziu investigação sobre um caso corriqueiro de tráfico de entorpecentes. E foi necessária a obtenção de mandado para acesso a dados de IP e de conteúdo de e-mail de certo usuário que interessava àquela investigação. Esse mandado foi concedido por um juízo de primeiro grau em Nova Iorque, e a Microsoft, que era a detentora, que era a controladora desses dados, porque era a provedora do e-mail, inicialmente, se recusou a cumprir essa ordem, alegando que os dados desse e-mail estavam armazenados em um provedor na Irlanda. E impugnou, portanto, a decisão do juiz de Nova Iorque, recorrendo à Corte de Apelação do Segundo Circuito de Nova Iorque.

Em 2016, esse recurso do DOJ foi julgado procedente por essa Corte de Apelações, dando razão à Microsoft, ao argumento de que o *Stored Communications Act*, que era a lei que baseava o pedido, não autorizava a extraterritorialidade de decisão norte-americana. O mandado não poderia ser

cumprido no estrangeiro, porque a lei americana assim não autorizava. Não haveria jurisdição sobre a Irlanda.

O DOJ recorreu à Suprema Corte, a Suprema Corte norte-americana concedeu o *writ of certiorari*, ou seja, admitiu a admissibilidade do recurso. E essa pendência foi suplantada com a aprovação, em 2018, do CLOUD Act, que é um acrônimo para *Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act*. Numa tradução livre, seria lei para esclarecimento do uso de dados no exterior.

A aprovação desse CLOUD Act representou uma vitória para as empresas e, também, para o governo norte-americano.

É interessante, porque passou-se a prever, a partir de então, a possibilidade de cooperação direta, fornecimento direto de dados por empresas de tecnologias a autoridades incumbidas da persecução penal sem passar pela via do MLAT, ou seja, seria uma alternativa à cooperação via MLAT.

Isso é interessante, claro, para as empresas, porque para elas representa o *safe harbor*, o porto seguro.

A lei norte-americana, sendo cumprido o protocolo do CLOUD Act, não será descumprida e, portanto, a empresa se exime da responsabilidade perante a sua Justiça. É uma garantia de que não serão

processadas na Justiça dos Estados Unidos. É uma pretensão legítima das empresas.

A questão é que nesta ADC se discute se o decreto executivo que promulgou o MLAT Brasil/Estados Unidos é constitucional ou não. Não há nenhuma dúvida disso. Isso foi afirmado até pelos autores dessa ADC, nesta Audiência Pública.

A questão é que a declaração da constitucionalidade desse decreto não levará aos efeitos pretendidos pelos autores, pelo simples fato de que nós temos uma lei, muito clara, muito específica, muito objetiva, que obriga empresas que operam no Brasil ou que oferecem seus serviços no Brasil a cumprirem a lei brasileira e, consequentemente, a cumprirem as decisões brasileiras.

O ponto que eu gostaria de destacar, é o seguinte: a aprovação do CLOUD Act pelos Estados Unidos, na verdade, é o reconhecimento, tanto pelo Estado norte-americano quanto pelas empresas norte-americanas, de que a via da cooperação pelo MLAT não tem sido eficiente em matéria de cooperação em relação a dados de internet. Não tem sido eficiente tanto em relação ao Brasil quanto em relação a qualquer país. No caso, era com relação à Irlanda.

O DRCI trouxe dados muito interessantes e atualizados que mostram que a cooperação com o Brasil tem alcançado resultados efetivos de apenas 20%. Isso não quer dizer que tenha que ser ignorado esse instrumento, ele pode ser utilizado para outras questões, mas em relação a dados de internet, nós temos um marco civil bastante claro, bastante específico, que deve ser cumprido.

E, por isso, eu, como pesquisador do tema e como Membro do Ministério Público Federal, que também trabalha com isso, reitero o entendimento do MPF, no caso, pela procedência da ADC.

A questão processual nos parece bastante relevante. Foi destacado aqui, no início de uma das apresentações, que as questões estariam superadas neste processo, mas, na verdade, não.

A sensibilidade de Vossa Excelência com relação ao tema levou à marcação desta Audiência Pública, porque, de fato, é muito cara a persecução penal no Brasil. Mas a questão processual continua sendo relevante e não pode ser ignorada. A nosso ver, há ausência de interesse na modalidade necessidade que levaria à extinção da ADC ou ao julgamento pela sua procedência sem os efeitos pretendido pelos autores.

Pela atenção de todos, muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Agora, falará o professor Flávio Unes, Presidente da Comissão Especial de Produção de Dados OAB.

O SENHOR FLÁVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente Gilmar Mendes, em nome de quem cumprimento todas as autoridades, Senhoras e Senhores.

Eu vou repetir, aqui, o início, pontuado pelo professor Rezek, de que há uma diferença muito grande entre editar uma lei com a pretensão de que o direito material seja aplicado e a exigibilidade disso, quando o destinatário da norma não está no território nacional, como é o caso das empresas que estão no exterior.

Essa diferença precisa ser considerada, sob pena de que, amanhã, batam na nossa porta, pretendendo aplicar uma lei que não existe aqui, que existe em outro país, à revelia da nossa jurisdição e das nossas leis. Defender a soberania nossa também é reconhecer a dos outros, sob pena de que amanhã a nossa seja violada pelos mesmos fundamentos.

Uma outra questão que me parece importante, dita aqui pelo Ministro Sérgio Moro, conta que não está em pauta uma questão de privacidade. Ambos os países protegem a privacidade. Cada um protege da sua forma. Veja, o Ministério da Justiça apresentou informações, por meio do

seu departamento, dizendo que 24% dos pedidos foram recusados por envolver solicitações feitas para fins de elucidação de crimes contra a honra, sob o argumento de que, de acordo com a Emenda Constitucional nº 1 americana, os Estados Unidos não compreendem tais condutas como atos criminosos. Se lá não é crime, então, acessar o conteúdo restringiria a privacidade na noção que aquele país, dentro da sua soberania, entende. Então, sim, se trata sim de reconhecer que a noção de privacidade de um país em relação ao outro pode variar; para uns, pode ser crime determinada conduta; para outros, não. Então, como é que eu posso pretender dizer que não está em discussão isso?

Bom, se não está em discussão isso, está em discussão o quê? Uma morosidade, então é moroso. É interessante que, ao mesmo tempo que a manifestação do Ministério da Justiça é no sentido de "Olha, nós estamos fazendo nosso trabalho muito bem feito, não é um problema de autoridades nem daqui, nem de acolá, mas, olha, demoram muito para responder." Há um problema, então, de eficiência. Se é um problema de eficiência que leva a uma desproporcionalidade e a um esvaziamento do cumprimento do Tratado, quem tem que denunciar o Tratado é o Brasil, por não estar sendo cumprido a pretexto de formalismos.

Agora fazer o raciocínio de que "Olha, se tivesse alguma coisa errada, o Brasil ou os Estados Unidos estariam reclamando, estariam denunciando o Tratado." O fato de ainda não ter havido isso não autoriza uma interpretação de dizer que, à revelia do Tratado, eu posso diretamente exigir de alguém o cumprimento de uma lei que é minha e não a do outro, sob pena de o outro ser sancionado lá por descumprir minha lei lá! É como se eu dissesse assim: "Olha, você pode matar sim, mas você vai preso, tá?"

Essas empresas, e foi demonstrado nos autos, estão sendo sancionadas lá quando entregaram diretamente. Então, como é que eu posso exigir que elas entreguem isso, sabendo que elas serão apenadas, sancionadas, pela jurisdição de outro país? E que, à luz da soberania, têm exclusividade de jurisdição do seu país como nós temos a nossa! É exigir o absurdo!

É verdade que essa solução poderia ser encaminhada de uma outra forma, exigir, por exemplo, que o *data center* seja localizado no Brasil, por meio das suas afiliadas. Mas o legislador brasileiro deliberadamente, no Marco Civil da *Internet*, retirou essa exigência. Havia uma proposta nesse sentido, e o legislador retirou. Não tem que estar aqui. E há discussões em torno disso, porque isso pode ser oneroso; isso, por exemplo, pode comprometer ainda mais as noções de privacidade, confidencialidade, segurança. Então, a ideia de centralidade desses dados em um lugar é

importante à luz dessas premissas. Mas é um debate que o legislador brasileiro tem que travar. Não sou eu, desgostoso da ideia do legislador, que vou arranjar um jeito de contornar esse problema.

E, vejam os senhores, fala-se muito no art. 17. Falou-se aqui o tempo todo do art. 17 do acordo. Então, é preciso lê-lo do jeito que ele está dito. Diz assim:

> "Os termos de assistência e demais procedimentos contidos neste Acordo não constituirão impedimento a que uma Parte preste assistência à outra com base em dispositivos de outros acordos internacionais aplicáveis, ou de conformidade com suas leis nacionais."

Não é com a minha lei não, é com as suas. A noção, portanto, que se deve ter é de reciprocidade, como por exemplo, se lá não é crime, a lei lá não criminaliza calúnia, então, eu não posso agora, porque eu criminalizo, entender que a empresa que está lá tem que fornecer, sob pena de cometer o crime que tem o limite territorial brasileiro. E é interessante, porque, na hora que vem o Ministério da Justiça por meio do seu departamento, logo depois que transcreve isso, ele diz "Está de acordo com a nossa lei". Mas lá está falando de "suas leis".

Então, nem na literalidade do dispositivo mencionado, eu, com a devida vênia, conseguiria vislumbrar a possibilidade desse caminho paralelo. O que se discute aqui é o acerto ou não de decisões brasileiras, que é

uma das razões e um dos requisitos para uma ADC, a propósito de um tema de estatura constitucional, que tem trazido uma controvérsia jurisprudencial relevante. Não chegou no Supremo; chegou agora. Talvez seja até por isso que não tenha sido denunciado o Tratado ainda - precaução dos Estados Unidos que estão aguardando para ver o deslinde aqui. Mas jamais levar ao raciocínio indireto de que isso significa que está tudo bem, obrigado, como se o Poder Judiciário brasileiro não pudesse reconhecer a inconstitucionalidade ou a desconformidade com noções como privacidade, soberania, do art. 4º, que foi mencionado aqui, que diz dessa convivência harmoniosa entre os povos.

Uma outra questão que me parece relevante é aduzir sobre a ideia de proporcionalidade, ou seja, essas decisões brasileiras estariam, seriam necessárias, elas atenderiam àqueles requisitos de adequabilidade, de necessidade, de proporcionalidade em sentido estrito?

Só pela noção de adequabilidade, reconhecer que, em outro país, há uma sanção a uma determinada empresa por ela entregar diretamente, já mostra que eu não posso exigir isso dela, seria desarrazoado.

Na questão da necessidade, também seria um despautério imaginar que eu poderia eleger um caminho muito mais gravoso quando eu já tenho outro, que é exatamente o dos tratados, dos acordos internacionais

previstos, que viabilizam isso de uma forma consentânea com os dois entes, os dois Estados.

E a proporcionalidade em sentido estrito, aí, fica completamente sem sustentação.

É nesse sentido que, à luz dessa noção do princípio da proporcionalidade, essas decisões brasileiras, isoladas, por parte de Tribunais, até mesmo do Superior Tribunal de Justiça, com a devida vênia, revelam o seu desacerto.

E, portanto, a Ordem dos Advogados do Brasil reconhece que o devido processo legal deve ser obedecido, devido processo legal este acordado entre dois Estados soberanos.

E, como bem disse, há uma recente lei, Lei das Nuvens, assim colocado também, que possibilita aditivos e novas tratativas que possam otimizar essa entrega. E, nesse sentido, há até uma expectativa positiva, porque não é de hoje que se coloca uma relação extraordinária entre os Estados Unidos e o Brasil. Ora, se assim o é, nós não teremos dificuldades nenhuma em promover ajustes e melhorias nessa relação.

Muitíssimo obrigado!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado.

O SENHOR ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA (ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO) - Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, antes de mais nada, cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela possibilidade desta Audiência Pública; Doutora Luíza, representante máxima do Ministério Público Federal, demais autoridades, Audiência, como um todo.

A Advocacia-Geral de União tem o papel de fazer a defesa no âmbito dos três Poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário - e, de modo específico, nessa Ação Direta de Constitucionalidade, de preservar, naquilo em que for consentâneo com o Texto Constitucional, como princípio, a constitucionalidade das normas.

O tema aqui trazido parece que já, até o momento, nos traz a perspectiva de um consenso de constitucionalidade, do que eu ouvi até a presente hora. A grande questão são os efeitos dessa declaração: em que medida o reconhecimento dessa constitucionalidade impacta os tratados, impacta os procedimentos de cooperação e assistência mútua entre autoridades para fins de investigação de ilícitos criminais.

Da nossa parte, para que também nós formemos nossa convicção como defensores máximos do Estado e possamos, ao final, fazer a defesa na tribuna do Supremo Tribunal Federal, estamos, não só eu, como toda a Advocacia-Geral através de outros membros aqui presentes tomando nota,

amadurecendo os conceitos, as perspectivas e as visões das partes para que, ao final, possamos fazer a adequada defesa da União nessa Ação Direta.

É motivo de grande reconhecimento da nossa parte a iniciativa de Vossa Excelência, iniciativa essa iniciada treze anos atrás, com a primeira audiência pública, presidida pelo nosso querido Ministro Ayres Britto, e apenas reforça o compromisso do Supremo Tribunal Federal, a partir dessa iniciativa, com o princípio democrático, com a necessidade de ouvirmos as partes, como é peculiar a Vossa Excelência, para que o Supremo Tribunal Federal possa tomar a decisão de forma imparcial e com os melhores elementos de convicção possíveis.

Registro o agradecimento e uma boa continuidade à Audiência como um todo.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Nosso último expositor da parte da manhã, Doutor Lucas Borges de Carvalho.

O SENHOR LUCAS BORGES DE CARVALHO (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES) - Bom dia, Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, demais presentes!

Eu falo aqui em nome do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e vamos trazer alguns pontos, alguns deles já

abordados aqui, mas trazer as nossas contribuições em relação a esse debate sobre as condições e os limites para o adequado exercício da jurisdição nacional na internet.

Começo com uma breve contextualização do tema. Como se sabe, a jurisdição dos Estados está circunscrita pelos limites territoriais, o que foi um paradigma, ou um critério, que se demonstrou funcional durante muitos anos, muito tempo, porque a conduta dos indivíduos ou a ação de empresas, em geral, os seus impactos estavam limitados ao âmbito local ou ao âmbito nacional. Nesse sentido, as fronteiras jurídicas coincidiam também com as fronteiras geográficas, o que vai mudar ao longo dos últimos anos com o avanço das tecnologias da informação e da comunicação, da internet, a possibilidade de interações e troca de dados, especialmente por meio da internet, que não vão respeitar fronteiras, que vão muito além das fronteiras, de modo que condutas de indivíduos e a atuação de empresas, embora originalmente locais, passam a estar entrelaçadas ou passam a ter impactos que são muitas vezes globais, que vão muito além das fronteiras, o que vai colocar em xeque, então, esse modelo que se mostrou funcional durante muito tempo, no qual o critério essencial para avaliação dos limites da jurisdição nacional eram ali, como mencionei, critérios de ordem territorial.

Isso coloca, então, uma série de desafios que eu tento resumir aqui com base nesses dois conceitos: legitimidade e eficácia, que a gente pode dizer que são os dois pontos de apoio para um adequado exercício da jurisdição nacional no âmbito da internet. Trata-se, então, de uma busca de difícil equilíbrio - e essa é uma palavra-chave aqui neste nosso debate, equilíbrio - entre legitimidade e eficácia. A todo momento, estamos aqui discutindo esses dois pontos. De um lado, a legitimidade, ou seja, os procedimentos adequados a serem seguidos para uma determinada decisão e também os fundamentos jurídicos substantivos e materiais que amparam uma determinada decisão e, de outro lado, a eficácia, ou seja, o cumprimento efetivo, o resultado, que deve ser célere e adequado, de uma determinada decisão no âmbito da realidade social.

Então, resumindo, um nível adequado de eficácia deve corresponder ao mesmo grau de legitimidade atribuído a essa decisão. Deve haver, nesse sentido, um equilíbrio entre esses dois pontos de apoio do exercício da jurisdição nacional, o que encerra essa primeira parte e nos leva, então, a um tema, a uma pergunta central que está envolvida nesta ação e em outras também em curso neste Supremo Tribunal: como garantir de forma legítima o efetivo cumprimento de normas e decisões estatais no ambiente digital?

Mas o ponto é que esse equilíbrio, como mencionei, é difícil. Se formos analisar a história desse debate - da internet e jurisdição -, ela é, na verdade, uma história de desequilíbrios. Estamos muito longe de alcançar esse equilíbrio entre legitimidade e eficácia, e eu destaco aqui dois desequilíbrios que mostram bem a natureza desse debate e o desafio posto para ser enfrentado.

De um lado, o desafio do desequilíbrio da hiper-regulação, ou seja, atribui-se máxima eficácia a uma determinada decisão, subestimando-se ou ignorando-se as exigências de legitimidade. Isso leva então, muitas vezes, a se passar por cima da complexidade envolvida, técnica e jurídica, no ambiente da internet, no ambiente digital.

Um princípio importante e fundamental, que está no Marco Civil na Internet, é o princípio da escala mundial da rede. A lei fala em um reconhecimento da escala mundial da rede e também os efeitos sistêmicos de uma determinada decisão. Muitas vezes, no caso concreto, por mais que aquele ponto pareça limitado àquele ambiente local, na verdade ele pode gerar efeitos que são muito mais largos, efeitos sistêmicos, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista jurídico, atingindo direitos que são essenciais ou atributos essenciais para o funcionamento da internet.

Eu destaco aqui alguns exemplos. Obviamente, são casos controversos: o bloqueio do YouTube, no caso Cicarelli, do Brasil; o bloqueio do WhatsApp também, que é um tema também posto aqui para decisão do Supremo Tribunal Federal.

E há exemplos diversos que temos em relação a decisões locais que expressamente atribuem efeitos globais, atribuem eficácia global, a sua decisão. Então, temos casos no Canadá, na França e há também, em relação a esse ponto, casos já no Brasil, especificamente no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual foram atribuídos expressamente efeitos globais, por exemplo, para remoção de determinado conteúdo, o que significa que aquela decisão vale não somente para o .br, ou seja, para IPs nacionais, mas também acaba por atingir pessoas que estão localizadas em outros países, em outras jurisdições.

No outro extremo, então nós temos o oposto. O desequilíbrio da desregulação, ou seja, uma máxima legitimidade e uma mínima eficácia. Aqui, o peso todo da análise ou da interpretação está no pilar da legitimidade. Essa ideia de legitimidade vai ser identificada com a ideia de autorregularão, ou seja, com a ideia de mínima intervenção do Estado, e isso permeado por, muitas vezes, um discurso de determinismo tecnológico, ou seja, a tecnologia é vista, ou pelo menos ela se impõe, como uma força inevitável que vai se suplantar ou se sobrepor às decisões estatais, ou seja,

também a própria tecnologia seria capaz de permitir uma adequada regulação do ambiente digital.

Como consequência, nesse ambiente de desequilíbrio, trata-se de uma ampla e irrestrita liberdade de atuação de agentes econômicos, incluindo a possibilidade de definir as normas que regem as suas atividades, por exemplo, nas suas relações com seus usuários, mencionando aqui provedores de aplicações, e, no limite, a possibilidade de optar por qual norma estatal seguir de acordo com os seus interesses e conveniências. Então, é possível, no ambiente da internet, como é de conhecimento geral, a empresa ter uma sede em um país europeu, hospedar seus dados nos Estados Unidos e ofertar serviços no Brasil, o que, embora seja uma estratégia legítima do ponto de vista da empresa, pode, num ambiente de desregulação, significar a possibilidade de optar por qual norma seguir ou a qual norma se submeter.

Então, nós temos esses dois desiquilíbrios. De um lado, a hiper-regulação e, de outro, a desregulação. E como se coloca então a legislação brasileira, especialmente o Marco Civil da Internet, e o tema específico aqui da nossa discussão, que é o de acesso a dados armazenados no exterior?

A nossa posição aqui é de que o Marco Civil da Internet, sim, consagrou a posição de equilíbrio. Por quê? Primeiro, os critérios adotados pelo Marco Civil na Internet, especialmente no art. 11, seguem e aperfeiçoam

parâmetros definidos pela jurisprudência dos tribunais brasileiros ao longo da última década. Além de todo o processo participativo, de debate com a sociedade, que resultou no Marco Civil da Internet, neste ponto específico, o Marco Civil reproduz uma jurisprudência consolidada dos tribunais brasileiros. Ele segue e aperfeiçoa esses critérios.

Há acórdãos do STJ, pelo menos desde de 2008, que vêm colocando ou definindo esses parâmetros que são seguidos em relação ao acesso a dados armazenados no exterior, ou seja, não estamos tratando aqui de uma imposição de cima para baixo ou de uma legislação que, de uma hora para outra, impôs um modelo cujas consequências ainda estariam por vir. Na verdade, nós estamos neste tema aqui há cerca de mais uma década.

E em mais uma oportunidade - eu vou mencionar um pouco depois também -, na provação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o Congresso Nacional adotou critérios similares. Em mais de uma oportunidade da manifestação sobre esse tema, o Poder Legislativo Brasileiro manteve regras similares.

Há um outro ponto que nos leva a essa possibilidade de afirmar que os mecanismos legais de acesso a dados armazenados no exterior, ou seja, o MLAT, ou, quando atendidos determinados requisitos, a solicitação direta, convivem validamente no ordenamento jurídico. E, aqui, eu cito trecho

da manifestação da Advocacia Geral da União nos autos, ou seja, eles não são excludentes, mas, sim, complementares. Ou seja, o modelo adotado é, nesse sentido, também flexível, não impõe um procedimento rígido, não ignora a necessidade de eficácia e celeridade nos processos de aplicação da lei brasileira.

Então, estamos falando de equilíbrio nesse sentido também, na medida que, a depender do caso concreto, a depender da situação concreta, obviamente observados determinados requisitos, pode-se adotar um procedimento ou outro, ambos validamente incorporados ou admitidos pelo ordenamento jurídico nacional.

Quais são esses critérios? Eu não vou entrar aqui detalhadamente em todo eles, por uma questão de tempo, mas quero pontuar que, em todos os casos, estamos falando da legislação que é muito clara ao mencionar a coleta de dados em território nacional. Muitas vezes, estamos também tratando de condutas praticadas por usuários localizados no território nacional e também terminais - como esse critério complementar previsto no Marco Civil - localizados no Brasil, ou ainda que se trate de empresa estrangeira, empresa que oferece serviços ao público brasileiro ou possui uma subsidiária ou pessoa do seu grupo econômico com estabelecimento no país. Há aqui conexão substancial desses casos com a atuação do Estado Brasileiro, que possui, sim, o interesse legítimo para regular essas hipóteses e estabelecer

o procedimento, no caso de, quando atendidos esses critérios, o procedimento de solicitação direta dos dados.

E, como mencionei, a legislação de proteção de dados, que entra em vigor em agosto deste ano, ela é muito clara. Além de reproduzir critérios que são similares, que já haviam sido mencionados aqui, é clara ao adotar expressamente a menção ao fato de que a lei brasileira se aplica independentemente do país onde estejam localizados os dados.

Em resumo, os parâmetros jurídicos vigentes sustentam a aplicação ponderada da lei brasileira na internet, equilibrada, na medida em que, ancoradas no princípio da territorialidade - desde o começo estamos falando sempre de coleta de dados em território nacional, empresas que ofertam serviços ao público brasileiro, condutas praticadas no Brasil -, esses critérios, é importante ressaltar, eles impõem limites à atuação do Poder Judiciário.

Como falei, essa é uma jurisprudência consolidada. Esses critérios não conferem ao juiz, ou ao Poder Judiciário, ou às agências de persecução penal, a possibilidade de fazer o que bem entender. Parece-me que é justamente o contrário: são critérios relativamente objetivos que, inclusive, delimitam o âmbito de ação ou as hipóteses em que são admitidos os

mecanismos de solicitação direta, ou as hipóteses em que se admite o procedimento, ou é necessário procedimento de cooperação internacional.

Cito duas decisões para exemplificar esse meu último argumento.

No caso, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que foi negado o acesso direto a dados de usuário residente na Ilha da Madeira, em Portugal, expressamente mencionado nessa decisão, dizendo que não se pode admitir o fornecimento de dados relativos a usuários fora do território brasileiro, por se tratar de hipótese não prevista no art. 11 do Marco Civil, além de configurar afronta a soberania de outros países. Então, neste caso, aqui, seria, sim, segundo essa decisão, necessária a observância do procedimento de cooperação internacional.

Um outro exemplo, uma decisão do STJ, de 2019, agora de outubro de 2019, em que expressamente o Ministro-Relator deixa clara a convivência entre os mecanismos de solicitação direta ou os mecanismos de cooperação jurídica internacional, mencionando ali que há situações, em determinadas decisões judiciais, que não podem ser cumpridas sem que haja cooperação internacional. No caso, dados armazenados em dispositivos eletrônicos portáteis localizados no exterior.

Então, parece-me que a própria jurisprudência, a boa jurisprudência, ela vem estabelecendo também limites e uma aplicação ponderada desses critérios previstos na legislação brasileira.

Então, eu parto aqui para conclusão com uma citação de um trabalho recente que resume bem a fala, pautada por essa ideia de equilíbrio, de respeito a uma jurisprudência que foi consolidada ao longo de mais de uma década, consagrada pelo Poder Legislativo do Brasil em mais de uma ocasião, recentemente na Lei Geral da Proteção de dados, e a lerei agora para encerrar.

Em última análise, independentemente do modelo adotado, a adequada regulação da internet pressupõe uma mão firme e uma mente desapaixonada. A história já provou que tanto a inação quanto o excesso de ação podem ser prejudiciais para esse ambiente que é, de fato, sensível e frágil.

Então, essa é mensagem que queria deixar, nesse sentido de manutenção do equilíbrio, de manutenção de opções flexíveis que consigam atender tantas exigências de legitimidade, de um lado, quanto, de outro, a necessária eficácia e efetividade do cumprimento da lei no ambiente da internet.

É isso.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Muito Obrigado.

Eu cometi um equívoco, dizendo que o Doutor Lucas era o nosso último expositor para a manhã. Nós temos ainda alguns expositores.

Chamo o Doutor Carlos Affonso de Souza e o Doutor Christian Perrone, que dividirão o tempo de 15 minutos.

O SENHOR CARLOS AFFONSO DE SOUZA (INSTITUTO DE TECNOLOGIA & SOCIEDADE DO RIO - ITS RIO) – Bom dia a todos!

De início, uma saudação ao Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes e a todas as demais autoridades constituintes da mesa e aqui presentes para essa audiência pública.

É um prazer muito grande, em nome do ITS, poder fazer parte dessa audiência e, de forma cronológica, iniciar aqui uma série de exposições da academia e sociedade civil, nesse bloco e nos blocos que virão a seguir. Pareceu-me importante destacar o papel muito plural dessa audiência pública, muito destacado por um tema bastante controvertido. O número de expositores, às vezes, parece um tanto quanto intimidador, mas justamente nessa pluralidade que conseguimos alcançar um debate mais arejado, com soluções mais efetivas sobre o problema que aqui nos reúne hoje.

O ITS é um instituto que foi criado em 2013, mas é fruto do trabalho de 17 anos dos seus diretores, Professor Ronaldo Lemos, eu e o Professor Sérgio Branco, dedicando-nos muito a temas ligados à regulação da

internet, ao debate sobre direito e tecnologia no País. De forma específica para esse caso, nós atuamos, lá atrás, como coordenadores da equipe de pesquisadores, a qual foi comissionada pelo Ministério da Justiça para acompanhar a consulta pública feita através da plataforma do Marco Civil da Internet, acompanhando a criação do Marco Civil da Internet, como um todo. Nesse particular, gostaríamos de trazer algumas contribuições derivadas dessa nossa experiência e dos debates que temos observado nos fóruns sobre governança, sobre regulação da rede como um todo.

Partimos do pressuposto que falamos aqui de um momento de desmaterialização das provas, em que a prova não é mais um documento, um papel que esteja ancorado especificamente dentro de uma gaveta, em cima de uma mesa, mas que pode ser mais facilmente acessável.

O problema é saber quanto mais facilmente acessável pode ser e como isso também não pode prescindir dos devidos critérios e procedimentos para termos acesso justamente a essa prova.

Quando se fala muito em nuvem aqui, o *CLOUD Act* acaba sendo bastante mencionado, é importante que nós também possamos cortar um pouco a figura da da nuvem e desmistificar um pouco a figura da nuvem, entender que a nuvem está ancorada e traz em si a necessidade de procedimentos para termos acesso a esse conteúdo.

Existem, então, duas perguntas que precisam ser feitas: Qual é a lei aplicável ao determinado dado que será produzido e qual é o procedimento para ter acesso a esse determinado dado? E justamente ao fazer isso, sobre essas duas perguntas, caímos na discussão sobre o Marco Civil da Internet que aqui foi colocada.

Com essas duas questões - e, aqui, eu vou passar rápido pela redação do Marco Civil, porque já vimos bastante a redação do art. 11 -, é importante entender como o Marco Civil responde a primeira pergunta: Qual é a lei aplicável para acesso ao dado? É a lei brasileira. E essa resposta - acho que todos aqui concordamos - está clara no Marco Civil. O que se gera aqui de discussão é: Uma vez entendido que é a lei brasileira, qual é o procedimento adequado para ter acesso a esse dado? E, nesse ponto, o Marco Civil não responde. Esse procedimento não se encontra no Marco Civil e acho que aqui justamente aparece o nosso ponto sobre legislação, a lei aplicável, e a jurisdição e o procedimento para acesso desse dado. Esse ponto é importante, porque quando o Marco Civil fala em lei brasileira, parece-me que todos concordamos aqui que o MLAT, incorporado através do decreto, é lei brasileira. E inclusive pensando como o MLAT se relaciona com os demais instrumentos legais aqui colocados, acho que vale não apenas comentar que o próprio Marco Civil da Internet, no seu art. 3º, parágrafo único, menciona que os princípios ali

elencados não desconsideram os outros previstos em tratados que o Brasil venha a celebrar. Então, o próprio Marco Civil da Internet tem essa abertura para tratados que venham a ser celebrados. E, mais recentemente, eu chamaria a atenção para o fato de que a celebração de MLAT's também aparece no decreto publicado na semana passada, o decreto do Governo Federal que trata da Estratégia Nacional de Segurança da Informação. Lá, no Decreto nº 10.222, é dito que, ainda com relação a acordos bilaterais, o Brasil deve estimular a negociação de tratados de assistência jurídica mútua - MLAT's -, a fim de melhor combater os crimes cibernéticos quando se expandem além das nossas fronteiras. Então, é interessante perceber como a dinâmica do MLAT aparece inclusive como parte da Estratégia Nacional de Segurança da Informação.

E digo isso porque, ao trabalhar com essa nossa segunda pergunta, que é "qual é o procedimento para ter acesso a esses dados?", como já foi muito bem colocado, existe uma discussão no Judiciário brasileiro, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça, sobre a aplicação ou não do MLAT com julgamentos, com decisões que levam a diferentes conclusões - e aqui vão na tela apenas um desses casos; este é um caso no STJ em que se aplica o MLAT justamente em questões ligadas a dados envolvendo o seu armazenamento através da internet. Mas vale dizer que a aplicação do MLAT está espalhada por tribunais de todos os estados e, aqui, especificamente nos

casos de quebra de sigilo telemático, encontramos decisões aplicando o MLAT em São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Enfim, justamente para dar uma ideia de que temos aqui uma ampla discussão sendo feita no Poder Judiciário. Creio que vale a pena entendermos como o MLAT se relaciona com essas decisões e, olhando para frente, qual é a mensagem que o Supremo mandará sobre esse caso.

E aqui, acho que todo mundo concordando nos discursos que aqui me antecederam pela constitucionalidade do decreto que incorpora o MLAT, acaba se concentrando numa ideia de que a missão que é pedida ao Supremo nesta ação é uma missão extremamente focada: Decidir pela constitucionalidade ou não do decreto que incorpora o MLAT, numa audiência em que temos tamanha pluralidade de vozes, não deixa de ser importante aqui notar como existe uma concordância bastante manifesta aqui nos demais participantes desta audiência. Mas esse olhar sobre o MLAT no direito interno deve sempre andar lado a lado com as tendências internacionais, com as experiências internacionais; e, nesse ponto, queria pedir ao meu colega Christian Perrone que viesse explicar um pouco de alguma dessas experiências internacionais importantes para esse assunto.

Christian.

PROFESSOR CHRISTIAN PERRONE (INSTITUTO DE TECNOLOGIA & SOCIEDADE DO RIO - ITS RIO) - Muito obrigado!

Bom dia, Excelências! Faço minhas as palavras do meu caro colega Carlos Afonso e saúdo todos aqui presentes.

O meu nome é Christian Perrone, eu trabalho justamente com a área de Direito Internacional e novas tecnologias, e é nessa função que eu gostaria de comentar com senhores dois pontos importantes.

Primeiramente, como as soluções unilaterais previstas em leis nacionais não necessariamente resolvem todos os problemas. Elas são uma parte da solução dos problemas. E o segundo ponto é: como é necessária a existência de cooperação jurídica internacional para efetivamente trespassarmos a ideia de um possível conflito de leis no espaço.

Bom, já vimos aqui que esse não é um problema meramente nacional, não é um problema meramente do Brasil, é um problema que existe de acesso a dados desmaterializados, a provas, elementos de provas em outros países que perpassa diversos países do mundo.

Vamos comentar sobre dois exemplos ilustres nesse fato. O primeiro é o CLOUD Act, que já foi mencionado aqui, e o segundo é E-Evidence, que é um projeto da União Europeia para justamente dar vazão a isso.

O que essas soluções unilaterais nos dão? Elas propõem um instrumento, um procedimento específico, dentro dos países ou dentro da União Europeia, que possibilita esse acesso direto a dados que estão no exterior, mas não resolve o problema quando nós temos uma lei em outro país que impede esse acesso. E não é como se esses instrumentos unilaterais não se dessem conta disso. Na realidade, eles reconhecem a ideia de um conflito potencial de leis. Por exemplo, no caso CLOUD Act, ele tem uma defesa para empresas que estão submetidas a outras jurisdições e que são obrigadas a não entregar esses dados, elas podem questionar a ordem que peça a entrega desses dados. Já no caso da E-Evidence, eles não somente fazem isso, como também reconhecem que muitas vezes as empresas não estão dentro do mercado comum europeu, e, por isso, na diretiva, na proposta, ela estabelece a necessidade de uma regulação, de um representante dessas empresas cujas sedes estão no exterior dentro da União Europeia, mais ou menos como casos similares que acontecem em diversas situações aqui no Brasil.

Contudo, isso também não solve a questão do nosso possível potencial conflito de leis, e eles também reconhecem que não solve. O que acontece em um CLOUD Act, por exemplo? Ele permite, autoriza ao Presidente norte-americano até acordos que vão além da rede do MLAT, que nós estamos discutindo aqui, e, ao mesmo tempo, na E-Evidence, nesse projeto

da União Europeia, os países da União Europeia instruem a comissão da União Europeia a iniciar um procedimento de acordos internacionais. Ou seja, mesmo com a possibilidade de soluções unilaterais, eles também reconhecem a necessidade de acordos internacionais para trespassar esse potencial conflito de leis.

Esses só são modelos que o Brasil pode seguir caso queira realmente também ter uma solução unilateral parecida com esses países, mas as soluções podem ser de outras formas, e é disso que o meu colega agora vai tratar.

O SENHOR CARLOS AFFONSO DE SOUZA (INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO RIO - ITS RIO) - Muito rapidamente, só para encerrar o ponto de nossa fala, acho que é importante entender a necessidade de cooperação internacional sobre esses temas. E, nesse ponto, julgo que fiquei muito contente em ver a fala do MCTIC terminando com a menção ao relatório do *Internet and Jurisdiction* - jurisdição e internet no mundo como um todo -, porque o ITS tem uma demanda para esse ano para construir o relatório de *status* regional sobre internet e jurisdição na América Latina e no Caribe.

O *Internet and Jurisdiction* é uma rede multissetorial de agentes, incluindo a academia, o governo, sociedade civil e empresas, que

procura explorar formas de entender como três pontos nevrálgicos do debate sobre jurisdição e internet seguem adiante. O primeiro é acesso a dados transfronteiriços, o segundo é remoção de conteúdo, que tem impactos extrafronteiras, e o terceiro é a governança de nome de domínio.

Especificamente, no que diz respeito ao acesso a dados transfronteiriços, parece-me que essa audiência é justamente um local privilegiadíssimo para entender os contornos da legislação brasileira e como ela se aplica justamente nessa discussão, nesse debate, sobre acesso a dados que extravasam as fronteiras brasileiras; e esperamos entregar esse relatório no final do ano, e que ele faça menção justamente aos trabalhos aqui construídos, a partir desta audiência.

Bom, como último recado, para garantir que economizaremos um pouquinho do nosso tempo, acho que só vale a pena comentar, no final dessa nossa apresentação, que, se é verdade que a nossa fala leva em consideração a questão de que: 1) o MLAT é legislação brasileira; 2) que o decreto que incorpora o MLAT é constitucional; 3) que existe uma necessidade de cooperação internacional para que possamos levar adiante essa discussão com respeito às legislações dos diversos países envolvidos. É importante entender, aqui, que a internet é uma infraestrutura globalmente compartilhada e que as leis precisam também por vezes se adequar a um

princípio que parece muito próprio de tecnologia da informação de TI, que é a interoperabilidade.

Nós não estamos muito acostumados a trabalhar com interoperabilidade, como necessariamente sendo um princípio jurídico, muito mais facilmente o encontramos na literatura sobre Tecnologia da Informação, mas o tema de internet e jurisdição nos força justamente a olhar para esse momento em que a interoperabilidade de leis será fundamental, nesse sentido, para garantir que tenhamos um respeito as diferentes legislações e que se possa criar efetivamente um ambiente de cooperação internacional.

Vivemos uma época de nacionalismos em cima de uma rede, que é efetivamente uma rede global, e essa fratura, é claro, que gera efeitos que são importantes para o Direito. E esperamos que esta Corte possa, justamente, na restrita missão que lhe é dada dentro de uma ADC, oferecer espaço para que um debate global, como este, possa acontecer.

Mas, parece-me - e aqui encerrado - que essa é uma decisão de meio de caminho. Tendências internacionais mostram que o Brasil, com o encaminhamento de sua adesão à Convenção de Budapeste, caminha numa direção de que este assunto será fatalmente resolvido em algum período breve de tempo. Mas é nessa missão, em meio de caminho, parece-me que o Supremo dá um passo muito positivo ao gerar aqui o foro para esta Audiência.

Com isso agradeço.

Obrigado!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado! Agora, com a palavra a Doutora Jacqueline de Souza Abreu.

A SENHORA JACQUELINE DE SOUZA ABREU (PROFESSORA PESQUISADORA) - Excelentíssimo Senhor Ministro, eminente representante do Ministério Público Federal, demais servidores, colegas e participantes. Bom dia!

Gostaria de começar agradecendo o convite para participar desta Audiência, parabenizando também o Supremo Tribunal Federeal pela abertura ao diálogo e registrando que eu falo aqui, hoje, exclusivamente da minha capacidade pessoal, enquanto pesquisadora.

Particularmente, as observações que eu faço aqui são reflexos do meu mestrado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e da minha experiência, enquanto coordenadora de pesquisa no *InternetLab* há dois anos atrás, quando eu tive a oportunidade de participar de diversos foros internacionais sobre esse tema, inclusive coordenar a elaboração de uma petição de *amicus cure* para a Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso, *Microsoft-Ireland*.

Nesta breve contribuição, gostaria de retomar as circunstâncias que nos levaram a essa controvérsia e as premissas que não podemos ignorar nem abandonar ao pensar adiante em respostas e soluções para ela.

Os mecanismos de cooperação internacional surgiram para lidar com situações nas quais as autoridades públicas de um Estado esbarram nos limites do seu poder. A identificação dessas situações, dessas ocasiões, é bastante clara quando nós estamos falando de meios físicos, como já foi dito aqui. Se as autoridades do "País A" precisam ouvir pessoas ou obter materiais que estão fisicamente localizadas no "País B", o "País A" simplesmente não pode ordenar que suas autoridades policiais ingressem no "País B", para fazer uma busca e apreensão sem causar um baita de um incidente diplomático.

Essa dinâmica de uso de MLAT's assumiu contornos ainda mais complexos com a internet, porque os documentos digitais, como já foi dito aqui, possui uma natureza intangível. Ou seja, ao mesmo tempo que eles estão de fato localizado na forma de *bits*, em algum servidor ou lugar no mundo, eles podem também ser acessados virtualmente de qualquer outro lugar. E, também, as pessoas que controlam essas informações e detêm o poder sobre esses servidores estão presentes multinacionalmente, seja através de sua sede, de subsidiárias ou simplesmente virtualmente.

Neste contexto, o que a internet faz é recolocar a pergunta sobre quando e em que circunstâncias um país está obrigado, pelo Direito Internacional, a adotar a via diplomática para aplicar a sua lei e executar essas decisões.

Como é que eu sei quando eu preciso acionar essa cooperação internacional agora na internet? O que vale olhar? Para o local de armazenamento atual dos dados que estão sendo requeridos, ou o local em que existiu a coleta original dessas informações, ou o local onde serão fornecidos para as autoridades, ou o local da sede do controlador? Enfim, o que é que conta, então, para me dizer quando é que um Estado esbarra nos limites do seu poder e precisa de um MLAT na era da internet.

A natureza aterritorial de dados, como diz a professora Jennifer Daskal, e também a existência desses diversos elementos de conexão para dados eletrônicos faz com que também a proteção legal conferida a essas informações, a esses dados, seja suscitada simultaneamente por diversos países. Então, dados podem ter sido coletadas aqui no Brasil, mas estarem armazenados em servidores na Suécia e ser controlados por empresas americanas. Isso atrai simultaneamente a legislação dos três países. Isso complica ainda mais o cenário e nos leva à constatação de que, quando estamos pensando na internet, de um território que é virtual, eu preciso de um MLAT

ou de algum tipo equivalente de cooperação internacional não mais porque eu estou esbarrando nos limites do meu poder, mas porque facilmente posso esbarrar nos interesses legítimos de um outro Estado.

Nesse sentido, a internet e a multiterritorialidade dos dados que eu estou chamando aqui agora fazem com que tenhamos um desafio diferente, o desafio de determinar não só quando preciso de um MLAT porque esbarrei no meu poder, mas quando preciso dele porque ele é o único canal diplomático disponível para que se respeite e acomode interesses legítimos de outros Estados soberanos.

Nós estamos diante de uma versão desse dilema aqui hoje, o Marco Civil da Internet, como já ouvimos, aplica-se a provedores de aplicações que operam serviços e coletam dados no Brasil. Ele também prevê mecanismos e procedimentos de requisição para o fornecimento desses dados às autoridades no Brasil. A legislação americana, por sua vez, faz a mesma coisa, ela se aplica a provedores de aplicações sediados nos Estados Unidos, protege os dados que são controlados por essas empresas e também prevê, a sua própria maneira, os mecanismos de quebra de sigilo. E, como já ouvimos aqui, segundo a interpretação de muitos, essa legislação proíbe o fornecimento direto a autoridades estrangeiras de dados controlados por essas empresas.

Como é que nós lidamos, então, com essa situação em que existe um conjunto de dados que parece estar simultaneamente sujeito à dupla jurisdição? A brasileira e a americana, cada uma direcionando a respostas completamente diferentes para situação em que uma autoridade brasileira requisita conteúdo de comunicações?

Eu faço aqui esse breve comentário entre parênteses, porque hoje estamos discutindo a legislação americana, mas poderíamos estar muito bem discutindo a legislação europeia que, no seu Regulamento Geral de Proteção de Dados, por exemplo, impôs recentemente um elevadíssimo nível de proteção e de exigências para transferências internacionais de dados para todo e qualquer tipo de dado pessoal, não só conteúdo de comunicações, e que impõe o mesmo tipo de bloqueio para transferências internacionais se certas condições não forem verificadas.

Mas voltando à questão de hoje aqui: qual é a resposta então do Direito Internacional Público para o fenômeno da dupla jurisdição? Como é que vou saber quando eu preciso de cooperação internacional nesses casos?

Se essa resposta fosse fácil, não estaríamos aqui.

E o que eu entendo hoje, aqui, a nossa certeza é que, na verdade, ela está para ser consolidada ainda internacionalmente, e o que nós estamos fazendo faz parte desse esforço.

Como já foi dito aqui também, em diversos foros de discussão, tem se reconhecido a razoabilidade em tese da ideia de que, quando um país tem um nexo muito forte com um caso, ou seja, em razão da localização do crime, da nacionalidade do suspeito e da vítima, e quando a sua legislação nacional contém níveis adequados de respeito ao devido processo legal e a outras garantias fundamentais, deveria ser possível, faz sentido normativamente que esse país possa ter, mediante requisição direta, acesso a dados, sem precisar optar pela via diplomática.

Nesses mesmos foros, como também já foi destacado pelos meus colegas, discutem-se que esses mecanismos em que provedores possam questionar ainda assim requisições diretas e existir a via diplomática, quando houver indícios de que o usuário possui um vínculo forte com um país terceiro, ou quando ainda permaneça um risco de se violar a legislação de um outro país, tem-se tentado chegar então a um novo sistema, um novo regime internacional que facilite requisições diretas de dados entre autoridades e empresas, autoridade de um país e empresas de outro, mas que, ainda assim, contenha garantias do devido processo legal, que preserve os direitos humanos e acomode interesses de diferentes países. O que hoje é assegurado pelo MLAT e que é algo que nós precisamos manter.

Dito isso, o fato é que o Brasil não pode se autocredenciar num sistema que autoriza requisições diretas. E eu falo isso porque, na minha humilde opinião, entendo que o Supremo Tribunal Federal deve ser cauteloso quanto à tese que vai afirmar aqui, exatamente por isso.

A conclusão de que a legislação brasileira autorize autoridades a fazerem requisições diretas, em certos tipos de ocasiões excepcionais, a partir de determinados critérios, não impediria que qualquer outro país do mundo, inclusive aqueles com poucas tradições democráticas e baixo apreço a direitos humanos, também, a partir do seu próprio conjunto de critérios, fizesse a mesma coisa.

Qualquer que seja a solução aqui, então, ela não pode ser uma que sustente a noção de que é possível ignorar coincidente de jurisdição, ignorar conflitos de lei, ou mesmo, mais fundamentalmente, a noção de que isso é um problema que pode ser resolvido unilateralmente. Não é!

Para não alimentar essa corrida do "salve-se quem puder" ou "do cada um por si, custe o que custar" em busca de dados e que acarreta um perigo global, sim, à privacidade, à liberdade de expressão e à inovação na internet, o Brasil deve se engajar com essas iniciativas que buscam uma saída conjunta e dialogada para esse problema, e que já foram mencionadas aqui. Isso pode se dar no âmbito do CLOUD Act, no âmbito de discussões à

Convenção de Budapeste, ou ao seu segundo protocolo adicional, e a outras iniciativas que procuram agilizar o sistema MLAT.

Através desses mecanismos, o Brasil terá a chance de se habilitar internacionalmente como país comprometido com os direitos humanos e o diálogo entre as nações, oferecendo canais ou participando de canais que lidam de forma muito mais satisfatória, saudável e duradoura com o problema que estamos enfrentando hoje.

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Agora, sim, o último expositor da parte da manhã, Doutor Walter Faiad.

O SENHOR WALTER FAIAD (INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC) - Muito obrigado, eminente Presidente!

O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, lisonjeia-se com o convite, reforçando a aumento da pluralidade em debate desta Audiência Pública. O IDEC tem trinta e três anos de atuação, em nível nacional e internacional, na defesa dos interesses do consumidor.

Saúdo, já neste agradecimento, o eminente Presidente destes trabalhos pela abertura de voz ao IDEC, assim como estendo esse cumprimento a todos os representantes da Mesa dos trabalhos, inclusive ao

representante do Ministério Público Federal, e todos colegas que estão aqui ladeados nesta exposição, nas pessoas dos meus professores Ayres e Francisco Rezek e do ilustre Ministro-chefe da AGU.

O IDEC agradece, eminente Presidente, à sensibilidade de colocação no despacho que convocou dos temas de Vossa Excelência a noção de que pode haver uma possível diminuição do nível de proteção do direito fundamental à privacidade dos consumidores de serviços de *internet*.

Parece-me que, das tensões que se apresentam nesse debate, era o debate que parece simples, mas, na verdade, vai ganhando, cada vez mais, vultos de complexidade, até porque as falas aqui se complementam, mas não se repetem. Mas o fato é que, entre as cordas de tensão, entre as pinças da grande prensa, que vão exprimir o resultado dado pelo Supremo Tribunal Federal, estou eu aqui a tentar vocalizar quem sou o titular dos dados. Até agora, desde a primeira fala até a que me antecedeu, eu estou com o pesado problema de tentar vocalizar o que diz o cidadão.

O IDEC representa consumidores, e a definição de consumidor, no Brasil, está muito ligada a contribuinte e também a cidadão. Qualquer um dos constitucionalistas que me repreendam, mas, na prática, estou aqui a falar pelo cidadão.

O cidadão tem duas vertentes de imagem. O IDEC pede desculpa por não ter dado empírico preparado até então, mas o preparará em virtude dos debates. A percepção do cidadão nesse aspecto tem cabeça de Juno, ela vai para dois lados, e eles se encontram. O primeiro deles é que o IDEC tem interesse no reforço do combate aos crimes praticados em meio virtual, porque o cidadão também é vítima, ou é a vítima dos crimes cibernéticos.

Então, seja pelo MLAT ou seja pelo acesso que se tenha a dados que blindam, que dão anonimato a criminosos, inclusive, das relações de consumo - lembrando que os crimes contra as relações de consumo também estão na legislação material norte-americana -, o IDEC tem interesse, inclusive, quem sabe, eu não tenho os dados concretos do Ministério da Justiça, mas, por exemplo, o PROCON venha a investigar ou a pedir dados armazenados em equipamentos de *storage* estrangeiro, no caso norte-americano. Então, isso é novidade a que o IDEC não tem acesso. Mas o que é comum ao IDEC é a quantidade de reclamações de consumidores que são vítimas de crimes nas relações de consumo - daí a atuação do IDEC - e que têm uma dificuldade tremenda de acesso a esses dados.

Então, essa é a primeira perspectiva; e, nela, eminente Ministro-Presidente, por incrível que pareça, eu, com o papel de contribuinte, fico entristecido com o ajuizamento da ação, dada a incapacidade do poder de

se auto-harmonizar em relação a esse tema. Parece-me que essa questão, com todo o respeito às partes autoras, seria mais de um arranjo político, institucional e administrativo, uma nova rodada de negociação. Tem reclamação para todos os lados, nós é que sustentamos esse debate, a grosso modo, e me parece que sobrou para o Supremo Tribunal Federal dar o Direito no que me parece que poderia ser uma nova rodada, um novo ajuste, e me parece que os canais não judiciais seriam canais bastante possíveis, tanto é que foi tentada herculeamente uma audiência de conciliação entre as partes, embora não tenha havido resultado. Mas me parece, como cidadão, estar próximo, porque as convergências de ideias são grandes.

O que me chama a atenção como cidadão que move a máquina, que paga pela máquina: as definições de eficiência e eficácia são bastante distintas administrativa ou gerencialmente.

O fato é que o tempo é apenas uma das facetas da efetividade. O que é efetivo é rápido, mas não necessariamente apenas rápido. Há coisas que são rápidas, mas também são não efetivas, porque caem no campo da ineficácia.

O ponto objetivo a que eu quero chegar é a segunda faceta de observação do consumidor. O consumidor quer investigação, para se sentir seguro, mas também quer consumir serviço de internet, de transmissão dos

seus dados pessoais com segurança. E esse debate ascendeu para uma assimetria entre a distinção entre a proteção que um consumidor norte-americano tem sobre os seus dados de internet, que estão armazenados em determinado provedor de acesso, e a que o cidadão brasileiro tem.

Uma simples fala retórica de que a proteção à privacidade é a mesma entre Brasil e Estados Unidos não me convence. Ela precisa de um dado empírico. Talvez, academicamente, precisaríamos medir e ter um indicador para isso, e aí entrariam percepções subjetivas e objetivas, além das normativas.

O que a gente fecha como observação contributiva, além da pesquisa empírica que faremos, diz respeito com o cidadão. Qualquer que seja o provimento jurisdicional final na definição constitucional do tema, olhem para o cidadão, que tem a cabeça prensada no meio das forças. Vejam se não estamos vivendo em dois mundos, com os pés em um país em que nós temos uma ânsia investigativa, que abre os dados, e talvez isso pode ser algo a ser percebido, uma noção de insegurança, dado o excesso de quebra do acesso a dados sensíveis. O Supremo já se debruçou agora sobre a Receita Federal. Atira-se no que parece que é visto e acerta-se no que não é. Existe uma massa de consumidores que é vítima de uma talvez coisificação, de um infeliz avanço. Isso pode acontecer, isso tem que ser visto.

Então, o aprimoramento de instrumentos como o MLAT não é apenas um sinal de falta de arranjo institucional para acesso de dados no estrangeiro, mas também uma oportunidade de o cidadão se sentir seguro nas suas operações e transações bancárias, dados prestados à autoridade da Receita Federal. Óbvio, ao fim ao cabo, o que eu quero é transmitir meu dado de internet de modo seguro. O cidadão também quer isso, ele quer ordem, mas ele quer a proteção dos seus dados de modo que não seja vítima de abuso.

Está aí o Legislativo tratando dos dois temas. Nós esperamos que, antes da solução deste julgamento, haja um arranjo institucional que traga uma solução, ao final, de maior segurança, para o cidadão brasileiro, quanto aos seus dados de privacidade em níveis, inclusive, internacionais.

Eu peço desculpas pelo excesso de tempo e devolvo a palavra a Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado!

Agradeço a todos os participantes da audiência pela manhã.

Eu gostaria de dirigir duas perguntas aos requerentes. A primeira pergunta aos requerentes é se poderiam esclarecer, de forma mais clara, sobre as sanções que podem ser aplicadas em virtude de requisições

diretas de autoridades nacionais a servidores de comunicação existentes nos Estados Unidos, e se houve casos concretos em que essas sanções foram aplicadas por autoridades americanas ou outras autoridades estrangeiras.

O SENHOR PROFESSOR DOUTOR TODD HINNER (ASSESPRO NACIONAL)* transcrição feita com base em tradução simultânea - Meritíssimo, muito obrigado pela pergunta. Há, sim, casos nos Estados Unidos. Primeiro, friso que há uma disposição prevista em lei que dispõe sobre sanções aplicáveis no caso de violação do SCA. E há também casos que sustentaram esse mecanismo de sancionamento previsto em lei.

Além disso, as leis sobre privacidade podem ser também invocadas nos Estados Unidos e serem aplicadas no caso de divulgação que venha a violar o SCA. E acredito eu que um dos depoentes hoje à tarde, o Professor Albert Gidari, tecerá comentários extensos acerca desses casos. De modo que, em vez de absorver mais tempo do Tribunal sobre esse tema, neste momento, talvez, deixo a cargo do Senhor depoente Gidari tratar da questão mais oportunamente.

Agradeço.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Uma outra questão também aos requerentes. Como eles vislumbram a questão da adoção de instrumentos simultâneos, mencionada pelos órgãos públicos

hoje na sessão da manhã, ou seja, o auxílio direto em conjunto com a requisição via MLAT?

O SENHOR FRANCISCO REZEK (ASSESPRO NACIONAL) - Senhor Presidente, ouvimos, na manhã de hoje, diversas referências de autoridades do Poder Executivo e do Ministério Público a outros meios de cooperação internacional neste domínio que poderiam perfeitamente funcionar em paralelo com o tratado.

Eu não sei se as atitudes tomadas por algumas autoridades judiciárias brasileiras, de constrangimento até físico, senão financeiro, de integrantes da empresa brasileira afiliada, por conta de não poder essa empresa oferecer dados de que sabidamente ela não dispõe. Eu não sei quais seriam esses meios paralelos. Eu não sei quais são as outras formas de cooperação a que se referiu o Ministro Moro, por quem a minha estima pessoal é ilimitada, mas eu sinceramente não sei. Falam em alternativas ao MLAT, alternativas de cooperação no eixo Estados Unidos da América/Brasil e não dizem quais são.

A alternativa seria essa conduta escoteira, em absolutamente arbitrária, de juízes que punem a empresa brasileira por não poder oferecer dados de que ela efetivamente não dispõe? Eu não sei. Fico devendo a resposta a Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Os dados apresentados pelo Ministério da Justiça apresentam um baixo - indicam pelo menos - grau de cumprimento dos pedidos de interceptação telemática de comunicações eletrônicas em servidores localizados nos Estados Unidos. Em torno de 20%, foi isso que se falou. Aponta ainda para demora em média de 10 meses para obtenção de resposta. Há um caso em que isto teria tido uma demora ainda muito mais expressiva.

Eu pergunto, então, aos representantes do Ministério da Justiça - e perguntaria ao Ministro Moro que está ausente - e também aos americanos, aos representantes dos Estados Unidos, se fosse o caso, quais seriam as causas desse baixo grau de atendimento às solicitações brasileiras e de que forma esses pedidos poderiam tramitar de forma mais rápida e eficaz?

MARCONI COSTA MELO (DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA NACIONAL) - Muito obrigado, Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, pela pergunta.

Digamos, o diagnóstico é esse: nós vemos aqui nos pedidos de cooperação, em geral, o índice de efetividade da cooperação que se obtém é muito mais alto quando comparado com a efetividade existente para dados telemáticos.

E uma das razões pelas as quais esse fator ocorre foi objeto da apresentação que fizemos, que é justamente a verificação das razões pelas quais essa efetividade não ocorre. O que se observa, em muitos aspectos, é que isso tem a ver com a própria legislação americana, de certa forma, mas também pela forma como a legislação americana, neste caso, é aplicada.

Digo isso, porque, em muitos casos, e talvez seja o primeiro dos exemplos da legislação americana, um tribunal americano pode fazer essa solicitação de quebra de sigilo telemático de acordo com os critérios pré-estabelecidos. Mas, no caso de jurisdições estrangeiras, esse processo é mais, digamos, exigente e demanda maior tempo também para que possa ser executado.

Um outro aspecto que não podemos deixar de mencionar é que esse mesmo problema não é um problema brasileiro, não é um problema nacional; isso impõe que a quantidade de pedidos desse mesmo tipo leva a que as autoridades americanas tenham que executar diversos pedidos de cooperação, ou seja, levar todas essas demandas aos tribunais americanos, em nome do Estado estrangeiro justamente para obtenção da informação. E isso obviamente impacta na capacidade dos Estados em prestar cooperação nessa matéria.

Então, esses são talvez alguns dos elementos mais importantes. Agora, remarcar, nós temos excelente relação com as autoridades estadunidenses. Estamos sempre buscando entender e interpretar a legislação americana a fim de conseguir melhorar a capacidade dos tratados internacionais nessa matéria, do funcionamento do MLAT. Mas, infelizmente, ainda estamos longe de obter um resultado satisfatório tanto em relação à taxa de comprimento, quanto em relação a tempo.

Espero ter respondido e à disposição para qualquer outra indagação.

O SENHOR CALOR AYRES BRITTO (PRESIDENTE DA ASSESPRO NACIONAL) - O MLAT, em diversas passagens, prioriza a sua própria aplicabilidade. Fala até em atendimento no prazo máximo, com o máximo de presteza em várias oportunidades.

Se o problema é de morosidade, de complexidade, que se adite um documento, que se aperfeiçoe o documento, porque o fato é que o art. 181 da Constituição - interessante, ninguém fala desse art. 181, eu falei -, ele exige que a requisição de documentos, a prestação de informações à empresa se faça de autoridade para autoridade, e não por forma direta. Pré-exclui a cobrança direta à empresa de dados, que, já sabemos, não estão ao dispor

sequer da empresa de internet, seja de conexão, seja de aplicação de internet aqui no Brasil.

Então, se o problema é esse, que se aperfeiçoe o documento, o MLAT, ou que se o denuncie unilateralmente como imprestável, como ineficiente, como inefetivo.

É como penso, Excelência.

O DOUTOR ERIC HOLDER (FACEBOOK)* transcrição baseada em tradução simultânea - Obrigado meritíssimo, como ex-procurador geral do Departamento da Justiça, entendo as impressões e percepções dos meus colegas de investigação criminal aqui no Brasil.

A resposta, no entanto, não consiste em, caso a caso, obrigar uma empresa a cumprir uma requisição que é incoerente com a lei que rege as ações de tal empresa. Não é, aí, que reside a resposta.

Vivemos em duas grandes democracias e, em muitos aspectos, tal requisição que possa obrigar a empresa atuar de modo incoerente com as leis de seu país pode parecer, em certos aspectos, benigna. No entanto, se recuarmos e examinarmos o mundo como um todo, observaremos que há regimes opressivos, que não estão comprometidos com o Estado Democrático de Direito. E se permitirmos que tal ato ocorra entre grandes democracias, como as nossas, será cada vez mais difícil proteger as liberdades civis, direitos

humanos e as empresas que operam ou atuam em tais ambientes. É necessário, faz-se necessário tornar esse processo mais funcional. E, acredito eu, as respostas exigem que essas duas grandes nações nossas se reúnam e convirjam rumo a soluções que possam, de certa forma, modificar, emendar os MLATs, considerando as alternativas existentes, o CLOUD Act, por exemplo, e examinar modos como o SCA possa se tornar mais receptivo e aberto às necessidades legítimas das pessoas que atuam na comunidade de investigação penal. A resposta, no entanto, não pode ser obrigar, compelir uma empresa, como disse, a fazer algo que seja incoerente com as leis que regem sua conduta.

Obrigado.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Uma última consideração que agora dirigiria aos representantes americanos. A aprovação do CLOUD Act pelo Congresso Norte-Americano, em 2018, foi criticada por entidades lideradas pela União Americana pelas Liberdades Civis, que chegaram a alegar que a lei permitirá o compartilhamento de dados com Estados que violam direitos humanos, além de possibilitar que tais governos tenham acesso aos dados armazenados nos Estados Unidos, sem que um acordo mútuo seja tratado pelo Congresso.

A lei também é criticada pelo fato de a sua tramitação, na Câmara e no Senado, não ter contado com um grande debate público. Considerando esse contexto, pergunta-se:

Qual a sua posição sobre essas críticas dirigidas ao CLOUD Act? Além disso, seria oportuno ouvir a opinião sobre os critérios previstos no CLOUD Act para contestação dos pedidos de compartilhamento, em especial a lei prevê que o provedor de acesso à internet não estará obrigado a divulgar os dados quando houver risco de violação da lei do país onde o dado está armazenado. Como esse critério pode ser examinado, de forma eficiente, nos eventuais acordos executivos firmados com base no CLOUD Act?

O SENHOR PROFESSOR DOUTOR TODD HINNEN (ASSESPRO NACIONAL)* transcrição baseada em tradução simultânea - Tratarei cada uma de suas perguntas brevemente. No que se refere aos direitos humanos, o CLOUD Act contém, como pré-requisito para a celebração de um acordo executivo, a conformidade, o cumprimento com o devido processo de lei e os direitos humanos. Parte do processo de tratativas ou negociações entre dois Estados soberanos, antes de se celebrar um acordo, no âmbito do CLOUD Act, tem por objetivo garantir que tal observação de direitos humanos e liberdades civis se façam reais. Nesse sentido, espera-se que o CLOUD Act será a causa para elevar o sarrafo, por assim dizer, ao nível de atendimento às

exigências dispostas no CLOUD Act, para tanto, outros países passarão a inspecionar os seus próprios sistemas de justiça e registro histórico em direitos humanos e Estado de Direito, de modo a elevar o seu padrão e estar em conformidade com o acordo no âmbito do CLOUD Act.

No que se refere a se há debate público adequado antes da adoção do CLOUD Act, se houve tal debate, essas questões foram, sim, debatidas, vêm sendo discutidas há décadas nos Estados Unidos. O debate prossegue após a promulgação do CLOUD Act. Embora a Lei do CLOUD Act, *per se*, tenha sido objeto apenas de algumas poucas audiências públicas, o fato é que os princípios e os fatores que informam essa peça legal têm sido objeto de discussão já há muito tempo nos Estados Unidos.

Por fim, diria eu que a meta, o propósito do CLOUD Act consiste em eliminar obstáculos ao compartilhamento de informações. Se o efeito consiste em remover a proibição contida no SCA sobre o que tanto falamos e eliminar, remover a proibição contida na lei sobre interceptação, de modo que provedores americanos possam compartilhar mais eficaz e mais eficientemente dados com governos estrangeiros, é necessária uma relação governo a governo. Acredito eu que o atraso, o retardo, reside fora desse panorama por completo e permite ao governo, tal como o governo do Brasil,

por exemplo, recorrer diretamente ao provedor desse serviço americano e dele exigir, ou solicitar, que esse provedor responda a uma ordem judicial do Brasil.

Obrigado, Meritíssimo.

DOUTOR ERIC HOLDER JR. (FACEBOOK)* transcrição baseada em tradução simultânea - Acrescento apenas brevemente àquilo que o Senhor Hinnen disse que há critérios contidos no Act, na lei, que os países precisam atender para serem elegíveis a considerações de recursos ao CLOUD Act. Não tenho qualquer dúvida de que o Brasil estaria em condições e atenderia bem esses critérios.

Há também outra coisa que Meritíssimo Juiz mencionou sobre a participação do Congresso. Uma vez que o Poder Executivo do nosso governo alcance um acordo com um homólogo de outro país, como há pouco alcançamos com o Reino Unido, há um período de tempo em que o Congresso americano tem a possibilidade de reexaminar o acordo e declarar satisfeitos os critérios. Para ser muito franco, acredito que não todos os países do mundo atenderão aos critérios aplicados, porém não tenho dúvidas de que, mediante tratativas, negociação e acomodação de meio termo, o Brasil e os Estados Unidos poderão efetivamente alcançar um acordo ancorado no CLOUD Act.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Agradecendo a presença de todos os representantes aqui já mencionados que

participaram desta parte da audiência, nós encerramos a sessão da manhã e vamos dar continuidade às 14 h.

SEGUNDA PARTE - TARDE

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Declaro reaberta a sessão da Audiência Pública. Agora dando continuidade ao grupo academia e sociedade civil, nós começamos como o Professor Doutor Victor Doering Xavier da Silveira.

O SENHOR VICTOR DOERING XAVIER DA SILVEIRA (CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS) - Boa tarde a todos e todos! Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, que preside essa sessão! Boa tarde, colegas e representantes da sociedade civil da academia, autoridades aqui presentes! Boa tarde, em especial, ao ex-Ministro Ayres Britto, ex-Ministro Francisco Rezek, representando aqui a parte proponente.

É um prazer e uma honra estar aqui, sem dúvida, participando dessa oportunidade única de contribuir para esse tema, em nome do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas.

Aqui, nós temos um - eu posso dizer com toda certeza - dos maiores privilégios, nós temos, é justamente compartilhar um pouco da nossa

perspectiva, compartilhar um pouco da sua experiência, com o tema de direito em tecnologia e sociedade.

Em especial, no CEPI, temos nos deparado, em nossas pesquisas, com temas muitos caros a governança da internet, governança de dados, e a remoção de conteúdos em searas que tem se mostrado especialmente problemáticas e complexas com, inclusive, notícias falsas, discurso de ódio. Então, acredito que essa é uma bela oportunidade de passar um pouco dessa experiência e participar um pouco dessa discussão aqui com este egrégio Tribunal e perante a sociedade civil.

Pois bem. Eu posso começar dizendo que eu acredito que o debate em vigor, não especificamente o debate travado nesta audiência pública, mas muito do debate público que se tem feito a respeito do tema, em muitos espaços, em muitos fóruns, tem se dado a partir de uma falsa dicotomia. Uma falsa dicotomia que aparece muito nesses temas, e principalmente em questão de dados, que é justamente a falsa dicotomia entre privacidade e segurança. A falsa dicotomia costuma tratar privacidade e segurança como valores, bens, opostos, às vezes, inconciliáveis, que teriam necessariamente de ser afastado um em benefício do outro, ou seja, um deles sempre sofrer com isso.

E quando se trata do armazenamento de dados pessoais de usuários de internet em territórios sob jurisdição estrangeira e dessa necessidade de obter, de seguir um procedimento para se obter acesso a esses dados, esse tema volta.

O Ministro Sérgio Moro começou, levantou a perspectiva de que o debate que se faz aqui não é sobre privacidade, com todo respeito, eu discordo disso, assim como alguns dos meus antecessores aqui, que participaram dessa audiência pública, eu discordo um pouco dessa perspectiva. Eu acredito que temos uma discussão muito interessante sobre privacidade que precisa ser travada aqui.

Por quê? Justamente porque quando falamos sobre privacidade e segurança, estamos falando no fim das contas sobre, na verdade, estamos falando sobre produção de dados como um meio para se garantir segurança, não para se tirar. Estamos falando de segurança de usuários. Estamos falando de segurança dos dados dos usuários e de prover condições estruturais para que os usuários possam ter a garantia de que seus dados não serão invadidos, violados indevidamente, que o uso deles não será desviado para outras finalidades, por agentes públicos ou por agentes privados.

Então, o argumento é falho. A ideia de que segurança e privacidade são ideologicamente opostos é falha justamente por conta disso.

Quando entramos nessa seara, estamos discutindo privacidade com uma forma, como um bem que, em última instância, garante a segurança dos usuários, a segurança da informação.

Em parte do debate público que se faz sobre esse tema específico, a interpretação que se parece fazer, muitas vezes, é de que empresas estariam enviando dados de usuários para fora para jurisdições com regime de proteção de dados mais restritivo, mais protetivo e que estaria impedindo investigações criminais e, portanto, facilitando atividades criminosas, atividades ilícitas, como se estivesse falando de paraísos fiscais de produção de dados. Existe um pouco de senso comum que parece, mais ou menos, nesse sentido, e não me parece que isto seja procedente.

No fim das contas, nós tivemos um pouco a discussão sobre a territorialidade, sobre a localização de provedores, perdão, localização dos servidores de dados pessoais, e esses dados pessoais coletados, no Brasil, teriam que obrigatoriamente ficar no Brasil. Discutíamos isso, na época, da elaboração do Marco Civil da Internet, como representante da Ordem dos Advogados do Brasil aqui já destacou, e, na época, a decisão tomada foi a de eliminar essa sugestão do texto da lei. Então, hoje, a lei não tem essa disposição, e ela não tem essa disposição, justamente porque é essa solução seria descabida; ela impediria plataformas de garantir uma mais privacidade aos

seus usuários e traria dificuldades logísticas absolutamente desnecessárias ao setor e a essas empresas.

Então, no fim das contas, quando falamos de jurisdição, de produção de dados, é importante considerar que estamos falando de um tema que deve ser tratado necessariamente na esfera de cooperação internacional, justamente porque, por excelência, é um tema complexo, é um tema espinhoso e é um tema delicado. Não é só apenas em relação à transferência de dados, fornecimento de dados entre as jurisdições; é um tema espinhoso em basicamente qualquer seara.

E quanto à cooperação internacional, já sabemos que essa única solução justamente porque quando há um abandono dos espaços de estabelecimento de mecanismos de cooperação internacional, e se privilegia os mecanismos unilaterais, o que temos são posturas que frequentemente escapam de consensos transacionais sobre produção de dados e que acabam tendo a tendência de andar no sentido de violação de direitos e de eliminação de garantias inatas à produção de dados.

Ocorreu isso, na ocasião do chamado caso Snowden e da revelação dos mecanismos de vigilância do Governo dos Estados Unidos, que gerou uma crise diplomática. Enfim, o mundo, desde então, tem andado no

sentido oposto, no sentido de restabelecimento do mecanismo de cooperação internacional.

Logo, o argumento central - acho que eu gostaria de colocar aqui - é justamente quando falamos desse tema, estamos falando de cooperação internacional essencialmente. Mecanismos unilaterais evidentemente existisse, evidentemente podem ser colocadas, balizados, incluídos de forma complementar, mas não é possível afastar os mecanismos de cooperação internacional sob pretexto de que os mecanismos são morosos ou pouco adequados. Isso porque, entrando na seara mais jurídica da discussão que fazemos aqui, estamos falando, em uma última instância, do devido processo legal.

No fim das contas, é claro existe uma consideração sobre as limitações dos MLATs, as dificuldades que se têm com os MLATs em relação à morosidade, em relação ao procedimento ser eventualmente burocrático demais, sobre se precisa ser atualizado. Essa discussão existe, mas é diferente se trazer essa discussão no sentido de "vamos levar isso para via diplomática" e discutir isso e tentar estabelecer exceções, estabelecer novas condições, ou até mesmo instituir mecanismos unilaterais e simplesmente se fazer o que parece ser o caminho que parte da jurisprudência tem adotado, entender que, de alguma forma, o Marco Civil da Internet autoriza o juiz a escolher ou não

aplicar o MLAT quando parecer inconveniente. E essa opção não parece adequada, ao que é o caminho que se tem tomado ao redor do mundo.

E, sim, novamente, existem - claro - mecanismos unilaterais que podem ser implementados, adaptados - já citou aqui muitas vezes o CLOUD Act, mas se deve observar. O CLOUD Act é uma lei que passou pelo devido processo legislativo nos Estados Unidos e foi sancionado pelo Presidente dos Estados Unidos. No Brasil, a interpretação que se tem feito de que o Marco Civil da Internet autorizaria, de alguma forma, aplicação da lei brasileira como se o MLAT, uma vez incorporado ao Direito Brasileiro não fosse a lei brasileira, isso autorizaria o afastamento do MLAT, na prática, enfim, com certeza não é a mesma coisa.

Em suma, indo por esse caminho, parece-me, nós estamos gerando não apenas um risco muito grande, do ponto de vista diplomático, mas nos arriscando a descumprir sistematicamente o tratado internacional ao qual nós aderimos, a partir da nossa soberania, e nós estamos colocando em risco a proteção de dados de inúmeros cidadãos brasileiros. Então, o caminho posto, sem dúvida, parece mais atraente e é o que diz a experiência internacional.

Novamente, muito obrigado, Ministro Gilmar Mendes, muito obrigado a todos e todas!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Agora, com a palavra, o Doutor Vinicius Marques de Carvalho.

O SENHOR VINICIUS MARQUES DE CARVALHO (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP) - Boa tarde a todos e todas, boa tarde, Ministro Gilmar Mendes.

Antes de mais nada, gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa em convocar essa audiência pública sobre a ADC 51, tema super relevante, cujo posicionamento do Brasil certamente vai ter impacto para modelos de negócio, ambientes econômicos e desenvolvimento da chamada economia digital, atividade que têm, cada vez mais, contaminado setores tradicionais da economia. Hoje, talvez seja até difícil definir exatamente o que é economia digital, porque seus modelos de negócio têm, cada vez mais, tocados setores econômicos tradicionais. Hoje, no Brasil, basta ver os aplicativos que têm sido desenvolvidos por exemplo, no setor de meios de pagamento e financeiro como um todo, saúde suplementar e educação, ou seja, é modelo de negócio que tende a se espraiar e contaminar todos os setores econômicos da sociedade. Obviamente esse ou esses modelos de negócio incluem - a gente não está tratando de um modelo só - características disruptivas que, de certo modo, desafiam nossos modelos institucionais e toda a estrutura normativa que, muitas vezes, compõem nosso sistema jurídico.

Queria falar um pouco desse ponto. Talvez nisso minha contribuição seja um pouco diferente da maioria das contribuições que aconteceram aqui hoje. Como regra geral - acho que a Doutora Jaqueline já mencionou isso de manhã -, existem duas grandes, digamos, regras relacionadas à discussão de competência jurisdicional quando tratam desses sistemas. A primeira diz respeito à localização da companhia como referência para a aplicação da lei, e a outra, à localização da evidência como referência para a definição da jurisdição que vai lidar e decidir sobre essa evidência. Esses sistemas, até pouco tempo atrás, misturavam-se em várias situações e, até aqui, em algumas situações, talvez tenham-se misturado - na medida em que algumas manifestações vão no sentido de defender a soberania nacional. Afinal de contas, se a empresa está instalada no Brasil, deve cumprir a lei brasileira. Ora, acho que ninguém imagina que uma empresa se instale no Brasil sem saber que tem que cumprir a legislação brasileira. Esse ponto, acho, não está em discussão. O que está em discussão é que essas duas regras gerais acabaram, de algum modo, sendo questionadas pela própria realidade da economia digital e por esses modelos. E o que são esses modelos? Basicamente, a gente está lidando com as chamadas plataformas de múltiplos lados ou plataformas de dois lados, enfim. Esse modelo não é um modelo novo. Todo mundo aqui lembra do jornal impresso? O jornal impresso é um modelo típico

de plataforma de dois lados. Basicamente, o que isso quer dizer? Que o equilíbrio econômico desse modelo de negócio não é alcançado com base só em um lado da plataforma. Se um jornal é entregue à população, por exemplo, a preço zero, ninguém, em sã consciência, vai dizer que o dono daquele jornal está praticando preço predatório, porque obviamente alguém está olhando para o outro lado dessa plataforma e dizendo que ele está auferindo toda a renda da venda de anúncios. Ele pode adotar outro modelo, em que cobre um pouco mais de um lado da plataforma, um pouco menos de outro. É por aí que se dá o equilíbrio.

O que a economia digital faz é levar a níveis muito mais intensos esse modelo e utilizar os chamados efeitos de rede. Efeitos de rede chamados diretos e indiretos, em que a utilidade da plataforma é tanto maior quanto mais usuários há, de um lado e de outro da plataforma.

Esse modelo, obviamente, cria uma série de características. Uma delas é que a gente vê enormes ganhos de escala e também economias de escopo. Esse modelo ganha todas essas características usando como elemento central o dado, pessoal ou não - dados de maneira geral. Escala de dados é aquilo que permite, de maneira geral, que produtos sejam ofertados no mercado em quantidade razoavelmente grande a ponto de, em determinadas circunstâncias, permitir que, mesmo em grandes empresas, esse produto seja

ofertado em preços muito mais baratos - considerando que o outro lado da plataforma, como, por exemplo, o lado relacionado à publicidade e propaganda, está remunerando a produção desses tipos de serviços. Isso vale para redes sociais, buscadores, a chamada economia do compartilhamento - Airbnb, Uber e todos esses aplicativos que a gente conhece. Todo mundo sabe o ganho de bem-estar para o consumidor que isso tem gerado, ampliação de acesso e assim por diante.

Outro elemento importante que o uso de dados por essas plataformas de maneira geral revela é a possibilidade de customização. A gente tem aí também uma chamada economia de escopo. Não só a quantidade, mas a diversidade de dados permite que as empresas customizem e organizem produtos e serviços específicos focados para determinados perfis de consumidor. Isso também, em tese, em qualquer economia de mercado, é visto como algo que agrega valor. Óbvio que, de outro lado, é visto, de maneira geral, pela literatura, como vantagem competitiva, uma diferenciação de produtos e assim por diante.

Agora tem um terceiro elemento que, acho, toca principalmente a discussão aqui. Com todo esse movimento que vimos nos últimos anos, as discussões relacionadas a privacidade ganharam relevo ainda maior. Todo mundo reconhece isso. A privacidade e a forma como as empresas

que atuam nesses setores protegem os dados pessoais também se tem tornado cada vez mais uma vantagem competitiva, uma forma de diferenciação. Isso é algo que deve ser preservado e deve ser levado em conta em qualquer decisão que tenha impacto nesses modelos de negócio. Óbvio que quando a gente fala de modelo de negócio, nenhum modelo de negócio, nenhuma estratégia empresarial está livre de intervenção estatal, da necessidade de se impor determinados requisitos de interesse público para seu exercício. Mas isso, de certo modo, também tem que ser levado em consideração em todas essas discussões.

Parece-me claro que, diante dessas características específicas e da problemática que se ensaia nesses debates que estamos tendo aqui hoje, a questão da cooperação internacional e da solução unitária e coordenada para esses conflitos acaba sendo caminho que melhor preserva todos esses interesses. Quando a gente analisa algumas regras de jurisprudência que têm sido ensaiadas no Brasil - por exemplo, decisões do STJ na linha de que mensagens entre brasileiros sobre conteúdo relacionado a ilícitos praticados no Brasil não são evidência estrangeira ou que troca de dados no mesmo grupo econômico também não violaria o princípio da territorialidade e assim por diante -, a despeito da discussão de mérito dessas decisões, um ponto importante a ressaltar - e desculpem a menção futebolística

- é a frase de Garrincha: "combinou com os russos?". No fundo, é um pouco isso. Combinou com os americanos que vai ser essa regra? Combinou com as outras jurisdições que vai ser essa regra? Se isso for organizado desse modo, o risco de *by pass* institucional - risco que a gente não pode tomar como jurisdição - é, de certo modo, afastado. Se o problema é morosidade - não acho que seja só morosidade, talvez existam outras questões aí, inclusive a preocupação com o próprio conteúdo relacionado a cada um desses pedidos -, é importante que haja solução harmônica para todas essas questões.

Acho que o que fica claro é que, a despeito de nossa soberania, o aperfeiçoamento desses instrumentos não pode passar por decisão unilateral que possa, de algum modo, invadir ou correr o risco de invadir a soberania de outra jurisdição de outro país.

Obrigado!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado.

Passo agora a palavra ao professor Fabrício Polido.

O SENHOR FABRÍCIO POLIDO (INSTITUTO DE REFERÊNCIA EM INTERNET E SOCIEDADE - IRIS) – Boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, relator da Ação

Declaratória de Constitucionalidade 51, autoridade acadêmica e judiciária, por quem cumprimento os demais colegas presentes nesta oportuna sessão de debates sobre as repercussões constitucionais e internacionais da ADC 51.

É tema que certamente não só repercute no decidir das instituições e dos sistemas de regulação de governança de internet - como a conhecemos -, nos campos de jurisdição, prescrição e execução das decisões, mas também nos faz voltar à essência da discussão a respeito de direitos, responsabilidades e obrigações que formam esse grande campo de batalha de interações e divergências de atores estatais e não estatais, esse grande espaço que é a internet: comunicação, informação e conhecimento.

Fui incumbido com essa missão central, como professor de direito internacional e advogado - mais de quinze anos dedicados aos temas de direito internacional e novas tecnologias -: vir à mais alta Corte para contribuir com os principais resultados de pesquisas e reflexões desses últimos anos a respeito do tema.

Em 2018, fechei publicação intitulada *Direito Internacional Privado nas Fronteiras da Tecnologia e do Trabalho: ensaios e narrativas na Era Digital*. Esse livro antecipava um pouco discussões que fui acumulando ao longo dessa carreira, tanto na advocacia como na academia - especificamente na Universidade Federal de Minas Gerais -, com a ideia de voltar a problemas

com que o direito internacional se via confrontado. As novas tecnologias, sem dúvida, transformam a racionalidade de princípios que estão na Constituição de 1988, como, por exemplo, os que inspiram as relações internacionais do Estado brasileiro - o tão esquecido e maltratado artigo 4º da Constituição de 1988. Este não foi, de certo modo, ventilado apropriadamente em muitas das apresentações escritas, mas volta a esta tribuna justamente porque o Supremo Tribunal Federal tem a tarefa de delimitar o escopo do que é um contencioso constitucional e, ao mesmo tempo, fazer valer os tratados e convenções que o Brasil firmou na ordem internacional. Um desses é justamente o que discute não apenas questões de cooperação e assistência mútua entre Brasil e Estados Unidos - questões características da diplomacia interestatal e das relações intergovernamentais - mas também - e aí talvez esse seja o ponto central e por isso a necessidade de amplo debate pelos vários atores que têm interesses no campo de regulação da *internet* - no que diz respeito a transação, divulgação e fornecimento de dados de usuários localizados em território brasileiro.

Se estamos olhando as repercussões de decisão em ação direta de constitucionalidade - que nada mais faz do que fazer valer o direito a ser aplicado -, lembrando frase de um professor de Direito Internacional: Direito não é bom senso, não é encanto pelo outro, Direito é vigência. Nesse caso específico, o acordo entre Brasil e Estados Unidos é um tratado de

cooperação jurídica internacional como qualquer outro. Tem que ser observado pelas Cortes inferiores, nos casos que digam respeito a questões processuais e, também, materiais relacionadas a processo penal.

Não sou especialista em direito penal, mas questões sistêmicas de direito internacional passam por esta ação direta de constitucionalidade. Sobretudo porque, se negarmos vigência ao próprio tratado ou acordo bilateral entre Estados Unidos e Brasil, incorporado pelo Decreto nº 3.810/2001, também estaremos negando vigência a outros dispositivos do direito brasileiro, não só da Constituição. Talvez nem me aventurasse a ir mais além do que já foi dito a respeito da Constituição, mas o próprio artigo 1º do Código de Processo Penal determina a observância de tratados, convenções e regras de Direito Internacional no desenvolvimento do processo penal. Envolve também partes que não estão diretamente relacionadas a persecução e investigação criminais, mas que, de certo modo, podem ser afetadas pelos efeitos irradiantes e irresistíveis de eventual decisão do Supremo nesta ADC nº 51. Não estamos apenas lidando com interesses que dizem respeito aos Estados e às empresas, nos polos de um contencioso que se trava, mas, sim, especificamente, de direitos de usuários da *internet* que, em espectro maior, também poderiam ser afetados a depender de decisões proferidas nos tribunais inferiores - em patente violação da Constituição de

1988 e também dos tratados que o Brasil assinou e aos quais se vinculou na ordem internacional.

Gostaria de fazer três pontos que dizem respeito a três submissões materiais feitas pelos *amicus curiae.* A proposta apresentada pelo Instituto de Referência à Internet e Sociedade se integra à participação de atores para contribuir com esta Corte na discussão científica e acadêmica dos temas em consideração no litígio como um todo, na disputa, e é alinhar e não permitir que o contencioso se desestabilize. Estamos falando de recurso constitucional, ação de competência originária, que vai ao fundo de problemas que ultrapassam a jurisdição do Estado brasileiro. Muito se viu no desenvolvimento das apresentações anteriores, por exemplo, distorção a respeito da aplicação do próprio artigo 11 do Marco Civil da Internet - que apenas reflete microcosmo de relações que dizem respeito aos direitos de usuários de internet no Brasil. Se olharmos a forma como a dogmática das relações civis ali estabelecidas é maltratada dentro da própria Constituição ou dentro de uma ação constitucional, encontraremos essa distorção ou extensão dos efeitos do artigo 11 do Marco Civil da Internet - como se ele fosse suficiente, por si só, para isolar a competência dos tribunais brasileiros e a jurisdição do Estado brasileiro bastasse para solucionar casos que foram sendo adjudicados pelos tribunais inferiores.

Esse é um problema sério. Por quê? Porque, aí, entramos em campo minado, não só de confusão de conceitos, mas também de confusão de regras vigentes no direito brasileiro e no próprio direito internacional, por exemplo o fato de que o artigo 11 não diz respeito - como já mencionado várias vezes aqui e em outras intervenções - a regra de competência ou de jurisdição de tribunais brasileiros, mas, sim, a regra de Direito aplicável. Não há nenhum problema - do ponto de vista técnico - em que haja interesses ou concorrência de interesses regulatórios entre diferentes Estados, para alcançar fatos, situações e relações jurídicas que se desdobram em seu território. Isso alcança um conceito tradicional de soberania, mas depende de instrumentos, como a cooperação jurídica internacional, para solucionar problemas que dizem respeito não apenas à forma como o processo se desenvolve e tem solução perante os tribunais, mas também à forma como os Estados, em quadro de cooperação para a regulação de problemas materiais, como os casos que envolvem *internet*, estejam alinhados nesses mesmos interesses.

Vale lembrar que depende muito - e esse é um problema central desta ação direta de constitucionalidade - dos efeitos que serão dados por esta Corte e que podem afetar como as relações na internet se desenvolvem. Uma preocupação central é: por que temos que fazer valer a aplicação de tratados e convenções? Por uma razão muito simples: não só porque a

Constituição Federal determina mas também pelo fato de que o Marco Civil abre janela sistemática para as normas de direito internacional, ao dispor, em seu art. 3°, parágrafo único, sobre a entrada ou interação de tratados e convenções para solucionar questões que decorram do Marco Civil da Internet e que afetem questões ou aspectos de direitos dos usuários relacionados em casos que extravasem o microcosmo das políticas de perseguição e investigação criminal - muito legítimas também do ponto de vista do exercício da soberania do Estado brasileiro.

Para concluir, é muito importante se fazer uma pergunta: na forma em que esta decisão, na ADC, seja dada e proferida, ao suprimirmos mecanismos e procedimentos de cooperação jurídica internacional no processo civil e penal brasileiro, como ficariam resguardados direitos e garantias processuais das partes em litígios de internet, sobretudo por força do art. 26, I, do Código de Processo Civil, art. 1° do Código de Processo Penal e do art. 3° do parágrafo único do Marco Civil da Internet, em conformidade com as normas constitucionais especificamente contidas no art. 5, LIV, LV, LVI, e parágrafos 1º e 2º da Constituição de 1988 - que também não foram analisados em concreto na repercussão constitucional que uma decisão do Supremo poderia dar a esse caso?

Agradeço a todos e a todas. Estou à disposição desta Corte para contribuir para os debates. Obrigado!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) - Obrigado. Com a palavra agora o Professor Danilo Doneda.

DOUTOR DANILO DONEDA (CENTRO DE DIREITO, INTERNET E SOCIEDADE DO IDP - CEDIS/IDP) – Boa tarde, Ministro-Presidente, Excelências, senhoras e senhores.

O tema da jurisdição e internet não é um tema pontual, não é um tema cuja discussão começa ou termina aqui. É um problema persistente, e muito persistente no caso da internet.

Eu começo fazendo alusão a uma metáfora, uma metáfora que começou com uma provocação do professor italiano Natalino Irti, ele falava que a internet era comparável, em relação ao seus problemas jurídicos, ao Direito do Mar, fazendo uma alusão inclusive ao livro do jurista Carl Schmitt, *Nomos da Terra*, pelo qual, pra ele, o Direito da Terra era um direito com fins e bem definidos, espaços protegidos, proprietários; enquanto o espaço do mar era amplo, poderia permitir a sua coutilização, dificilmente permitiria a atribuição de limites e confins. E Natalino Irti levava isso para os dias de hoje, no sentido de que, na internet, era muito difícil para ele estabelecer alguns limites que, no Direito na Terra, digamos assim, seriam naturais. E não é por

outro motivo que, até na nossa gramática, na nossa simbologia, até hoje, utilizamos metáforas como a da navegação na internet. Um dos primeiros *browsers* era o *Netscape Navigator*.

Há uma miríade de problemas relacionados à jurisdição que datam, desde o começo, da relevância jurídica, por assim dizer, na internet. No ano 2000, talvez, o mais relevante dos primeiros caso ocorreu, um caso em que o então grande buscador de motor de pesquisa, Yahoo, que tinha um site de vendas, foi compelido a retirar da venda um artigo memoráblia neonazista, sendo que o serviço era gerado, gerenciado nos Estados Unidos, porém, estava possibilitando a venda para países que tinham vedações em sua legislação para a venda de tais itens. Houve um primeiro momento de estranhamento, de estupefação, mas abriu-se a porta para uma série de complexidade relacionada à jurisdição, que, até hoje - quem somos nós para dizer que não -, assolam-nos bastante.

Bom, normas que acabaram de entrar em vigor, que ainda vão entrar em vigor vão endereçando esse problema de forma, cada vez mais, vamos dizer assim, pragmática, pragmática a ponto, às vezes, até de tentar antever problemas que ainda não são totalmente resolúveis com os instrumentos atuais.

Vejamos o Marco Civil na Internet, a própria Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), elas procuram afirmar, em uma técnica bastante parecida com o GDPR, mas não somente com o GDPR, a possibilidade da aplicação da sua norma a uma série de situações que têm relevância direta nos nossos problemas, nos costumes locais, por exemplo, com tratamento de dados do território nacional que incluem pessoas residentes no Brasil, ofertas direcionadas a cidadãos que se encontram no Brasil.

Todos esses temas, com algumas modulações, variações, estão no Marco Civil na Internet, muitos já foram tocados aqui, estão na LGPD. De certa forma, ressoam algumas soluções da GDPR, regulamento para operação de dados, muito embora, possa se traçar um desenvolvimento nosso, um toque desses problemas.

E eu queria propor, não como solução, mas como método de observação do problema, é que esses métodos se entrechocam com uma certa rigidez de algumas soluções que hoje são proporcionadas pelos MLAT's. Claro, o MLAT não é um conteúdo objetivo fixo, pode ser desenvolvido, há que ser desenvolvido, há promessas de que ele deva ser desenvolvido, mas os MLAT's foram, são, geralmente, instrumentos, cuja formulação iniciou na década de 60, e respondem, com alto grau de eficiência, a várias demandas, mas eles estão muito baseados em soluções territoriais muito firmes,

dependem da situação da localização das partes, das empresas, no caso, dos dados quando chegamos à economia da informação.

Os MLAT's são instrumentos gerais que - a isso devemos prestar atenção - não foram desenvolvidos levando em conta a tal dinâmica informacional. Não tratam de temas como: como os dados são transferidos; quais os instrumentos que governam a transferência desses dados; como preservar os direitos das pessoas envolvidas, não só os de titulares de dados, mas de pessoas que tangencialmente estejam envolvidas. E isto foi muitas vezes ressaltado, como constatação, como crítica, os MLAT's são classicamente complexos, custosos e lentos. Isso talvez não tenha ficado tão óbvio, nem pareça, sim, em várias ocasiões, mas em situações que tenham a ver com a dinâmica da internet e a dinâmica da informação, talvez seja uma situação, seja uma qualificação que salte aos olhos em diversas vezes, porque as características da informação hoje são dificilmente apreensíveis a confins.

A determinação dos lugares, onde a informação está a quem a trata, pode ser muito pouco substancial na dinâmica da internet. A transmissão de dados é definida não por um caminho previamente traçado, mas por uma multitude de critérios, que podem ser técnicos, como a otimização de fluxo de redes, utilização racional de recursos informáticos, modelos de negócio e também critérios jurídicos. Mas esse balanceamento é

muito variável, envolve uma série de fatores que se tornam ainda mais complexos em plataformas que atingem dezenas, centenas de países ao mesmo tempo.

Bom, isso levou, essa dificuldade, digamos assim, levou justamente ao desenvolvimento desses instrumentais, do Marco Civil da Internet, da LGPD, para tratar desses problemas, porque reconhecer a via única do MLAT, muito embora tenha uma consistência jurídica bastante forte, bastante argumentável, talvez não daria os incentivos necessários, talvez o próprio aperfeiçoamento do MLAT. E eventualmente não seja uma solução completamente afinada com o espírito do nosso tempo.

Por exemplo, veja a Lei Geral de Produção de Dados, art. 33, II, "*c*", o que fala? Fala "*by the incorporate rules*", normas corporativas globais. É um instrumento que facilita o intercâmbio de informações dentro de uma própria organização, um conglomerado. Para quê? Para justamente azeitar esse fluxo de dados entre empresas que têm pés em várias jurisdições.

Agora, por um lado, reforçar esse mecanismo, que é justamente um pedido, um clamor, de uma boa parte do setor privado, ante a entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados, eventualmente se enquadraria em uma sistemática que objetivamente entraria em contradição com a própria

ideia do MLAT. No caso aqui, o MLAT clama por uma solução diplomática para determinados fluxos de dados.

Bom, ao mesmo tempo que, digamos, o sistema do MLAT pode ser tido como ineficiente, a insistência num modelo que eventualmente se torne anacrônico pode potencializar alguns problemas que já estão se fazendo ver: os bloqueios, lei sobre localização de dados, o recurso de agências de *enforcement* a métodos informais de cooperação que eventualmente existem e até em alguns países, isso vem sendo cada vez mais documentado e até, de certa forma, se procura regulamentar, de forma incipiente, o chamado *government hacking*, isto é, o recurso, por órgãos públicos, a técnicas similares ou mimetizadas com o acesso "não autorizado" a sistemas informatizados.

Nesse sentido, aqui já caminhando para o final, entendo que seria necessário aumentar tanto a eficácia dos pedidos de requisição de informação, mas, ao mesmo tempo, proporcionar medidas para proteção e clareza dos direitos dos cidadãos e também das regras do jogo para governos e empresas. Requisitos para que isso seja feito seriam: deixar claro que o país requerente possa ter que demonstrar o interesse específico no caso requisitado e também que o sistema de requisição deve levar em conta tanto a proteção de dados como padrões de direitos humanos.

Nesse sentido, a Coalizão *Necessary and Proportionate*, logo depois dos escândalos do Edward Snowden, redigiu um documento, com vários especialistas em Direitos Humanos, que faz menção a vários requisitos para que o acesso a dados por forças de *law enforcement* possa ser feito sem que se coloque em risco os direitos dos interessados, dos titulares.

Nesse sentido, também é necessário lembrar que as normas de proteção de dados têm uma valência estratégia nesse ponto. Lembro aqui que a Câmara dos Deputados nomeou uma comissão de juristas, presidida pelo Ministro Nefi Cordeiro, justamente para regulamentar o artigo da Lei de Proteção de Dados - o art. 4º, § 1º - que fala na aplicação das leis, dos princípios de proteção de dados, dos direitos dos titulares, na maior medida possível, também para investigações criminais e segurança pública.

Em conclusão, levando em consideração tanto o caso em questão quanto a sua repercussão, vemos que a discussão vai muito além do reconhecimento, ou não, da constitucionalidade de um decreto. Essa constitucionalidade, no caso, não parece sequer questionável. No entanto, a discussão tem como consequência que seus efeitos sejam produzidos dentro de um quadro normativo geral no qual, sempre que cabível, outras fontes também hão de ser igualmente consideradas.

Especificamente, verificamos que as dinâmicas dos fluxos de informação na internet são fluidas, complexas e, em especial, dificilmente enquadráveis em alguns dos pressupostos que tradicionalmente vêm embasando os MLAT's, relacionados ao critério do território como ensejador de legitimidade e efeitos. E essa tensão chega a tal ponto que é possível mesmo aludir a um certo anacronismo na utilização exclusiva desse instrumento, anacronismo que eventualmente pode consolidar-se em vários riscos, até indesejáveis, mesmo para aqueles que propugnam pela sua utilização.

Muito obrigado pela atenção!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado!

Agora, com a palavra, a Doutora Nathalie Fragoso.

A SENHORA NATHALIE FRAGOSO (INTERNETLAB - PESQUISA EM DIREITO E TECNOLOGIA) - Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, demais presentes, prezados colegas, boa tarde!

Eu queria começar agradecendo, em meu nome e em nome de InternetLab, um centro independente de pesquisa em direito e tecnologia, a oportunidade de participar desta audiência pública e contribuir com a instrução adequada desta ADC.

O InternetLab é uma entidade sem fins lucrativos que pretende atuar como ponto de articulação entre academia e representantes dos setores público, privado e sociedade civil, incentivando e promovendo o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares e baseadas em evidências que abordem, de maneira adequada, os desafios de elaboração e implementação de políticas públicas de internet.

Não custa retomar que a internet e o processamento transacional de dados, frequentemente implicados, têm desafiado as pretensões jurisdicionais dos Estados e os contornos tradicionais dos princípios da soberania e da territorialidade. Um ato juridicamente relevante afinal pode ser praticado no país X, através de uma plataforma cujo provedor está sediado no segundo país, e produzir efeitos no terceiro.

O resultado comum desse arranjo é a concorrência de diversos Estados com reivindicações de jurisdição legítimas quando se trata de um dos critérios de fixação de competência.

Nessa ADC, está em questão, então, o acordo de assistência judiciária em matéria penal com o Estado dos Estados Unidos da América e está em questão por conta da interpretação que vem sendo conferida ao Marco Civil da Internet, sobretudo no que diz respeito ao conteúdo do seu artigo 11 e do § 2º deste mesmo artigo.

O artigo 11 do Marco Civil da Internet prever que as diversas operações de tratamento de dados estão submetidas à legislação brasileira, e o § 2º fala que empresas estrangeiras também estarão submetidas a essa incidência.

Daí vem sendo desdobrado o lastro para solicitação direta de comunicações dirigidas por empresas estrangeiras, geralmente estadunidenses e as suas filiais brasileiras, ou seja, esses dispositivos vêm sendo interpretados de modo a submeter as empresas à lei nacional não somente no que diz respeito ao tratamento de dados, conforme o sentido literal da norma, mas também à legislação material e processual penal, no caso, para o acesso aos dados de internet.

Assim sendo, é daí, portanto, que surge o conflito jurisdicional decorrente da simultânea pretensão estrangeira no que diz respeito a competência para companhias sediadas no seu território e comunicações armazenadas no país.

Eu gostaria de propor uma outra questão, uma outra interpretação, que já foi suscitada aqui Professor Fabrício. A obrigação de respeito à lei brasileira, inclusive por pessoas jurídicas sediadas no exterior, caso ofertem serviços ao público brasileiro, não se opõe ao cumprimento do rito estabelecido em outros diplomas legais brasileiros para obtenção de

cooperação internacional. Isto se desdobra do artigo 3º do Marco Civil da Internet, segundo qual os princípios expressos na lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Aliás, não é que o Marco Civil não se oponha, ele impõe. O acordo referido integra ordem jurídica. Portanto, a obediência ao rito de cooperação jurídica-internacional positivado no sistema brasileiro é coloca-se como adequada interpretação do sentido do artigo 11.

É óbvio que há de se esperar das empresas de tecnologia que têm acesso ao mercado brasileiro, um dos maiores do mundo, e aos dados pessoais de seus cidadãos, cooperação com as autoridades brasileiras. De fato, se respeitados os direitos fundamentais dos cidadãos e usuários de internet, em especial, os direitos à privacidade e aos associados à proteção de seus dados pessoais, tal comparação é imprescindível para a adequada prestação jurisdicional e deve ocorrer, como ressaltamos acima, com o respeito à totalidade do ordenamento jurídico brasileiro, o que inclui tratados internacionais efetuados pelo governo brasileiro no exercício de suas funções executivas e da sua soberania.

Mas o Marco Civil da Internet, como visto e já ressaltado, é aberto à normação internacional, assim como o Código Processo Civil, assim

como o Código de Processo Penal, e o seu texto é harmonizável aos procedimentos de cooperação tal como previstos.

A tentativa de resolução do conflito de forma unilateral, como tem-se pretendido, falha em promover a coordenação entre os Estados-nação e endereçar as questões postas, pelas novas tecnologias de informação e comunicação, como desafios ao processo penal e ao direito internacional de maneira consistente e estrutural. Isso porque a proteção da soberania, como também já foi abordado por vários expositores aqui, não é uma via de mão única. É um equilíbrio delicado, e as práticas adotadas pelo Brasil em relação a empresas estrangeiras com presença nacional poderão ser espelhados por outros entes estatais que colocam xeque o funcionamento da internet enquanto tecnologia, que tem como uma de suas maiores virtudes ser uma rede de interconexão global.

A título ilustrativo, eu acho que vale mencionar, a InterneLab foi participou foi admitida como *amicus curiae* em um caso norte-americano, também já mencionado aqui, em que a empresa Microsoft questionou uma ordem judicial que demandava o acesso a dados, hospedados no servidor irlandês.

Naquela ocasião, nossa contribuição estava muito pautada na preocupação de que uma decisão naquele caso, se favorável aos ao Governo

Estadunidense, poderia representar um alarmante precedente e implicaria reconhecer o poder de um governo para acessar informações de cidadãos independentemente de estarem sob jurisdição de outros países em que a legislação poderia, inclusive, estabelecer diferentes graus de proteção à privacidade e ao devido processo legal.

O caso em tela suscita preocupação similar. De fato, com arguem e demonstram as autoridades brasileiras, a expedição de cartas rogatórias e os ritos estabelecidos pelo MLAT, na forma como hoje processados, podem frustrar as expectativas das autoridades brasileiras de acesso célere aos meios de prova.

O legítimo objetivo de promover adequada persecução penal, dentro do cometimento de crimes, não pode ser ignorado, nem deve ser. Quanto a isso, acho que também foi reiteradamente suscitada a necessidade ou oportunidade de modernização desses procedimentos para cooperação jurídica, hoje, burocráticos e demorados como uma responsabilidade premente do Estado brasileiro, a quem em cabe o papel de defender a soberania e negociar esses tratados.

Cabe os Poderes Legislativo e Executivo, no limite de suas competências, fazê-lo, engajando-se em iniciativas internacionais que pondere

modelos alternativos de cooperação, de forma garantir a preservação dos interesses dos Estados soberanos.

Ao Judiciário Brasileiro, por outro lado - e, aí, que eu gostaria de centrar a contribuição -, incumbe a garantia dos direitos do acusado, conforme sua missão constitucional.

As insuficiências que se manifestam no cotidiano da justiça criminal, embora profundamente relevantes, não bastam para que se abdique do devido processo, isto é, da observância de formas instrumentais adequadas a assegurar uma prestação jurisdicional justa.

A incerteza quanto ao procedimento, ao contrário, fragiliza e infirma garantias processuais penais e abre espaço para mecanismos de cooperação informais que padecem de falta de transparência, previsibilidade e falham em considerar garantias processuais.

A pretensão do acesso direto - e eu já encerro - armazenados em territórios estrangeiros sob custódia de empresas estrangeiras, ou seja, a pretensão de exercer poder jurisdicional sobre coisas e pessoas submetidas a outra jurisdição, desafia princípios de direitos internacionais reconhecidos pela Constituição Federal, tal como o respeito à soberania alheia que decorre dos princípios que orientam as relações internacionais do Brasil.

Há, por outro lado, relevantes implicações internas ainda a considerar. A coleta de meios de prova fora das balizas previstas no MLAT viola a Constituição, seja pelo desrespeito aos já referidos princípios da soberania, da autodeterminação dos povos, da não intervenção, da igualdade dos Estados, seja pela inobservância do procedimento estabelecido como capaz de submeter as provas oriundas de outra jurisdição a filtros garantidores de credibilidade e de direitos.

A inobservância das regras na obtenção desses elementos compromete a admissão e a valoração dos elementos de prova; expõe o processo, mina processo ao invés de garanti-lo, posto que sujeita esses elementos à sanção decorrente da violação de princípios relacionados com a ordem pública.

Eventual modernização, reforma ou aperfeiçoamento devem permanecer, devem ser feitas de maneira atenta ao devido processo legal e seus elementos condicionantes observados

Ao Judiciário, neste contexto, espera-se que exerça função de tutela dos direitos, de garantias das regras do jogo, enquanto essas regras não se alteram.

Obrigada.

A SENHORA NATALIA PEPPI (PESQUISADORA) - Boa tarde a todos. Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, Doutor Eduardo Dantas, Doutor Vitor Fernandes, Doutora Monique Siqueira, demais membros da Mesa, todos aqui presentes.

Gostaria de iniciar parabenizando o Excelentíssimo Ministro-Relator e todo o gabinete ao convocar essa Audiência Pública para tratar de tema tão atual e inovador. É um privilégio e uma honra poder contribuir com o debate ao lado de renomados estudiosos. Este Supremo Tribunal Federal terá um papel pioneiro nesse debate.

A célebre frase do escritor americano Alec Ross, no livro d*e* *The Industries of the Future,* que compara os dados, na sociedade atual, à agricultura na era agrícola e à indústria na era industrial, retrata bem a importância do tema ora debatido, uma vez que os dados eletrônicos são hoje um dos principais motores da economia e da ordem mundial. Portanto, os dados e seu fluxo passaram a necessitar de tutela jurisdicional e se tornaram verdadeiro direito fundamental a ser protegido pelo Estado. Isso traz graves implicações para o Direito, que precisa acompanhar a dinâmica evolutiva das relações jurídicas sociais, e é justamente parte do desafio que estamos hoje, aqui, debatendo.

Afim de deixar a discussão mais clara, é preciso ressaltar que estamos tratando especificamente do *enforcement* das decisões judiciais e/ou administrativas, ou seja, os limites que exigem para que o Brasil faça valer a legislação interna em território estrangeiro, onde for sediada determinada empresa envolvida em um processo, cujo objetivo é a obtenção de dados eletrônicos referentes ao conteúdo de comunicações privadas, armazenadas ou controladas fora do território brasileiro.

As respostas não são fáceis. No entanto, como afirma o professor Thomas Schultz, da *King's College* de Londres, parecem poder ser encontradas em uma releitura da própria definição de conceitos como território, soberania, jurisdição e consenso jurídicos entre os vários atores do direito internacional público e privado.

Nesse contexto, a rede internacional *The Internet & Jurisdiction* afirma que as tensões entre sistemas jurídicos nacionais, baseados no princípio da territorialidade, são uns dos maiores desafios do séc. XXI. Como já aqui falado, vários Estados já requereram dados localizados fora de sua jurisdição, persuadindo as empresas a cumprirem ordens de entrega fora de sua soberania e sem a utilização dos competentes mecanismos de cooperação internacional. Ou seja, sem respeito ao devido processo legal.

No Brasil, a Questão de Ordem no Inquérito 784/DF, julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 2013, sob o único argumento de afronta à soberania, determinou a entrega de dados localizados fora do País. Por outro lado, o mesmo STJ, em outubro de 2019, pela Sexta Turma, no Habeas Corpus 88.142, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, reconheceu a necessidade de se utilizar esse mecanismo de cooperação para a obtenção desses mesmos dados. Isso mostra a pertinência da presente ADC.

Para melhor análise desse assunto, é possível verificar que a Constituição Federal, nos arts. 4º, parágrafo único, e nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 5º e o 181, assim como a legislação infraconstitucional sobre o tema revelam que o Brasil garante um Estado constitucional cooperativo, defendido por Peter Häberle há muito.

Nesse ponto, faço um parêntese para destacar que esse próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu o fenômeno de substituição do arcaico Estado voltado para si por um Estado constitucional cooperativo, que demanda a manutenção da boa-fé e da segurança jurídica, tendo na cooperação jurídica internacional a forma de viabilizar esse fenômeno. Como exemplo, cumpre citar o voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário 460.320, do Paraná.

Passando ao exame da legislação infraconstitucional, sobre o tema, verifica-se que o aparente conflito de leis entre Marco Civil da Internet e os seus dispositivos de aplicação unilateral da lei brasileira, previsto aqui no já citado art. 11 e o Decreto 3.810, de 2001, que determina o processo a ser adotado, em caso de cooperação jurídica internacional, não tem razão de ser, isso porque, como sabido, as leis devem ser interpretadas dentro de um contexto. O próprio Marco Civil da Internet, no art. 3º, prevê, em seu parágrafo único, a necessidade de observância dos tratados internacionais em que o Brasil é parte. Portanto, o Marco Civil jamais poderia ir de encontro ao estabelecido no acordo entre Brasil e Estados Unidos especificamente.

Além disso, o antagonismo do binômio de privacidade/ segurança, muitas vezes utilizado no debate, é criticado tanto pela doutrina nacional quanto a internacional, já que, em diversas ocasiões, direitos fundamentais foram gravemente flexibilizados em favor de uma pretensa necessidade de resposta social, às vezes política e até midiática, a questões de segurança. No entanto, privacidade e segurança não são mutuamente excludentes; pelo contrário, são complementares e elencadas como princípios basilares da nossa Constituição.

Já sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira - LGPD, a par das diversas discussões sobre a lei, cumpre destacar para esse debate que

a LGPD traz a definição de transferência internacional de dados no seu inciso XVI do art. 5º, e estabelece a possibilidade de armazenamento de dados em servidores localizados ao redor do globo. No art. 3º, há a previsão de eficácia extraterritorial da lei. No entanto, não traz qualquer obrigação de entrega de dados localizados em outro país, nem estende essa competência jurisdicional.

A LGPD é inspirada na *General Data Protection Regulation*, o GDPR, que também prevê a aplicação extraterritorial da lei em determinadas circunstâncias, mas, como não poderia deixar de ser, ambas não indicam jurisdição executiva extraterritorial. Tanto a LGPD, quanto o GDPR não indicam como será realizado o *enforcement* das decisões envolvendo as leis. Para isso será necessária a cooperação jurídica internacional. A razão disso é justamente o fato de que os princípios de soberania, independência, não intervenção e cooperação entre os povos contidos expressamente na nossa Constituição Federal não permitem aos Estados estrangeiros realizarem diligências processuais, nem executarem decisões judiciais em território nacional à margem dos apropriados mecanismos.

A Professora Marion Albers, da Universidade de Hamburgo, em recente palestra proferida no IDP, ressaltou que a União Europeia perdeu a oportunidade de discutir sobre o *enforcement* das decisões judiciais envolvendo a questão de dados eletrônicos com GDPR. Portanto, o

argumento de soberania deve ser utilizado justamente no sentido contrário: é para preservar a soberania do Brasil e dos demais Estados-nações que os mecanismos de cooperação jurídica internacional são hoje o único meio de se respeitar o devido processo legal.

Aqui eu faço um parêntese no meu discurso para mencionar que o caso Nova Escócia, por exemplo, já mencionado, é justamente o contrário. Se é possível que uma empresa entregue documentos bancários para outro Estado sem o devido processo legal, por que o próximo passo não será a realização, por exemplo, de **15 26 25**, Excelência, sem o devido mecanismo de cooperação internacional? Afinal, hoje tudo é dado.

Voltando... Dentro da cooperação internacional, os MLATs são hoje o devido processo legal vigentes e válidos no ordenamento brasileiro e legitimamente incorporados ao Direito interno. Contudo, tal procedimento é considerado excessivamente burocrático e lento. Segundo La Chapelle e Fehlinger, os fundadores da organização *The Internet & Jurisdiction*, é possível classificar os problemas da atual implementação dos MLATs no mundo como celeridade, escopo, assimetria e escalabilidade. Com relação ao problema da celeridade, é necessário ter em mente que os MLATs foram criados em um contexto histórico em que os crimes transnacionais eram exceção e utilizados

apenas para casos excepcionais. Assim, são mal adaptados à atual velocidade da internet.

Especificamente com relação ao MLAT Brasil-Estados Unidos, a *Electronic Frontier Foundation* defende a exclusão do requisito de *probable cause* presente nos tratados. Para a Professora Jennifer Daskal, da Universidade de Harvard, a necessidade de indicar a causa provável acaba por burocratizar ainda mais o procedimento, pois a autoridade que requisita tais dados deve indicar expressamente as razões pelas quais quer aquela informação. Tal exigência leva muitas vezes ao indeferimento do pedido e, consequentemente, novas requisições devem ser formuladas, o que contribui para a demora no êxito. Diante disso, é necessária a criação de soluções inovadoras que superem essas limitações.

Nesse sentido, surge o já também citado *Clarifying Overseas Use of Data Act*. O CLOUD Act vem justamente para tentar simplificar e agilizar esses procedimentos de cooperação entre os Estados Unidos. O CLOUD Act possibilita ao Poder Executivo americano firmar com Estados estrangeiros acordo executivos. Apesar de o Brasil ainda não ser signatário da Convenção de Budapeste, mesmo com grande pressão, com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, o País está em consonância com a Convenção e, portanto,

preenche os requisitos necessários para a celebração do acordo que pode substituir o atual Tratado de Cooperação MLAT com base.

Dessa forma, parece ser de relevante interesse a assinatura de um acordo executivo entre o Governo brasileiro e o Governo norte-americano com o objetivo de permitir às empresas sediadas nos Estados Unidos o cumprimento direto de ordens judiciais independentemente da observância do procedimento previsto no MLAT, que permanecerá suplementarmente em vigor. Com isso o devido processo legal será observado, uma vez que haverá regras claras para o cumprimento das decisões judiciais.

É necessário aumentar os estudos e os debates para evitar as consequências negativas do formato atual e, ao mesmo tempo, preservar a natureza global da internet, combatendo seus abusos. Nesse contexto, não é exagero afirmar que a situação posta constitui um dos maiores desafios do séc. XXI, e nenhum ator conseguirá resolvê-lo unilateralmente - é necessária a cooperação entre todos. Como destaca Yuval Harari, a cooperação entre os Estados-nações é peça fundamental para os desafios do séc. XXI.

Gostaria de encerrar a minha colaboração com uma frase de Hannah Arendt no livro *Sobre a Revolução*, de 1963: Quando os regimes deixam de ter a cooperação como norte, seu poder se evapora e, mesmo que possam

durante algum tempo evitar a derrota recorrendo à violência, não poderão se salvar.

Muito obrigado pela oportunidade.

O SENHOR ANDRÉ GIACCHETTA (YAHOO! BRASIL) - Muito boa tarde, Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, a quem eu tomo a liberdade de cumprimentar, integrantes da Mesa, senhoras e senhores, meus colegas.

Falo hoje em nome de Yahoo Brasil, empresa que atua diretamente no Brasil desde 1999 e, portanto, o objetivo da contribuição é tentar trazer um pouco mais da experiência prática do que a empresa vem vivenciando nesses vinte anos de atividades realizadas diretamente no Brasil.

É importante dizer, como abertura, em nome da Yahoo Brasil, que a empresa adotou e vem adotando todas as medidas necessárias para atender à legislação brasileira, vem aperfeiçoando a sua forma de conduzir seus negócios, a fim de atender à legislação brasileira, mas ainda assim, ante a possibilidade de contratação de usuários e empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, a liberdade de contratar dos usuários, existem, sim, situações nas quais é necessário se valer dos tratados internacionais e dos mecanismos de cooperação para que as ordens judiciais brasileiras sejam devidamente cumpridas.

Começo fazendo uma pergunta que vou tentar endereçar, de alguma maneira, nessa contribuição de 10 minutos: quais seriam as reais razões de se negar a aplicação do MLAT? Seria exclusivamente a morosidade do procedimento existente hoje, na forma como constituído? Seria o fato de que essa discussão do MLAT se dá geralmente ou exclusivamente quando a ordem de fornecimento de dados e conteúdo é direcionada à subsidiária local? Portanto, parece que não estamos discutindo aqui a utilização do MLAT para situações nas quais sequer haja representação da empresa ofertante do serviço ao usuário local. Ou será que a negativa de aplicação ao MLAT também se dá dentro da facilidade da transmissão e do fluxo de dados dentro dos conglomerados empresariais? E aqui é importante já ressaltar de início, como já foi dito, que o art. 11 do Marco Civil, já tão mencionado, trata exclusivamente de hipóteses da aplicação da lei brasileira; não há sequer uma passagem no Marco Civil tratando sobre jurisdição ou competência. Por isso, na sequência, pretendo contribuir olhando sob a perspectiva da lei brasileira, ou seja, qual é o conjunto de regras legais, hoje, aplicáveis no Brasil, que determinam as hipóteses de fornecimento de dados e de conteúdo, e a quem essas ordens devem ser dirigidas para que haja o seu cumprimento. Mas, ressaltando neste início, há liberdade de usuários, de cidadãos e consumidores brasileiros contratarem os serviços de empresas estrangeiras. Não há vedação.

Nessa linha de se negar a utilização especificamente do MLAT, o que se tem visto, na prática, é que se quer obter um atalho, uma forma fácil de se alcançar dados e conteúdo que não estejam ou localizados ou acessíveis por meio de empresas estabelecidas no Brasil. Portanto, em termos de jurisdição e competência, o ponto nevrálgico não é jurisdição e competência das autoridades de investigação judiciárias brasileiras para se determinar a quebra do sigilo e para se determinar o fornecimento dos dados ou do conteúdo. O que se questiona é como executar e como implementar a ordem judicial de autoridade brasileira para além do território nacional. Portanto, é a distinção da competência para se determinar a quebra daquela para se implementar e se fazer a coleta do dado ou do conteúdo fora do território nacional.

Portanto, a contribuição é olhar para o regramento legal brasileiro e como é que ele está construído, hoje, em termos de hipótese de fornecimento de dados.

A primeira - e a gente tem olhado aqui, e as contribuições foram muito focadas no art. 11 do Marco Civil, mas há outras tantas exposições do Marco Civil que reforçam a interpretação sistemática dele -, o primeiro deles é dizer que cada empresa, cada provedor de aplicação de internet responde exclusivamente pelo serviço que oferece, portanto, entender e delimitar com

clareza qual é o serviço que cada uma das empresas oferece, seja empresa estrangeira, seja empresa local.

Outro princípio presente no Marco Civil é também o da responsabilização de acordo com as suas atividades. Então, o Marco Civil sempre rumou, muito claramente, em delimitar a atividade e a responsabilização. E aqui não se trata de responsabilização em indenizar. É responsabilização e responsabilidade em dar cumprimento à regra brasileira local.

Diz mais: que a obrigação de cumprir ordem judicial para tornar indisponível um conteúdo ou mesmo para fornecer dado ou conteúdo está restrita aos limites técnicos do serviço oferecido.

Vou além, o Marco Civil, ainda diz que a obrigação de fornecimento dos dados ou mesmo de conteúdo cabe ao provedor responsável pela guarda. Esse ponto é importante porque, como disse anteriormente, a discussão que se tem levado a efeito, na prática, é obrigar empresas subsidiárias de empresas estrangeiras a dar cumprimento a ordens de fornecimento de dados e de conteúdo. Ora, o Marco Civil parece dar e encaminhar uma solução também a isso.

E é importante também que se diga, em relação ao Marco Civil da Internet, a única hipótese de solidariedade no Marco Civil da Internet

é para pagamento de multa em caso de infração aos dispositivos que falam do tratamento de dados pessoais. Não há nenhuma hipótese possível de se entender que haja solidariedade entre subsidiária e empresa estrangeira ao cumprimento de ordem. É neste aspecto que a Yahoo do Brasil tem entendido aplicável o MLAT como necessário. Do contrário, estaremos dirigindo e exigindo cumprimento de uma ordem judicial brasileira válida, mas adotando um mecanismo, como aqui eu chamei, de atalho, de coagir e de impor sanções, não só pecuniárias, mas até mesmo prisionais, como já antecipado aqui, como subterfúgio à aplicação do MLAT. Então, portanto, parece que o Marco Civil da Internet dá a saída e dá as alternativas para essa finalidade.

Eu tentei exemplificar alguma das possíveis consequências, em caso de se levar adiante à fórceps, se exigir o cumprimento na forma, como temos visto na prática, do fornecimento de dados e conteúdo a partir das empresas localizadas aqui no país.

Aqui, abro um parêntese, acho que todos nós temos conhecimento de incidente recente, em que o aplicativo de mensagem instantânea sequer tem representação, escritório ou qualquer tipo de presença aqui no país. Então, como dar endereçamento a isso? Então, parece haver um desequilíbrio na forma de tratar empresas sem representação em solo nacional e empresas que decidem estabelecer as suas subsidiárias aqui no País. Então,

há consequências, tanto do ponto de vista para as empresas brasileiras, as subsidiárias brasileiras e também para as empresas estrangeiras.

E eu vou finalizar minha contribuição dando um exemplo de duas decisões já não tão recentes, mas dois trechos que me parecem bastante evidentes da proposta aqui apresentada.

Essa aqui é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi, de 2011. Há um trecho, esse item IV, que eu tomarei a liberdade de ler para encerrar a minha contribuição.

É uma discussão a respeito da necessidade de utilização de acordo internacional, do MLAT, para fornecimento de dados de instituição financeira que diz (há distinção entre a competência para se determinar e a competência para executar a ordem):

> Apenas a execução da medida, por depender de providências a serem tomadas em outro país, dependerá da aquiescência do Estado estrangeiro, que a realizará ou não a depender da observância das normas internas e de Direito Internacional a que se sujeitam, sendo que, em caso, como visto, existe acordo de assistência judiciária, em matéria penal, a respaldar o envio de documentação e das informações requeridas pelo Ministério Público Federal e autorizadas judicialmente.

Encerro, Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, com a sugestão, e olhando sob uma perspectiva pragmática, de que parece haver um tratamento não isonômico em relação às empresas que têm subsidiárias no

Brasil e aquelas sem representação local. E, mais do que isso, o Marco Civil da Internet não é excludente de aplicação de tratados internacionais.

Muito obrigado pela atenção e pela gentileza.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Agora teremos, por videoconferência, o Dr. Albert Gidari.

O PROFESSOR ALBERT GIDARI (FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.)* transcrição baseada em tradução simultânea - Agradeço o privilégio de depor hoje. Lamento que minhas responsabilidades docentes na Faculdade de Direito da Universidade de Stanford me impediram de viajar e estar com os senhores em pessoa. Atualmente, sou Diretor de Privacidade no Centro para Internet e Sociedade da Faculdade de Direito de Stanford. Tive longa carreira trabalhando em questões de privacidade e direito sobre vigilância eletrônica, sobretudo o SCA.

Examinei e ouvi, com muito interesse, os depoimentos de hoje de manhã e gostaria de esclarecer dois pontos desde já. Primeiro, o caso do Banco da Nova Escócia não mantém ou sustenta que haja filial operando nos Estados Unidos, portanto a empresa-mãe no exterior pode ser obrigada, por tribunal americano, a divulgar dados para fins de investigação criminais nos Estados Unidos. Na verdade, o caso sustenta que a subsidiária filial precisa ter custódia ou exercer controle e acesso legal a esses dados para assim

estar obrigado. O segundo ponto: mal-entendido semelhante pode existir também no que se refere ao caso da Microsoft, que levou à promulgação da Lei Cloud Act. Esse caso e também o próprio Cloud Act defendem que, nos Estados Unidos, a custódia e o controle de dados, independentemente de onde a empresa escolha armazená-los, a empresa não pode ser obrigada a produzir esses dados. De modo que a filial brasileira de empresa estrangeira que não têm acesso a dados armazenados pela empresa-mãe em outro país não pode ser obrigada a produzir ou fornecer aquilo que não possui.

Examinei as declarações e os depoimentos do ex-Ministro da Justiça Holder e do senhor Renan, e constato que suas avaliações sobre o SCA são justas e precisas. Conforme explanaram esses especialistas e conforme entendo ser a legislação, as empresas sujeitas ao SCA não podem simplesmente divulgar o conteúdo de comunicações a qualquer pessoa, incluídos governos estrangeiros - com limitadas exceções, sendo uma delas mandado emitido por tribunal americano.

Acredito que esse argumento foi bem frisado por outros. Gostaria, então, de concentrar meu depoimento nos riscos de responsabilidades e custos financeiros que os provedores poderiam enfrentar por violarem os termos do SCA. Primeiramente, o risco de ação civil. Nos termos do SCA, qualquer pessoa cujas comunicações tenham sido divulgadas

em violação à lei aplicável pode processar o provedor. Significa, portanto, que não só a pessoa alvo da ordem judicial tem o direito de processar - caso a divulgação tenha sido inadequada - mas também as pessoas que estão dentro ou com quem a pessoa alvo se comunica - por exemplo, ciclo ampliado de familiares e amigos cujo conteúdo esteja mesclado com a comunicação do alvo. Mais do que isso, quando as práticas de divulgação violam a lei, uma pessoa pode representar a classe de muitas outras pessoas em situação semelhante. Por exemplo, uma pessoa pode mover ação em nome da classe de todos os usuários, dentro de determinado país, cujas comunicações tenham sido divulgadas ilicitamente para agências de investigação criminal daquele país - caso o SCA não permita tal divulgação. Indenização por danos previstos no SCA serão o mais alto: ou o valor dos anos incorridos ou mil dólares por violação. Uma classe pode incluir centenas de milhares de usuários, logo, os danos indenizáveis em potencial são extraordinários.

Defender qualquer litígio nos Estados Unidos é caro, sendo as custas de ações de classe números que facilmente chegam a centenas de milhares ou bilhões de dólares, independentemente do desfecho. Além disso, se o provedor perder, terá de pagar também os honorários advocatícios do requerente e custas processuais. Se o Tribunal determinar que a divulgação foi dolosa ou intencional, indenizações punitivas por danos poderiam ser

concedidas como dissuasivo para qualquer violação futura. Por fim, o Tribunal pode emitir medida cautelar contra quaisquer divulgações análogas no futuro. Essas são algumas das situações de indenizações em potencial previstas no SCA.

Os provedores, nos termos da legislação de privacidade federal e estadual, também podem enfrentar consequências semelhantes. A Califórnia, estado onde a maioria dos provedores residem, tem legislação de privacidade das mais rigorosas dos Estados Unidos, mais rigorosa do que previsto no SCA com relação à divulgação de informação dos usuários.

Com base no Federal Trade Commission Act ou leis estaduais semelhantes, as agências regulatórias poderão investigar essas divulgações como práticas comerciais injustas e enganosas, se não tiverem sido adequadamente divulgadas aos usuários com base em acordos ou políticas de privacidade com os usuários ou se as políticas feitas nesses acordos tiverem sido desconsideradas. Em suma, os provedores, ao divulgarem conteúdo de usuários, enfrentam risco de sérias penalidades se não seguirem estritamente os requisitos previstos no SCA ou em outras leis.

Embora o risco monetário seja muito alto, ele se desvanece em comparação com os custos incorridos pelos danos à reputação e perda da confiança do consumidor vinculados à violação de lei americana promulgada

para proteger a privacidade de todos os usuários, não só de cidadãos americanos.

Também não importa se as intenções do provedor foram boas ou se achou que as divulgações eram adequadas. Se um tribunal determinar que o provedor, para evitar qualquer erro, deveria ter feito mais para assegurar-se sobre a licitude de divulgação, o resultado pode ser claramente a responsabilidade civil.

É a lição que deriva do Caso Streetman & AOL (Aol), onde a Aol foi processada, com êxito, por divulgar informação de usuários em resposta a pedido que não havia sido assinado adequadamente. Erro material em boa-fé por parte da Aol não foi razão para a defesa.

Cabe observar aqui que não há qualquer imunidade ao provedor por responder diretamente a ordens judiciais em ações penais de outros países. Nos termos do SCA, o provedor só tem imunidade quando responde adequadamente ao processo legal nos Estados Unidos, inclusive ou incluindo o tipo de processo legal que emana de requisição via MLAT válida.

É particularmente relevante que os tribunais americanos, no amparo da SCA, estão abertos a qualquer pessoa cujo conteúdo tenha sido ilicitamente divulgado.

Em média, a pessoa alvo de investigação criminal no Brasil pode não ter a capacidade de reivindicar direitos no Brasil, mas o fato é que basta um único requerente engenhoso para se ter êxito aqui. A lista de requerentes em potencial, mais uma vez, inclui todo o universo de amigos que compartilharam conteúdos com o usuário brasileiro cujo conteúdo tenha sido divulgado como parte da conta da pessoa alvo. Essas pessoas podem residir em qualquer lugar do mundo, incluindo Estados Unidos. Essa é a natureza da internet e essa é a realidade da base global de usuários do Facebook.

Com efeito, entidades não governamentais e grupos de defesa da privacidade têm-se tornado cada vez mais eloquentes na documentação das práticas de vigilância de países como o Brasil, bem como práticas de provedores em resposta a processo legal. Esses grupos são bem financiados, têm alcance global e capacidade para representar pessoas ou grupos ao amparo do SCA em demandas judiciais nos Estados Unidos.

As práticas de vigilância e conceito de privacidade modernas cada vez têm-se tornado questões candentes na agenda, de crescente interesse público, e tendem, certamente, a se tornar cada vez mais importantes no futuro.

Embora o interesse público e o escrutínio das práticas dos provedores tenham aumentado drasticamente nos últimos anos, o fato é que

os provedores sempre analisam cuidadosamente todos os requisitos por informação de usuários. Os provedores são transparentes acerca de suas práticas de divulgação, incluídas práticas adotadas em resposta a pedidos de governos.

O Facebook, por exemplo, compartilha publicamente, na página <transparecy.facebook.com>, estatísticas relativas a requisições de governos por uso ou por dados de usuários. Consta dos relatórios do primeiro semestre de 2019 que o Facebook recebeu mais de 128 mil requisições de dados e forneceu alguns, em resposta a cerca de 74% desses pedidos. A maioria dos pedidos veio do governo americano, seguidos de Índia e Reino Unido, estando o Brasil em sexto lugar.

Esses dados ilustram que a questão que se apresenta ao Tribunal hoje, sobre a aplicabilidade do MLAT Brasil/Estados Unidos, é de crucial importância para Brasil, sim, mas não se trata de questão singular. Muitos países apresentam solicitação de dados ao Facebook e, de modo geral, o Facebook não pode disponibilizar conteúdo a nenhuma desses países, dada as proibições contida no SCA.

Em toda minha experiência, o sistema MLAT tem sido característica e fator constante utilizado por governos em todo o mundo para se obterem provas adequadamente, de parte a parte, no âmbito de

investigações penais. O MLAT oferece regras de clareza solar para os provedores e minimiza o risco de responsabilidade civil, por responder diretamente a ordem judiciais de tribunais não americanos. É sistema internacional que vale a pena respaldar e modernizar e que tem, ainda, em seu bojo, a virtude de atender aos requisitos do SCA sem colocar os provedores em posição inviável ou comprometer a privacidade dos usuários.

Agradeço o privilégio de me dirigir a este Tribunal no dia de hoje. Obrigado!

DOUTORA ANDREA KIRKPATRICK (FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.) - Fico muito grata pela oportunidade de me dirigir a esta respeitável Corte. Meu nome é Andrea Kirkpatrick. Sou diretora para assuntos jurídicos do Facebook e líder da nossa equipe jurídica responsável por assessoramento em matérias de aplicabilidade geral da lei em escala global em termos de segurança.

O Facebook foi fundado há 15 anos, como um modo de estudantes universitários se conectarem com seus amigos. Desde então, cresceu e se tornou uma empresa global. Mais de 2,8 bilhões de pessoas de praticamente todos os países da Terra utilizam o Facebook, o Instagram e o Messenger, a cada mês, para se conectarem, para compartilharem as coisas sobre as quais se interessam, com as pessoas que lhes são importantes.

As plataformas são de custo zero porque nossa principal fonte de receita é a publicidade. Milhões de empresas em todo mundo, incluídas muitas aqui do Brasil, usam nossas plataformas e produtos para construir suas empresas, alcançar clientes e encontrar outros novos clientes.

Muito nos orgulhamos do modo como o Facebook e o Instagram foram abraçados amplamente pelo povo brasileiro. Cada empresa de pequeno porte que utiliza o Messenger para conversar com seus clientes, ou o Instagram para apresentar os seus produtos, ajuda a frisar o argumento de que, embora sejamos uma empresa baseada no Vale do Silício, nosso impacto é de escala global.

A questão que se põe diante deste distinto Tribunal é a constitucionalidade, a eficácia e a aplicabilidade do tratado de assistência jurídica mútua entre o Brasil e os Estados Unidos. Conforme sabem os Meritíssimos, essas questões têm ressonância muito além desta sala e estão no âmago daquilo que significa para as empresas globais de internet investir e fazer negócio no Brasil e em todo mundo.

Nossa posição, bem como a posição de amigos da corte e juristas neste país e em todo mundo, é de que o MLAT Brasil/Estados Unidos é constitucional, é eficaz e deveria ser a norma padrão aplicada pelas cortes brasileiras em investigações penais que envolvam requisições de dados

controlados por empresas americanas. Agir de outro modo suscitaria o risco de obrigar empresas como o Facebook a violarem as leis de seu país de origem e as exporia a riscos jurídicos tanto no país de origem quanto no exterior.

Permito-me entrar em mais alguns pormenores. Há dois fatos que são fundamentais para a questão em pauta. Primeiro, o Facebook sede nos Estados Unidos, o Facebook Inc, é o provedor do serviço e controlador dos dados de usuários para usos do Facebook e do Instagram no Brasil. Basicamente, somos a empresa que provê os serviços do Facebook e do Instagram, bem como os respectivos aplicativos, e com os quais as pessoas concordam compartilhar seus dados.

Segundo fato: o Facebook foi fundado nos Estados Unidos e, portanto, está sujeito à jurisdição americana. Em particular, estamos sujeitos ao SCA, a lei sobre comunicações armazenadas, uma lei federal que rege comunicações eletrônicas armazenadas e registros transnacionais mantidos por empresas americanas, como nós. Nos termos desta lei, de modo geral, estamos proibidos de divulgar ou disponibilizar conteúdo das comunicações de nossos clientes a qualquer pessoa ou entidade.

A lei americana define conteúdo como a substância, ou propósito, ou significado, o sentido de uma comunicação e exclui metadados sobre essas comunicações. A título de exemplo, se alguém mandou, se a pessoa

envia um *e-mail* a outra pessoa, o conteúdo seria o assunto e o corpo do *e-mail*, mas não a informação "de" e "para". É mais ou menos como pensaríamos, por exemplo, em uma carta numa caixa postal. A informação do lado de fora do envelope, o destinatário e o recebedor ou endereço recebedor não seriam protegidos, mas a mensagem dentro da carta sim.

No caso do Facebook, especificamente, o conteúdo inclui coisas como mensagens, fotografias, *post* e curtidas e não inclui metadados fora do envelope, do tipo, endereço de IP ou informação de registro. Assim nos termos do SCA, de um modo geral, estamos proibidos de divulgar mensagens, fotos, *post* e curtidas para qualquer terceiro.

Com efeito, de fato, de modo geral, estamos proibidos de divulgar até mesmo metadados ao governo americano na ausência do processo legal. Entretanto temos, sim, permissão de divulgarmos, voluntariamente metadados a entidades governamentais estrangeiras. Metadados, incluindo dados tais como a informação básica de registro que pode incluir nome, duração de serviço, informação de cartão de crédito, número de telefone, endereço de *e-mail* e recentes endereços de IP.

Atuamos dessa forma, conforme dizemos aos usuários de nossa política de dados, quando temos uma crença, de boa-fé, de que uma resposta seria necessária, conforme previsto na lei naquela jurisdição, e que a

investigação subjacente afetará os usuários naquela jurisdição e se faz em consonância com os padrões internacionais.

As autoridades de investigação criminal em todo o mundo buscam registros do Facebook e do Instagram e podem pedir ou apresentar seus pedidos por meio do sistema *Enforcement Online Request System*, 24 horas por dia, sete dias por semana e receberão a resposta por *e-mail* com *link* seguro para baixar os dados conforme apropriados.

Aqui no Brasil, a lei americana permite-nos divulgar informação básica de registro em resposta a pedidos de autoridades brasileiras que sejam consistentes com leis locais, tais como o Marco Civil. Por exemplo, divulgamos os endereços IPs disponíveis em resposta a ordem judiciais. No que se refere, no entanto, ao conteúdo das contas, em conformidade com a lei americana, um mandado de busca, de um modo geral, é necessário. Há limitadas exceções, por exemplo, nos termos que regem o serviço e nos termos da lei americana, temos permissão para divulgar conteúdos de contas. Se temos uma crença, de boa-fé, de que existe uma emergência que envolva risco iminente de morte ou de lesão física grave, nessas circunstâncias restritas e limitadas, conforme definidas, podemos, voluntariamente, divulgar conteúdo de contas com base na lei americana. Desde 2017 ou 2019 produzimos dados

em resposta a mais de 500 pedidos emergenciais recebidos de autoridades brasileiras.

De igual modo, no mesmo período, também divulgamos metadados de usuários do Facebook ou do Instagram em mais de quatro mil, ou mais casos, em respostas direta a pedidos de autoridades brasileiras. Embora a maioria desses casos estejam sob sigilo, a imprensa brasileira já relatou vários exemplos de casos bem-sucedidos em que fornecemos registros de metadados, e essas divulgações contribuíram ao apenamento ou condenações.

A produção e o fornecimento de metadados nesses casos se fez de modo consonante com a legislação americana e brasileira. O Facebook Brasil apresentou informação em seus informativos submetidos a essa respeitável Corte.

Para mitigar o risco de violar a lei americana, o Facebook Inc EUA segue essa abordagem nas suas respostas a todos os pedidos de conteúdo de contas de autoridades internacionais. Sempre que recebemos um mandado de busca válido que pleiteie conteúdo de comunicações relativas a um pedido de MLAT de autoridades americanas ou de autoridades brasileiras, produzimos os dados disponíveis em resposta. Agir de outro modo nos

colocaria em risco de violar a lei do nosso país de origem, no qual estamos baseados e a cuja jurisdição estamos sujeitos.

Não há na lei do CLOUD Act nenhuma exceção nos Estados Unidos que isente um provedor da responsabilidade por produzir conteúdo em resposta ao processo legal de outros países. Violar o SCA poderia sujeitar o Facebook à responsabilidade civil na forma de ações civis que podem pleitear indenizações por danos ou ações impetradas por órgãos reguladores estaduais ou federais.

A questão que é examinada por esta Corte, uma vez mantida a constitucionalidade do MLAT Brasil/Estados Unidos, propicia justamente isso.

Vivemos numa era digital e esse tipo de comunicação deve se fazer de modo tão célere quanto eficiente, conforme se vê na internet. Para tanto, recentes desdobramentos na legislação americana criaram vias adicionais para se obter um conteúdo de um modo ainda mais eficiente. O CLOUD Act cria uma nova exceção na legislação americana que, na presença de um acordo bilateral celebrado entre Estados Unidos e um país estrangeiro qualificado, permite que provedores americanos, tal como o Facebook Estados Unidos, produzam, forneçam conteúdo diretamente em resposta a pedidos legais válidos de tal país.

Os Estados Unidos e o Reúno Unido firmaram recentemente o primeiro desses acordos bilaterais. Quando esse acordo entrar em vigor, este ano, provedores americanos poderão divulgar conteúdo de comunicação de usuários diretamente a autoridades homólogas do Reino Unido, sem risco de violar a legislação americana.

O governo brasileiro recentemente adotou medidas que tornará isso possível para o Brasil também. Em uma declaração conjunta, publicada em dezembro de 2019, pelos Ministérios de Relações Exteriores, Justiça e Segurança Pública, ficou indicado que o Brasil havia dado início ao processo de adesão à Convenção sobre o Cibercrime, conhecida também como a Convenção de Budapeste. Tornar-se membro integral da Convenção de Budapeste simplificará ainda mais o processo para o Brasil se qualificar para celebrar acordo bilateral com os Estados Unidos ao amparo do CLOUD Act.

A título de conclusão, os tratados existentes entre Estados Unidos e o Brasil, que regem questões de comércio, soberania e conflitos de legislação e jurisdição, remontam aos idos de 1820. Nossos países têm um longo histórico de cooperação mútua e de respeito pela soberania um do outro.

Dado esse longo histórico de cooperação, o Facebook e outras empresas de internet baseadas nos Estados Unidos não deveriam, como custo de fazer negócio no Brasil ou sob ameaça de multas ou prisão de

empregados, ser obrigados a correr o risco de violar a legislação americana. Isso é particularmente verdadeiro, no caso em pauta, onde os governos do Brasil e Estados Unidos já estabeleceram mecanismos para obtenção de conteúdos de usuários que respeitem as leis dos dois países, refletindo nossas fortes relações mútuas e bilaterais, nosso firme compromisso para com Estado Democrático de Direito.

Esses princípios, que ambos os países valorizam tanto, não precisam, não deveriam ser sacrificados em nome da celeridade. Nosso mundo pode estar cada vez mais conectado, sim, mas as nossas leis permanecem soberanas.

Obrigada.

(INTERVALO)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Podemo-nos sentar.

Declaro reabertos os trabalhos e vamos ouvir agora o Doutor Marlio Martins.

O DOUTOR MARLIO MARTINS (FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.) - Boa tarde, Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, na pessoa de quem cumprimento os demais expositores aqui

presentes. Meu nome é Marlio Martins. Sou diretor jurídico do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Gostaria de começar minha exposição descrevendo o que o Facebook do Brasil faz e como isso se relaciona ao Facebook Inc. - sociedade americana controladora dos dados - e às questões objetos desta audiência pública.

O Facebook Brasil foi constituído em 2011, com objeto social voltado para a área publicitária, incluindo a venda de publicidade *online*, serviços de *marketing* e desenvolvimento comercial. Temos orgulho de nosso impacto positivo na comunidade e economia brasileiras. Com os recursos de publicidade que oferecemos, milhões de pessoas e empresas no País conseguem anunciar produtos e serviços a custo reduzido e direcionar anúncios para públicos que geralmente se interessam pelos temas, no Facebook e Instagram.

Como minha colega Andrea Kirkpatrick esclareceu, o Facebook Inc., de um lado, é o provedor das aplicações Facebook e Instagram no Brasil e controlador de dados de usuários dessas aplicações. O Facebook Brasil, de outro lado, é empresa associada indiretamente ao Facebook Inc., sem poder sobre as decisões desta, incluindo fornecimento de dados de usuários para autoridades brasileiras. O Facebook Brasil não opera ou controla as

aplicações Facebook e Instagram. Não controlamos ou possuímos dados de usuários.

No que se refere ao Decreto nº 3.810/2001, o Facebook Brasil entende que forçar uma controladora de dados sujeita à jurisdição dos Estados Unidos a fornecer conteúdo de comunicações de forma direta para autoridades brasileiras, arriscando violar a lei dos Estados Unidos, viola nossos princípios constitucionais, como a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a solução pacífica de conflitos - como também exposto, nesta audiência, pelos Ministros Carlos Ayres Britto e Francisco Rezek.

No que diz respeito ao Facebook Brasil, embora este não seja sujeito à lei estadunidense, ele simplesmente não pode fornecer dados que não controla ou possui e não é obrigado, pela lei brasileira, a controlar ou possuir.

Embora alguns juízos reconheçam o Decreto nº 3.810/2001 como o devido processo legal para obtenção de conteúdo de comunicações controlado por empresa sujeita a jurisdição dos Estados Unidos, outros juízos discordam, e estes costumam ser agressivos. Apesar de o Facebook Brasil nunca ter estado envolvido em investigação criminal originária de determinação de entrega de conteúdo de comunicações, sofre multas que em muito superam as impostas a pessoas e empresas envolvidas em investigações criminais por suas próprias condutas.

Mais: estamos litigando em diversos casos, nos quais sofremos bloqueios sumários de dezenas de milhões de reais, por suposto descumprimento de ordens de entrega de conteúdo de comunicações. Em outros casos houve medidas ainda mais extremas, como destinação final de valores para fundos escolhidos pelo próprio juízo que impôs a multa diária - muito embora nosso direito de recurso ainda estivesse disponível - e eventual multa final não fosse de titularidade do juízo que a impôs, mas, sim, da União Federal. Esses gravíssimos fatos também serviram de fundamento para a respeitável medida liminar concedida nesta ADC.

Acredito que nenhuma empresa brasileira que cumpre a legislação brasileira, tem atividade protegida pela livre iniciativa, ajuda milhões de negócios locais a criarem postos de trabalho e recolhe milhões de reais em impostos, como é o caso do Facebook Brasil, deveria ter que navegar em cenário de tamanha insegurança jurídica, especialmente quando existe procedimento específico criado pelo Brasil e aprovado pelo Congresso brasileiro para que as autoridades obtenham as informações que buscam. O Decreto nº 3.810/2001 é o devido processo legal, tanto é assim que nenhuma das partes que se manifestou na ADC hoje arguiu a inconstitucionalidade do decreto.

Ao invés de buscar penalizar empresas como o Facebook Brasil, as forças de segurança pública poderiam tentar tornar a cooperação internacional tão eficiente para a obtenção de dados como ela é para a obtenção de informações bancárias, por exemplo. Essa busca por maior eficiência na cooperação internacional é um dos pilares da estratégia nacional de segurança cibernética, aprovada, em 5 de fevereiro de 2020, por meio do Decreto nº 10.222.

Para concluir e em resposta àqueles que argumentam que é uma questão de respeito às leis e à soberania do Brasil, lembro que o Facebook Brasil é empresa brasileira, emprega centenas de brasileiros, ajuda a economia brasileira a crescer e cumpre as leis do Brasil. Levamos isso muito a sério e não questionamos a autoridade do Poder Judiciário brasileiro para determinar o fornecimento de conteúdo de comunicações de pessoa investigada ou processada por crime ou ato ilícito cometido no Brasil. Ocorre que o Decreto nº 3.810 é lei brasileira. Trata-se do devido processo legal para que as autoridades brasileiras executem ordens judiciais locais contra controladoras de dados sujeitas à jurisdição dos Estados Unidos da América.

Quando considero os princípios constitucionais regentes das relações internacionais do Brasil - notadamente a cooperação entre os povos -, concluo que, da mesma forma que nós, brasileiros, não desejaríamos que uma empresa brasileira fosse forçada pelos Estados Unidos a arriscar-se a

violar as leis brasileiras, não deveríamos exigir que empresas dos Estados Unidos corressem o risco de violar suas leis locais em nosso nome, como custo de aqui operar.

A resposta que esta nobre Suprema Corte dará para a constitucionalidade do Decreto nº 3.810/2001 produzirá efeitos para muito além desse caso. Ela mostrará se o Brasil respeita acordos internacionais e o devido processo legal e se empresas estrangeiras podem investir em operar aqui com a segurança jurídica de que as leis existentes no País serão aplicadas e não serão forçadas a arriscar violar suas leis domésticas. Ao lembrar o histórico de defesa de nossa Constituição Federal por esta egrégia Supremo Corte e ver o sucesso de milhões de negócios no Brasil se conectando com consumidores no Facebook e milhões de pessoas compartilhando experiências com famílias e amigos no Instagram, espero que a resposta seja um claro sim.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Com a palavra agora o Doutor Rony Vainzof.

O SENHOR RONY VAINZOF (FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE SÃO PAULO - FIESP) - Boa tarde a todos e a todas!

Agradeço ao Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, em quem aproveito para cumprimentar as demais autoridades e colegas.

É com uma mistura de ansiedade, nervosismo e alegria que me encontro representando a FIESP, aqui na Suprema Corte do nosso País, discutindo um tema tão relevante e de forma tão plural.

Nós vimos aqui que uma questão é clara, a rápida troca de informações é pedra de toque para investigações de ilícitos praticados por meios cibernéticos, não só de dados cadastrais e registros eletrônicos, Excelência, mas também conteúdo de comunicação privada. E isso independentemente da localização física desse tipo de conteúdo. Criminosos, organizados ou não, utilizam as mais variadas tecnologias existentes para intercambiar informações entre si, visando a prática de ilícitos, tornando cada vez mais complexas as investigações.

Por outro lado, as autoridades encontram uma profunda dificuldade em terem acesso a relevantes dados para investigar ilícitos sofisticados e extremamente danosos.

Vimos também na parte da manhã, segundo as informações do DRCI, que o MLAT não atende aos propósitos para o quais ele foi criado, ao menos quanto à investigação de ilícitos cibernéticos.

Então, Excelência, nós temos aqui um nó jurídico. E qual é esse nó jurídico? Nós temos, nos Estados Unidos, o *Stored Communications Act* que veda que o conteúdo de comunicação armazenado em provedor nos Estados Unidos seja fornecido às autoridades brasileiras, senão por meio de MLAT ou carta rogatória.

E, por outro lado, nós temos o Marco Civil da Internet, que foi demasiadamente aqui discutido, sendo importante ressaltar o seguinte: em anos de discussão do Marco Civil da Internet, quando ele estava já na Câmara dos Deputados, o fato social relevante que motivou o seu regime de urgência foi o efeito das revelações do Edward Snowden. E, consequentemente, havia sido inserido um dispositivo que, não importando a localização física dos dados, os provedores por meio de decreto poderiam ter que fazer uma replicação do *data center* aqui no Brasil. E felizmente, felizmente, essa parte do Marco Civil da Internet caiu.

No entanto, um meio-termo ficou. E este meio-termo justamente prevê que, a partir do momento em que um provedor de conteúdo ou um provedor de conexão presta serviços aos brasileiros, ele tem que cumprir a legislação brasileira. Então, a motivação desse artigo do Marco Civil da Internet foi, sim, uma questão de jurisdição e competência, relacionada a essa obrigação de fornecimento dos dados.

E é interessante que se diga que, apesar de haver já algumas decisões STJ, uma delas salta aos olhos:

> "A alegada impossibilidade material e jurídica para o cumprimento de ordem judicial pode e deve ser superada no âmbito das relações internas das empresas do grupo de fato, controladoras e controladas."

A grande questão é que com esse nó jurídico todos perdem Excelência. Empresas brasileiras controladas são sancionadas, empresas estrangeiras controladoras ficam desestimuladas a investirem no Brasil diante dos riscos sancionatórios e da insegurança jurídica. O conteúdo de comunicação eletrônica não é fornecido ou não é fornecido em tempo hábil e as investigações de crimes cometidos na jurisdição brasileira ficam comprometidas.

E, aí, nós temos que nos socorrer, muitas vezes, do Direito comparado. E nós encontramos justamente, nos Estados Unidos, uma fonte para esse Direito comparado. É justamente o *Microsoft-Ireland Case* - que já foi comentado aqui -, no qual o Departamento de Justiça norte-americano requereu o fornecimento de conteúdo de *e-mails* à Microsoft para investigação de tráfico de drogas nos Estados Unidos, ou seja, uma empresa norte-americana relacionada a uma investigação de um ilícito ocorrido nos Estados Unidos.

A Microsoft, justamente baseada no Stored Communications Act, alegou que não poderia fornecer tal conteúdo por estar situado na Irlanda, e, portanto, regido pela lei de proteção de dados da Irlanda, a não ser, por meio de MLAT entre Estados Unidos e a Irlanda. E quando esse caso chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos, sobreveio o denominado CLOUD Act; e o CLOUD Act encerrou este caso na Suprema Corte.

Na decisão de encerramento deste caso, na Suprema Corte dos Estados Unidos, a própria Suprema Corte disse que o SCA não alcançava as comunicações armazenadas em outros países e que somente o Congresso poderia criar regras diferenciadas, como o CLOUD Act, que traz adequadamente o SCA para o séc. XXI, ou seja, a Suprema Corte dizendo que o SCA, agora, traz essa possibilidade.

E quando nós vamos estudar e analisar o SCA - e me perdoem aqui os colegas norte-americanos, porque eu sou um advogado no Brasil -, nas disposições preliminares, diz-se o seguinte:

> O acesso a dados eletrônicos mantidos por provedores serviço de comunicações é um componente essencial dos esforços do governo para proteger a segurança pública e combater crimes graves, inclusive, o terrorismo.
> Vejam só:
>
> Tais esforços do governo estão sendo impedidos pela incapacidade de acessar dados armazenados fora dos Estados Unidos que estão sob custódia, controle ou posse de provedores

> de serviços de comunicações sujeitos à jurisdição dos Estados Unidos.
> A mesma questão em que a gente se encontra agora.
>
> > Os governos estrangeiros também buscam cada vez mais acesso a dados eletrônicos mantidos por provedores de serviços de comunicações nos Estados Unidos com o objetivo de combater crimes graves.
> E, finalmente:
>
> > Prevê que um provedor de serviço deve, entre outras questões, disponibilizar o conteúdo de comunicação eletrônica de seus clientes, localizado dentro ou fora dos Estados Unidos.
> É isso que está previsto no CLOUD Act.

Pois, então, a questão que eu deixo aqui é se, no Brasil, nós já não temos o nosso próprio CLOUD Act. Em qual sentido? Fazendo um comparativo do Marco Civil da Internet, art. 11, § 2º, junto com o art. 10, § 2º, nós temos um paralelismo muito semelhante ao que está justamente previsto no CLOUD Act, ou seja, há a jurisdição sobre a empresa, não importa a localização dos dados, e eles devem ser providos; é exatamente esta a sistemática utilizada nos Estados Unidos com o CLOUD Act.

Se há solução para esse dilema, nós estamos avaliando, aqui, que o tema é extremamente complexo e espinhoso. Se, por um lado, é de suma relevância o fornecimento de comunicações eletrônicas privadas de forma rápida e eficaz às autoridades brasileiras, para que seja possível investigar ilícitos cibernéticos aqui ocorridos, por outro lado, Excelência, impor sanções às filiais brasileiras para que as controladoras norte-americanas sejam

forçadas a fornecer tal conteúdo, também aparenta ser prejudicial a todos, mormente diante dos riscos à economia digital brasileira.

O COUD Act, na minha visão, é uma oportunidade porque ele conta com uma seção dedicada, a *Executive Agreements*, ou seja, a possibilidade de governos estrangeiros terem acesso aos dados, o que poderia facilitar a rápida troca de informações para a investigação de ilícitos cibernéticos, no caso, de celebração de novo acordo entre Brasil e Estados Unidos, desta vez baseado na nova lei norte-americana, o que poderia ser facilitado diante do amplo diploma legal brasileiro de proteção de dados, notadamente o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados que entra em vigor, espero, em agosto deste ano.

A base de toda essa nossa conversa é a confiança. Qualquer indivíduo só troca dados com quem confia. A confiança entre países, Excelência, para o intercâmbio de informações é a segurança jurídica oriunda de acordos internacionais. Porém esses acordos devem ser condizentes com a realidade. E a realidade é que há necessidade da mais alta celeridade na troca dessas informações.

Esperamos que a nova legislação norte-americana possa viabilizar a melhoria e a rapidez na investigação de ilícitos cibernéticos por meio de um novo acordo internacional.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Agora, com a palavra o Doutor Diego Gualda.

O SENHOR DIEGO GUALDA (CÂMARA BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO - CBCE) - Boa tarde! Cumprimento o Ministro-Presidente e os demais presentes.

A contribuição da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico vem de encontro a sua missão e preocupação com as condições de desenvolvimento da economia digital. A missão da Câmara-e.net é a capacitação de indivíduos e organizações para economia digital. A economia digital hoje, no Brasil, já tem escala bastante grande e tende somente a aumentar. Nesse sentido, acho que é importante ressaltar três condições para o desenvolvimento da economia digital e da economia como um todo.

A primeira condição é o fato de que a economia digital se dá em escala global, sempre em escala global. A segunda é que a inovação e geração de desenvolvimento depende, sim, de ambiente em que se respeite direitos fundamentais. Aqui, a gente está falando de direitos fundamentais, tanto do ponto de vista dos usuários - como direitos individuais - quanto do ponto de vista das liberdades econômicas - possibilidade de as empresas usufruírem das liberdades econômicas previstas constitucionalmente para

estabelecerem seus negócios de maneira legal. A terceira é a cooperação entre esses diversos agentes. Fora dessas condições, não há possibilidade de desenvolvimento da economia digital. Mais do que isso, o que a gente está tentando reforçar aqui é que é condição para o desenvolvimento econômico um ambiente de previsibilidade institucional, legalidade e segurança jurídica.

O caso em questão parece dizer respeito exatamente a essa discussão. O que está em jogo aqui não é, ao contrário do que ouvimos em outras manifestações, apenas uma discussão de soberania. Existe uma discussão entre duas soberanias que podem reivindicar isso de maneira legítima. Existem discussões aqui que perpassam direitos fundamentais dos usuários de internet. Existe uma discussão sobre a efetividade da prestação jurisdicional, não somente do ponto de vista da celeridade, mas também do ponto de vista das garantias processuais, porque, afinal de contas, se a prova não é uma prova produzida licitamente, ela não é uma prova legal. Finalmente, há uma discussão aqui relacionada às liberdades econômicas.

O devido processo legal é ferramenta de mediação desses aspectos. A gente precisa ressaltar isto: o MLAT como devido processo legal nessa circunstância, com os defeitos e virtudes que eventualmente o processo tenha. A noção de justiça procedimental aqui é importante. Essa é uma noção filosófica que a gente pode recuperar de John Rawls, e trabalhar sob a

perspectiva de que a justiça procedimental tem a ver com o fato de que, nas deliberações, para que sejam justas, também importa o meio pelo qual essa deliberação é produzida.

Temos uma noção muito forte de justiça substantiva, mas justiça procedimental é importante. Para nós, o centro deste caso tem a ver com duas perspectivas relacionadas a isso: uma noção de *rule of law*, noção forte de império da lei, e uma noção de *rule by law*, noção mitigada de império da lei, em que, na verdade, respeita-se a forma procedimental da lei apenas como instrumento de conveniência da autoridade. Essa é uma distinção bastante importante na visão da Câmara-e.net.

A gente vai falar de três elementos desse desdobramento da justiça procedimental. A primeira é que o devido processo legal não é opção da autoridade. A gente ouve muito aqui a discussão sobre meios alternativos de cooperação. Há meios alternativos? Eles estão previstos em lei? Como a gente ressaltou, a discussão sobre a conveniência da investigação não é o único elemento presente nessa discussão. Temos outras considerações e não há nada que legitime a prioridade da persecução criminal *versus* os outros interesses envolvidos. Em uma noção forte de *rule of law*, a autoridade se submete à lei, não apenas utiliza a lei de maneira instrumental. Essa parece ser questão fundamental aqui, pois em muitos casos as autoridades se utilizam da forma

legal de maneira exclusivamente baseada na conveniência. Em um Estado de Direito, a maneira como as coisas são feitas importa.

Na segunda questão, para voltar ao já surrado artigo 11 do Marco Civil da Internet, quero falar sobre a interpretação teleológica desse artigo, porque a seção é denominada "Da Proteção dos Dados Pessoais e das Comunicações Eletrônicas dos Usuários". A proteção e a razão pela qual esse dispositivo foi inserido foi fazer a lei brasileira ser aplicável à proteção dos direitos de privacidade dos usuários de internet. É estranho a gente ouvir as autoridades dizendo que este artigo, que foi feito ou desenhado para proteção de direitos, seja utilizado como base para a quebra de sigilo. Se existe uma conexão com o caso Snowden - e, evidentemente, do ponto de vista político, existe -, a questão de fazer a lei brasileira aplicável era justamente um comando para evitar que outras nações e outros países violassem direitos através de quebra de sigilo ilegal e não o contrário. A interpretação que tem sido feita do artigo 11 é contrária a seu objetivo primordial.

A segunda questão, também já levantada por outros colegas, é que o artigo 11 não trata de questões procedimentais. Não há uma única menção sobre a questão procedimental envolvida. Estamos falando exclusivamente da aplicação da lei brasileira. O procedimento segue o disposto na lei brasileira, que, mais uma vez, inclui o MLAT. A melhor interpretação do

artigo 11 do Marco Civil é a que celebra a aplicação da lei brasileira por um lado, sem ignorar a realização disso através do devido processo legal - instrumento de mediação dos vários interesses aqui envolvidos.

Finalmente, para terminar, a noção de que solução unilateral e a aplicação de medidas coercitivas viola o senso de justiça de procedimento e, portanto, de império da lei. A gente recai nas consequências indesejadas que acabam por violar a noção de equidade trazida pelo processo. Quais são as consequências indesejadas aqui? Você tem, do ponto de vista econômico, aumento das incertezas e, portanto, do ponto de vista dos agentes privados, custos, ausência de previsibilidade e, logicamente, revisão de investimentos e negócios no País.

Uma segunda questão importante é a proliferação de procedimentos não institucionalizados. É óbvio que os agentes privados vão tentar evitar as sanções impostas, seja no Brasil, seja fora. Isso incentiva a produção de procedimentos *ad hoc* que dificultam a transparência, o monitoramento e o controle social da quebra de sigilo de dados. Estamos, na verdade, entrando em um círculo vicioso aqui. Através disso, também tem uma afetação da solução desejável, que seria a cooperação internacional. Se posso resolver isso, do meu lado, exclusivamente, para que cooperar com outros governos ou com outros agentes envolvidos?

Finalmente, existe uma afetação negativa da qualidade da prestação jurisdicional, porque a ótica da celeridade não é exclusiva no que diz respeito à qualidade da prestação jurisdicional. Temos o fato de que, no Estado de Direito, a prova produzida precisa estar salvaguardada pelas disciplinas e garantias do devido processo legal - na lógica da justiça procedimental, porque, do contrário, estamos falando de prova ilícita. A prova produzida com vício na origem é, depois, questionada no processo, pelo fato de não ter sido produzida de acordo com o devido processo legal.

Apenas para concluir, na visão da Câmara-e.net, existe a necessidade de se ressaltar o processo de MLAT como processo que respeita o *rule of law* e que, portanto, ajuda na estabilidade institucional do País, favorece os negócios e o crescimento econômico.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Agora, ouviremos o doutor Marcelo Carpenter.

O SENHOR MARCELO CARPENTER (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO) - Boa tarde a todos, Senhor Presidente, Ministro Gilmar Mendes, caros colegas aqui presentes.

Parece-me, ouvindo atentamente todas as exposições, desde a manhã e agora à tarde, Ministro, que essa audiência é muito enriquecedora e tem, de fato, trazido elementos importantes para o debate; mas chama a atenção um ponto que parece comum aqui: não há elemento constitucional em disputa. Não há aqui nenhuma disputa constitucional. Isso inclusive chegou a ser objeto de um comentário do Ministro Ayres Britto, que reclamou da falta de menção a determinado dispositivo constitucional.

E é curioso notar que, ao longo de todo o dia de hoje, talvez tenhamos ouvido uma ou duas vezes qualquer referência genérica que seja a um dispositivo constitucional, claro, afora princípios de devido processo, que estão previstos na nossa Constituição; mas não há disposição constitucional, não há debate constitucional, a nosso ver, que justifique a apresentação da ação direta.

Há um debate relevante, sem dúvida, há um debate muito importante sobre as consequências das decisões judiciais brasileiras para empresas que prestam serviços no país e que têm controladores estrangeiros, mas esse é um debate exclusivamente infraconstitucional.

Os autores da ação, de forma inteligente e hábil, como caracteriza a atuação deles, referem-se a uma violação indireta, a um perpasse da Constituição por deixar de aplicar normas processuais quando elas

deveriam incidir, notadamente as normas do tratado e as normas da carta rogatória. Mas a falta de aplicação de normas infraconstitucionais é um debate no cotidiano do Superior Tribunal de Justiça. Diariamente, o que se discute em recurso especial é exatamente a não aplicação de normas legais, infraconstitucionais.

É preciso lembrar aqui a sempre curiosa citação do Ministro Aliomar Baleeiro, que dizia: salvo casos especialíssimos de direito intertemporal ou de loucura furiosa, nenhum juiz diz que deixa de aplicar a lei conscientemente. Por isso, entende-se por violada a lei quando aplicada uma lei quando ela não deveria incidir ou quando deixada de aplicar quando ela deveria incidir. É esta a discussão que se está tendo aqui: deve incidir o tratado necessariamente em todos os casos? E todos os casos trazidos na inicial dizem respeito à hipótese em que os autores entendem que deveria ter sido aplicada uma lei federal, quando, na verdade, foi aplicada uma outra lei, uma lei processual.

De modo que não me parece, caros colegas e eminentes Ministros - e trago a título de colaboração - que haja aqui um debate constitucional. O que há é o debate sobre aplicação de leis federais, quando elas devem ou não devem fazer incidir no ordenamento jurídico brasileiro.

Eu receio que o acolhimento dessa medida possa desaguar em uma avalanche de ações declaratórias de constitucionalidade no Suprem Tribunal Federal, porque, nesse momento, há um sem número de questões sendo discutidas no Superior Tribunal de Justiça sobre aplicação de leis federais. Toda vez que houver um debate sobre se aquela lei foi bem aplicada naquele caso, será cabível uma ação declaratória de constitucionalidade para o Supremo decidir? Porque sempre haverá, especialmente em questões processuais, princípios constitucionais que estão subjacentes a essa aplicação, como o devido processo legal.

De modo que, o que me parece - e aí avançando um pouco para discussão mais meritória, se me permite - é que, o que se discute aqui, acho que ficou bem claro, é que empresas de prestação de serviço optaram por constituir uma estrutura em que seus controladores são estrangeiros e optaram por constituir uma estrutura em que seus dados são armazenados no exterior. Muito bem, que dados são esses? Dados de serviços praticados, conversas realizadas no Brasil, entre brasileiros, e, em alguns casos, relativos a crimes praticados no território brasileiro.

Essas informações podem ficar a salvo da autoridade brasileira? Parece que não ficam, segundo pôde explicar aqui o meu antecessor

da FIESP. Nos Estados Unidos, parece que não é essa a regra, ainda que estejam situadas em outros territórios.

As decisões das cortes americanas podem exigir a apresentação dessa documentação, se eu entendi corretamente, ainda que o armazenamento não esteja nos Estados Unidos, esteja em outros lugares. Parece-me que essa é a discussão que se trava aqui.

Fala-se muito de violação ao devido processo legal, mas em nenhum desses casos trazidos a paradigma foi uma medida de violência, de força. Foram todas medidas deferidas no âmbito de processos judiciais, sob o crivo do contraditório, com juízes selecionados pelo critério do juiz natural, com o contraditório, advogados devidamente representados, recursos interpostos. Não parece ter havido violação do devido processo legal. O que parece haver é uma tentativa de exigir necessariamente um único meio de obtenção de prova quando envolver prestadores de serviços.

É preciso reconhecer e louvar o esforço e o compromisso das empresas estrangeiras aqui representadas em colaborar com as autoridades brasileiras, em colaborar com a obtenção dos dados, em colaborar com a prevenção das atividades criminosas, mas sempre sob o critério da lei estrangeira e das decisões judiciais estrangeiras.

Disse-se aqui: não temos problema em fornecer metadados, sempre fornecemos com muita velocidade e com muita frequência às autoridades brasileiras. Porque isso é autorizado pela lei estrangeira, porque isso é autorizado pelas cortes estrangeiras. Se não fosse, não haveria.

Estamos aqui discutindo com um país de admirável democracia. Por acaso, as empresas aqui representadas são empresas cujos controladores estão nos Estados Unidos, país em que temos muito a aprender em termos de regras processuais, de respeito à democracia e aos direitos humanos, mas poderia não ser. Poderiam ser países outros cujos valores não sejam compatíveis com os nossos.

E se os dados estiverem armazenados nesses outros países? E se esses controladores estiverem situados em países que não compartilham dos mesmos valores que os nossos? Nós nos submeteremos a eles? E só aí que nós poderemos pedir?

Veja o descompasso, caros colegas, eminente Ministro, que nós criaremos com empresas brasileiras que prestam esse serviço no Brasil, assim como estrangeiras podem fazer, mas que armazenem os dados aqui. Essas empresas, essas, sim, terão o diferencial competitivo e, talvez, seus usuários prefiram usar outros concorrentes que tenham dados de mais difícil acesso.

Então, é delicada a situação, sem dúvida nenhuma, mas me parece que não há aqui, em primeiro lugar, uma discussão constitucional. O que se discute é a aplicação de uma regra de lei federal. Também não me parece que tem havido, em nenhum desses casos, pelo que foi dito até agora, violação do devido processo legal. Todos eles foram dados por juiz, escolhidos corretamente, respeitado o princípio do juiz natural, observado o contraditório.

E o que me parece aqui, o que se discute é: empresas que decidem se instalar no Brasil e prestar serviços aqui, ainda que por empresas estrangeiras - não há dúvida que são empresas, entidades diferentes, com autonomias diferentes, mas elas decidiram o modelo de negócio quando vieram se estabelecer no Brasil e decidiram armazenar seus dados em outros lugares de serviços prestados no Brasil, inequivocamente -, elas podem recusar esse cumprimento? Será razoável? Será que serão as Cortes estrangeiras que vão determinar quando do acesso? Se tivermos países, por exemplo, que não entendam como crime - e usando aqui, evidentemente, para ilustrar, uma metáfora ou uma hipérbole -, que não entendam como crime a pedofilia, que não entendam como crime o nazismo, será que nós vamos ter que submeter e pedir a eles autorização pra quebra do sigilo? Eles podem negar dizendo: "Não

é crime na minha jurisdição. Os dados estão armazenados aqui, não vou fornecer essa informação."

Não parece razoável essa interpretação, ainda que compreenda o risco econômico, as multas são pesadas e, muitas vezes, injustificáveis, Senhor Ministro, mas essa, devo dizer, no processo civil - eu sei que não estamos aqui tratando de processo civil -, é a realidade de centenas de empresas no Brasil que convivem diariamente com bloqueios *online*, muitas vezes injustificados, por descumprimento de ordens judiciais. Basta uma rápida pesquisa na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e se encontrará uma miríade de acórdãos reduzindo multas aplicadas por juízos em razão de descumprimento de ordens judicias, muitas vezes de caráter milionário, mesmo não se tratando de processos criminais. De modo que, embora respeitando a preocupação, não parece que seja essa uma solução adequada.

Muito obrigado, Senhor Ministro.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Com a palavra agora ao Doutor Pedro Ivo Veloso.

DOUTOR PEDRO IVO VELLOSO (INSTITUTO DE GARANTIAS PENAIS) - Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Senhoras e Senhores, agradeço pelo deferimento da oportunidade de estar

aqui. Represento o Instituto de Garantias Penais, sediado em Brasília, que visa a lutar pelo aperfeiçoamento das garantias penais. Falarei aqui, e bem rapidamente, sob o ângulo das garantias de investigados que podem ser atingidas por essa cooperação, por esse procedimento de obtenção de dados.

Não me vou deter em temas técnicos de cooperação. Não me vou deter também na questão do campo de aplicação do Marco Civil, tampouco do MLAT. Falarei, obviamente, do MLAT, mas, repito, sob o ângulo do devido processo legal - forma pela qual penso que o Instituto de Garantias Penais tem como colaborar com esta colenda Corte.

Da mesma forma que o colega que me antecedeu - que falou brilhantemente -, entendo que, talvez, a questão é mais de campo de aplicação de discussão de um conceito e menos de constitucionalidade. Mas, como o princípio do devido processo legal foi colocado de forma bastante ávida e brilhante na inicial - e foi suscitado agora mesmo por outro colega que me antecedeu -, penso que se deve olhar pelo ângulo dos investigados, o que seria mais incremento para o devido processo legal: o caminho via cooperação, via MLAT, ou o caminho direto, abreviado.

Nesse ponto, penso que a questão não é tão simples, aliás, é muito dura, como todas as discussões aqui têm revelado. Talvez, para as garantias dos investigados, seja muito mais relevante que se tenha discussão

no âmbito da legislação ordinária brasileira. Hoje, há vácuo enorme no que se refere à coleta de dados pelas autoridades investigativas e pelo Poder Judiciário brasileiro. Efetivamente, é vácuo expresso, inclusive, pela própria Lei Geral de Proteção de Dados. Talvez a discussão legislativa traga clareza e mais proteção. Nesse aspecto, é importante registrar que a Câmara dos Deputados instituiu comissão para anteprojeto de regulação da proteção de dados, no âmbito da segurança pública e das investigações e repressão às infrações penais.

Em primeira análise, faria a seguinte pergunta: há mais garantia ao devido processo legal no que se refere aos investigados? Há outro aspecto também: a garantia do processo legal daqueles que representam as empresas. Nesse aspecto, é importante registrar, que há uma ADI - e o Instituto de Garantias Penais defende sua procedência - sobre sanções exageradas no Marco Civil da Internet. Mas aqui falo especificamente dos investigados.

Há respeito maior ao devido processo legal se observarmos o MLAT? Se a gente focar a discussão, em um primeiro momento, nos aspectos formais, como o MLAT, talvez, gere um *plus* de procedimento, uma necessidade, por exemplo, de tradução de documentos e análise por duas jurisdições, a gente indique que sim, que há mais garantia. Haverá, digamos assim, análise mais acurada dos casos do que se não houver o MLAT. Olhando

pelo aspecto prático de alguém que está sendo investigado, talvez seja positivo que haja uma análise de duas jurisdições, uma análise apurada.

Todavia - e é importante deixar bem claro -, muito mais danoso para as garantias é a ausência de marco legal claro para as hipóteses de coleta de dados no âmbito do Processo Penal. Muito mais danoso é o fato de as decisões judiciais citadas aqui estarem sendo feitas com uma miríade de argumentos e fundamentos legais, algumas focadas no Marco Civil da *Internet*, que não prevê expressamente nenhum tipo de extensão. Cabe a cada juiz especificar a proporcionalidade e a razoabilidade da medida. Cabe a cada juiz perceber se, no caso específico, há gravidade a justificar coleta de dado pessoal ou não, diferentemente de outras leis, como a de Interceptação Telefônica, que prevê, por exemplo, que, em casos de crime punido com detenção, não pode haver interceptação telefônica.

O que se nota é que, em atenção ao devido processo legal, talvez o foco maior não seja olhar pelo MLAT ou fora do MLAT. Talvez seja apenas uma questão de campo de aplicação para cada empresa. Mais importante é que haja um tratamento jurisprudencial - enquanto não houver uma lei mais clara - das hipóteses em que deve haver coleta de dados, como ela deve ser feita, a extensão em que deve ser feita e, sobretudo, se ela deve ser

feita em alguns casos - por exemplo, dados íntimos, dados personalíssimos sobre saúde. Nada disso está previsto em nossa legislação.

Também não acho que devemos terceirizar nosso devido processo legal. Se a gente fizer breve leitura do tão falado Cloud Act ou do Stored Communications Act, vai ver muita vagueza, muita exceção. Acho que isso pode até funcionar muito bem no sistema norte-americano, mas, talvez, tenhamos que pensar no nosso sistema, nos nossos valores - como o Colega que me antecedeu aqui falou. Aí, sim, reside, talvez, o principal aspecto a ser tutelado no que se refere ao devido processo legal no âmbito da proteção de dados.

Uma outra questão: esse caminho de internacionalização de cooperação - falando em uma discussão mais ampla, não só do MLAT -, de deixar fluir, com mais facilidade, dados de cidadão brasileiro e vice-versa ou dados de cidadão brasileiro que reside no estrangeiro, inclusive alguém que não seja daqui, necessários para investigação no Brasil, é caminho que gera proteção? Certamente, há de ser feito de forma que gere proteção.

Considerando que uma massa incrível de dados está concentrada em pouquíssimos países e que, portanto, o Brasil acaba sendo cliente de um lado só dessa cooperação, deixo aqui uma pequena provocação: estaria a República Federativa do Brasil cumprindo seu dever de proteger

dados pessoais de seus cidadãos se, a todo momento, buscar dados para investigação e deixar cópia *backup* em Estado estrangeiro - que acaba sendo feita por conta do processo de cooperação? Se, a cada momento de investigação brasileira, deixarmos, em Estado estrangeiro, aqueles mesmos dados, eles já não vão estar mais com uma empresa estrangeira, que tem código de privacidade. Eles vão estar com o Estado estrangeiro. Como meu Colega disse também, pode ser um Estado democrático, que tem princípios que inspiram nossa República, como os Estados Unidos da América, ou pode ser outro Estado.

Penso que esse é tema que deva ser estudado de forma bem detalhada. Com essas indagações, o que o Instituto de Garantias Penais coloca é que, talvez, o devido processo legal tenha sido um pouco apropriado nesta discussão. Pelo ângulo dos investigados, o MLAT talvez não seja o centro disso tudo; pelo ângulo dos investigados, talvez seja muito mais uma questão de legislação.

Com essa provocação, sendo uma audiência pública, não tenho a pretensão de dizer se a ação é procedente ou não.

Termino minha fala e agradeço novamente.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado!

Com a palavra, a Doutora Raquel Lima Saraiva.

DOUTORA RAQUEL LIMA SARAIVA (IP RECIFE) – Boa tarde a todas e todos.

Cumprimento as autoridades aqui presentes na pessoa do Ministro Gilmar Mendes e, em nome do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, o IP.rec, instituição que aqui represento, eu o saúdo pela iniciativa de abrir este espaço para ouvir representantes da sociedade civil interessados e especialistas no tema aqui discutido.

Eu começo minha exposição afirmando que, para os fins aqui pretendidos, é importante lembrar que os dados de comunicação têm proteção constitucional insculpida no art. 5º, inciso XII, que diz que:

> "XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;"

Dessa forma, sendo um direito fundamental do cidadão, a violação das comunicações somente pode ocorrer quando houver indícios de ilegalidade suficientes para demandar uma ordem judicial de quebra de sigilo.

Da mesma forma, a privacidade também é protegida pela Constituição e, embora o eminente Ministro Sérgio Moro tenha dito aqui, de manhã, que esta discussão travada hoje não se refere à privacidade, eu ouso

discordar, com todo o respeito, porque a privacidade é, sim, um dos pontos da discussão ora posta.

O regime jurídico brasileiro a respeito das relações intermediadas pela internet é muito avançado em relação a outros países, considerando a inovação temática trazida pelo Marco Civil da Internet, já muito falado aqui hoje, que se une à Constituição Federal e antevê o que agora é previsto com mais detalhes e maior aprofundamento na recém-aprovada, porém ainda não vigente, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O Brasil atingiu, com isso, um arcabouço legislativo de proteção à privacidade e aos dados pessoais que atende a parâmetros elevados, como, por exemplo, da União Europeia, que estabeleceu níveis consideráveis de proteção de dados aos cidadãos europeus.

Apesar de a LGPD ainda não estar vigente, trago aqui a pontuação de que ela trata da transferência internacional de dados pessoais, autorizando o seu art. 33, inciso III, a transferência para fins de cooperação internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, enfatizando, todavia, que tais casos estejam de acordo com instrumentos de Direito Internacional, como, por exemplo, o MLAT, objeto da discussão aqui apresentada. Nesse caso, o legislador foi muito feliz ao fazer a

ponte entre a transferência internacional de dados e os instrumentos de cooperação internacional já existentes no ordenamento jurídico.

Como ressaltado no início da minha fala, o sigilo de dados de comunicação dos cidadãos constitui direito fundamental, que carece de uma proteção mais rebuscada. Aqui enfatizo que as autoridades de investigação devem ter sempre isso em mente, bem como o princípio da presunção de inocência, também constitucionalmente estabelecido, pois qualquer infração a eles é digna de ser reparada de forma enérgica.

Dessa forma, entendemos que a melhor maneira de requisitar os dados de comunicação privada dos cidadãos brasileiros armazenados no exterior, para fins de investigação criminal, é, sim, via acordo de cooperação internacional para este fim. No caso específico, o MLAT, acordo de assistência judiciária em matéria penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, é a forma específica e vigente, no ordenamento jurídico brasileiro, para tanto.

Referido acordo foi promulgado por meio do Decreto nº 3.810/2001, o qual nunca foi objeto de ação de inconstitucionalidade perante esta Corte. Os tratados internacionais são, como se sabe, recepcionados pela Constituição Federal com *status* de lei federal. Em legislação específica, o

Marco Civil da Internet recepciona e respeita os tratados internacionais, precisamente seu artigo 3º, parágrafo único, que expressa que:

> Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte."
> Então, o decreto do MLAT não só pode como deve ser aplicado.

Ademais, muito se falou, hoje, sobre a possibilidade de fornecimento direto de informações armazenadas no exterior pelas empresas no Brasil, usando como base para tal artigo 11 do Marco Civil da Internet. Mas o dispositivo em questão não autoriza o fornecimento de dados diretamente às autoridades brasileiras, como afirmaram que mais cedo alguns expositores. O artigo 11 apenas afirma que a lei brasileira deve ser cumprida, o que é óbvio, sem estabelecer o procedimento, mas o decreto do MLAT também é uma lei brasileira, constitucional e vigente, ou seja, também deve ser observada, segundo a literalidade do artigo 11 do Marco Civil da Internet.

Entendemos os desafios que tecnologias transfronteiriças trazem às investigações criminais, como aplicações de mensagem ou redes sociais, e por isso mesmo consideramos necessário fortalecer esforços de colaboração entre agências governamentais. Nesse sentido, também é possível notar que a diligência processual, no que diz respeito à requisição e obtenção

de provas, se depara com novos desafios devido à natureza efêmera de certas comunicações estabelecidas via internet. A intermediação de tecnologias que "encriptam" as comunicações também inaugura um cenário delicado ao tornar inacessíveis, por vezes, o conteúdo das mesmas. Entre outros fatores, infelizmente, essa realidade dá ensejo a rotinas ilegítimas por parte de algumas agências de investigação, as quais enfraquecem o devido processo legal por não atuarem em obediência a uma ordem judicial. Assim, sucessivos programas de vigilância das comunicações são noticiados pelos meios de comunicação. Dito isso, frisamos a central necessidade de intermediação e acompanhamento do juízo legítimo no requerimento e consequente colaboração proporcionada pelo MLAT, a fim de não restar brechas à violação da privacidade dos cidadãos sem que haja estrita base legal.

Porém, ainda que o acordo bilateral do MLAT tenha surgido para sanar conflitos processuais sobre a requisição de dados localizados além das fronteiras nacionais para fins de investigação criminal, é importante destacar que o conteúdo de comunicações protegidas por criptografia forte encontra barreiras técnicas que vão além da boa-fé colaborativa entre empresas de tecnologia e agências do Estado. Apesar da defesa da constitucionalidade do instrumento aqui sustentada, é necessário pontuar que o MLAT não sana impossibilidades técnicas que empresas de tecnologias enfrentam no acesso às

comunicações de seus usuários. Seja no Brasil ou nos Estados Unidos, a situação permanece a mesma, pois a tecnologia não varia de acordo com o local onde é construída. Sua arquitetura é universal, pois baseada em critérios científicos de construção. A questão foi largamente desenvolvida por especialistas em Audiência Pública promovida por esta Corte, a qual procurou esclarecer conflitos no âmbito da ADIN nº 5.527 e da ADPF nº 403.

E aqui, já me encaminhando para o final da minha fala, sabemos que dados sobre a negativa de pedidos via MLAT realizados pelas autoridades brasileiras às autoridades estadunidenses demonstram a falta de indícios para embasar as investigações, segundo o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça. Os números apresentados pela manhã pelo DRCI demonstram que a ferramenta na verdade não está sendo bem utilizada. A lei dos EUA exige que, para violar o direito constitucional do sigilo das comunicações, é necessário demonstrar o nexo causal entre o fato investigado e a necessidade de afastamento do sigilo. Segundo o Ministério da Justiça, 32% das negativas de cooperação são por falta de demonstração da necessidade da quebra de sigilo telemático. Esse é o cuidado que temos que ter também aqui, a demonstração da necessidade tem que ser cabal.

Do ponto de vista da sociedade civil, cadeira que ora ocupamos, resta-nos concluir, a partir dessas explanações do Ministério da Justiça, que as autoridades brasileiras almejam a quebra do sigilo das comunicações para verificar a ocorrência de um fato, quando ainda não têm provas, e não utilizar o que lá está como evidência de um acontecimento prévio. Mais uma vez enfatizamos aqui a necessidade de se observar o princípio da presunção de inocência, e, também, que a quebra do sigilo das comunicações só deve ser autorizada quando houver indícios suficientes de prática de ato ilícito e de que as referidas comunicações dizem respeito ao ato criminoso investigado. Em hipótese alguma deve acontecer fora dessa lógica, sob pena de infração ao devido processo legal e a outros direitos constitucionalmente assegurados.

Assim, é possível afirmar que, respeitado o devido processo legal e o direito à privacidade, que o MLAT e os acordos de cooperação internacional em geral devem ser considerados os mais benéficos instrumentos para o caso de requisição de informações e dados necessários a investigações. Pelo mesmo motivo, não se pode questionar a eficácia das requisições de dados via MLAT, considerando que as negativas aconteceram, sobretudo, pela ausência das informações necessárias.

Com isso, concluo minha fala e novamente agradeço o espaço e a iniciativa do Ministro Gilmar Mendes.

Obrigada.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Com a palavra agora Doutor Maurício Tamer.

O SENHOR MAURÍCIO TAMER (SOCIEDADE DE USUÁRIOS DE TECNOLOGIA) - Boa tarde a todos e todas! Cumprimento a Colenda Corte em nome do eminente Ministro, cumprimento toda a mesa.

E me parece que a gente tem algumas premissas a serem colocadas. Primeiro, eu queria dizer e destacar que eu estou em nome da Sucesu -Sociedade dos Usuários de Tecnologia, e agradeço a admissão de *amicus curiae*, aqui, neste processo, para que a gente pudesse contribuir, de alguma forma, com aquilo que a gente acredita que é melhor no debate.

Vir antes, numa audiência como essa, é sempre prazeroso, é sempre mais espaço de fala; vir, depois, tem também prejuízo, mas também tem o benefício de reunir tanta fala e tantas colocações muito bem-feitas que possam trazer um debate plural. E, neste momento, eu reúno algumas premissas neste sentido.

Primeiro, parece-me muito claro - eu vou em aderência a algumas falas já, de hoje -, que não há um debate constitucional propriamente

dito aqui nesta ação. Parece-me que a ofensa seria meramente reflexa na ideia de tentar levar a debate disputas em legislações federais, quais seriam e quais não seriam aplicáveis. E, aqui, eu faço menção à ideia da força dos próprios tratados no ordenamento brasileiro.

Não há, em relação ao MLAT e a nenhum outro tratado dessa natureza alguma colocação de direitos humanos a elevá-los em grau tal como emenda constitucional, ou mesmo na interpretação bem dada, no caso do Pacto São José da Costa Rica, por este Supremo Tribunal Federal, em relação ao estado de supralegalidade. Então, nós não falamos, neste momento, de superioridade jurídica. Então estamos colocando, de fato, uma disputa entre legislações federais.

Em que pese, no nosso entender, a questão processual surgir como impeditivo de análise da própria questão, não me parece que seja oportuno a gente renegar o debate; não me parece que seja oportuno a gente não aproveitar esse momento que o Supremo Tribunal Federal - e elogio, mais uma vez - faz a colocação e promove essa audiência nesse sentido, levar esta questão à debate público, isso é uma questão absolutamente fundamental.

Primeiro, parece-me muito claro que existe um cenário lúcido de inefetividade do MLAT. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são as autoridades que levantaram essas informações até aqui. Também me parece

muito claro e, não só do fornecimento de MLAT, mas qualquer advogado que milita ou que atue diariamente sabe o quanto é difícil ou quanto tempo ou quanta morosidade prejudicam a obtenção de informações por cartas rogatórias.

Há um devido processo legal, mas também há devido processo legal com relação aos outros procedimentos. Não é uma violação ao devido processo legal a não utilização do MLAT ou a não utilização dos procedimentos de carta rogatória; eles convivem harmonicamente.

Lembramos que o devido processo legal, por certo, é o antídoto histórico e relacionado à própria atuação do Estado na prestação jurisdicional, assim como lembramos da função jurisdicional que aqui estamos agora a dizer a respeito.

Também é importante dizer que, de todo modo, é preciso que nós estabeleçamos a segurança jurídica àquilo que vai ser definido. A segurança jurídica é absolutamente fundamental, aqui é um ponto muito sensível e vários colegas falaram sobre isso.

O pior dos cenários é, na nossa opinião, a existência de exceções, exceções que vão justificar ou não a utilização de um procedimento ou outro. Ou você utiliza os vários procedimentos dessa posição - que é a nossa opinião, pela não é exclusividade da utilização do MLAT -, ou efetivamente

você utiliza um só. Condicionar o conteúdo das informações a serem obtidas, condicionar a natureza da fiscalização ou do procedimento penal, condicionar efetivamente aonde está, efetivamente não é o melhor dos caminhos.

Hoje se fala na discussão de MLAT, países, como bem o colega colocou recentemente, em que isso não vai ser possível, países em que a democracia não vai ser estabelecida. Como fica a soberania brasileira? Apenas não vai investigar, apenas não vai ser exercida, vai abrir mão de estruturas procedimentais de mais de 200 anos pelo simples fato de que o outro país não estabeleceu um procedimento? Precisamos pensar sobre isso.

Também parece de consenso, e hoje o debate é muito claro nesse sentido, de que precisamos evoluir muito todos esses mecanismos. Precisamos, sim. Precisamos sentar com os Estados Unidos; sentar e debater, como estamos fazendo hoje; evoluir ainda mais em sentido. Multiterritorialidade, infraestrutura global, todas as questões são claras. Todos nós sabemos que o desafio da competência e da jurisdição relacionadas à internet existe e não parece que tão cedo vai ser sanado. O problema é que não podemos ficar, enquanto não há essa sanação do problema, parados e aguardando efetivamente. São mecanismos que claramente se mostraram não efetivos. A tentativa foi válida. Ele está aí, ele pode ser utilizado. A questão não é que ele não possa ser utilizado, mas ele precisa ser utilizado desde que efetivo

seja. Talvez, uma circunstância própria de ser utilizada seja você trazê-lo previamente antes de uma outra medida. É questão de se pensar.

Segundo ponto. Acho prematuro - e foi falado em alguns momentos - falar-se em arbitrariedade. Acho prematuro se falar em arbitrariedade em relação à utilização de outros mecanismos que não o MLAT e que não as cartas rogatórias. A arbitrariedade seria exatamente a não existência de um mecanismo legal adotado. Não me parece que seja o caso também. E, aí, nós precisamos lembrar de por que a função jurisdicional existe. E hoje é colocada aqui - e já avançamos por barreiras processuais, as quais, ao nosso ver, impediriam a análise da questão, mas que nos permite conversar a respeito. Por que a função jurisdicional existe? Qual é a grande garantia constitucional? Então, se vamos levar a Constituição ao debate, vamos pensar na inafastabilidade da jurisdição. E se a gente pensar no Professor Humberto Ávila, o conteúdo da inafastabilidade, a promoção de um estado ideal das coisas, em que tem uma jurisdição que preste, com a efetividade e adequação, ao próprio direito material. Não me parece que ceifar o poder jurisdicional pela exclusividade e utilização da MLAT sirva de instrumento adequado à garantia e à constitucionalidade disso. Também me parece que falecem os princípios da isonomia e da livre concorrência em assegurar que determinados provedores, só por circunstâncias próprias de estarem em país diferente,

possam ter mecanismos de fornecimento de informações diferenciadas dos que têm os próprios provedores brasileiros. Claramente, foi falado aqui também, há vantagens competitivas criadas indiretamente em razão dessas disposições. Esse é um cuidado que tem de se ter também nesse sentido.

Precisamos pensar também no alcance dessa decisão. O quão essa decisão vai poder alterar o dia a dia, alterar os processos. Falar-se-á em precedentes? Sim. Falaremos na criação de um precedente importante. Quais as consequências que teremos, no dia a dia, em relação a isso? Falaremos de um ponto específico, e um colega referiu e faz muito sentido, da própria jurisdicidade da prova. O que acontecerá com essas provas já obtidas sem respeitar um ou outro procedimento? É preciso que o Tribunal pense, em caso de avanço, na minha humilde opinião, também na modulação dos efeitos em relação à decisão que seja colocada.

Por fim, e aqui encerro a minha fala, agradeço novamente a oportunidade. Eu queria encerrar com uma frase do professor Arruda Alvim, já na década de 70, em seu Tratado do Processo Civil, em que ele diz que a ausência de acesso à jurisdição representa a ausência de uma ordem jurídica vigente atuante. É disso que se trata. Não se trata de escolher um procedimento, é preciso pensar, é preciso evoluir, é preciso entender tudo que está em jogo nesse sentido, e a audiência pública serve exatamente para isso. O

que não se pode é estabelecer uma exclusividade, a qual nem na Constituição Federal nem na lei existe, para ceifar outros procedimentos igualmente efetivos e adequados.

Com isso encerro a minha fala.

Obrigado a todos e boa tarde.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Chamo agora os últimos expositores, Doutores Gabriel Araújo Souto, Doutora Alexandra Lopes e Doutor José Renato Laranjeira Pereira, que dividirão o tempo de quinze minutos.

O SENHOR GABRIEL ARAÚJO SOUTO (LABORATÓRIO DE PESQUISA EM DIREITO PRIVADO E INTERNET - LAPIN/UNB) - Excelentíssimo Senhor Presidente Ministro Gilmar Mendes e demais presentes aqui na Turma. Meu nome é Gabriel Souto, represento o LAPIN, *think tank* criado, na Universidade Brasília, para estudo de regulação em tecnologia.

Dividirei meu discurso em dois pontos. O principal bloco é a relação entre segurança pública e privacidade, e o segundo é a jurisprudência sobre privacidade e requisição de dados no exterior e como esse assunto vem sendo decidido internacionalmente e em território nacional.

Senhor Presidente, como se sabe, ter concepção sobre privacidade de dados e consequentemente realizar julgamento a partir dela é fator que não é simples, pois o conceito de privacidade é consequentemente mudado. Inicialmente, tratamos privacidade como ponderação entre interesse público e interesse privado. Posto esse dilema, a autora canadense Helen Nissenbaum cunhou o conceito de teoria da privacidade contextual. De acordo com essa doutrina, as normas que regulamentam as trocas de informação somente farão sentido caso analisadas conjuntamente, ou seja, de forma holística, levando em conta a situação cultural e as normas vigentes.

Por outro lado, Daniel Solove defende a teoria da privacidade contextual associada à expectativa razoável de privacidade, ou seja, seria necessário considerar dois pontos: o objetivo - o que sociedade estaria disposta a reconhecer como expectativa individual razoável - e o subjetivo - onde se leva em consideração as expectativas de privacidade do indivíduo vigiado. Esse entendimento, Senhores, foi aplicado no caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, *United States v. Katz*, e, posteriormente, foi aprimorado em *United States v. Jones*. Concluindo esse primeiro bloco, o maior instrumento para que se evite uma erosão plena da privacidade dos cidadãos é o devido processo legal.

No segundo bloco, em que se fala sobre jurisprudência, a questão que envolve todo esse bloco é a seguinte: podem autoridades brasileiras exercer jurisdição sobre dados coletados em território brasileiro por empresas estrangeiras? No presente caso pátrio, temos que a Google do Brasil, no Inquérito 784, afirmou que os dados estariam em sede estrangeira e que, portanto, não teriam localmente acesso, assim deveríamos usar o MLAT. Pela via recursal, o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que afirmou que essa recusa violaria frontalmente a soberania nacional e que, portanto, os dados deveriam ser acessados e obtidos no Brasil. Assim, determinou-se, nesse caso, que a jurisdição sobre o dado se define pelo local de coleta e nacionalidade do titular e não somente pelo local de armazenamento. Em situação semelhante, Senhor Presidente, temos, na Suprema Corte, caso da Microsoft. Nesse caso, os dados seriam coletados pela Microsoft nos Estados Unidos, mas a base de dados estaria armazenada na Irlanda. Decidiu-se que a obtenção desses dados não faz com que mandado de busca emitido por autoridades tenha reflexos extraterritoriais, uma vez que os dados poderão ser acessados a partir do território norte-americano. Temos, nesse caso, claro respeito à soberania norte-americana e questiono: não deveríamos ter o mesmo respeito com a nossa própria soberania?

Desses litígios foram extraídos quatro critérios. O primeiro é o critério de coleta: a jurisdição, nesse caso, seria definida pelo local em que houve a coleta de dados. O segundo seria o critério pessoal, em que a jurisdição é definida pelo local de residência do titular dos dados, que teria acesso a todo o ecossistema da empresa. O terceiro seria o critério do local de acesso, onde a jurisdição é definida pelo local em que haverá o acesso e, consequentemente, a quebra de sigilo de dados pelas autoridades. Por fim, o quarto, o critério de localidade de armazenamento de dados, onde os dados estariam armazenados em um local e exigiria a aplicação do MLAT. Esse seria caso em que a gente teria aplicação de MLAT.

Tendo isso em vista, o Lapin observa que esses critérios são insuficientes para abarcar a complexidade do tema de privacidade de dados eletrônicos e, portanto, defende que devem ser revisados e adaptados a fim de que os conceitos de soberania e extraterritorialidade tenham interpretação moderna, para que a modernidade do conceito de privacidade possa ser atendida e aplicada ao presente caso.

Agradeço mais uma vez a oportunidade e passo ao meu colega José Renato.

DOUTOR JOSÉ RENATO LARANJEIRA DE PEREIRA (LABORATÓRIO DE PESQUISA EM DIREITO PRIVADO E INTERNET - LAPIN/UNB) - Boa tarde, Excelentíssimo Ministro! Boa tarde a todos!

Meu colega acabou de delinear os critérios que têm sido usados tanto por julgadores brasileiros quanto norte-americanos para territorialização de dados em diferentes jurisdições. No entanto, lanço uma questão: dados são de fato territoriais?

A autora Jennifer Daskal relembra quatro características inatas a dados eletrônicos. Seriam elas: em primeiro lugar, sua intangibilidade; serem multiplicáveis, ou seja, um dado pode ser replicado e, então, armazenado em dois pontos diferentes; em terceiro lugar, sua divisibilidade, ou seja, consigo separar um conteúdo de um metadado e armazená-los em locais diferentes; e, por fim, a facilidade de mobilidade - consigo transferir dados de um ponto a outro quase que simultaneamente.

A conclusão a que se chega é de que o esforço em responder a um fenômeno novo utilizando imagens do passado confunde a aplicação do MLAT a dados eletrônicos. Nesse sentido, precisamos de novo paradigma, que saia desse tipo de critério de territorialização física, para pensar dados de uma nova maneira. No entanto, por mais ineficiente e defasado, consideramos que o MLAT é atualmente o único mecanismo pelo qual a requisição internacional

de dados passa por procedimento - como vários já ressaltaram - de devido processo legal e é necessário, sob o paradigma em que estamos, para garantir a proteção de direitos, como proteção de dados e privacidade.

Meramente ignorar o MLAT pode também - como alguns já falaram - gerar conflitos de jurisdições. Caso o Brasil ignore tratado que firmou com os Estados Unidos, este também se veria na possibilidade de ignorá-lo - e assim também o fariam várias outras jurisdições -, o que faria com que a normatização internacional sobre transferências se tornasse uma colcha de retalhos. Seriam criadas também consequências jurídicas para as empresas: qual lei seguir? Isso poderia dar margem a fenômeno que muitas pessoas chamam de "balcanização na internet": a criação de barreiras para o fluxo internacional de dados - transformando a internet em fenômeno meramente local, reservado a determinadas regiões geográficas, perdendo toda a globalização que a faz tão especial e que permite a troca de informações de bens e valores como hoje acontece.

Nesse sentido, chegamos à conclusão de que MLATs, de fato, são insuficientes, mas ignorá-los pode também não fazer sentido. Por conta disso é que o Lapin pensou em algumas recomendações e traçou alguns parâmetros que podem ajudar a preencher essas lacunas. Minha colega Alexandra vai falar agora sobre elas.

Muito obrigado!

A SENHORA ALEXANDRA LOPES (LABORATÓRIO DE PESQUISA EM DIREITO PRIVADO E INTERNET) - Boa tarde a todas e todos!

Falarei dos parâmetros para requisição de dados em contexto transnacional.

Como dito hoje diversas vezes, o Marco Civil da Internet estabelece a necessidade de aplicação da legislação brasileira nos casos de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registro de dados ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicação de internet, desde que ofereçam serviços a consumidores brasileiros ou haja pelo menos um integrante do grupo econômico com sede no Brasil. Nosso Código de Processo Penal estabelece o cumprimento dos princípios de adequação, necessidade e proporcionalidade ao ordenar a produção de provas.

No contexto da legislação europeia, para que o princípio da necessidade seja cumprido, faz-se presente avaliação de necessidade da interferência do poder público sobre a autonomia privada, cujo grau deve ser avaliado em relação a quão necessária é essa interferência para lograr ou alcançar determinado objetivo. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos interpreta que necessidade estrita significa que garantias adequadas e eficazes contra abusos devem existir. Quanto ao princípio da proporcionalidade, este

deve refletir duas nuances. A primeira nuance da proporcionalidade é a do princípio da subsidiariedade, o qual reflete a utilização do instrumento menos invasivo. E a segunda nuance se refere à aplicação da última *ratio*, pela qual os outros meios disponíveis para investigação criminal devem ser exaustivamente testados antes que se recorra à obtenção de dados em contexto privado.

Apesar de não conter expressamente menção ao princípio da proporcionalidade na Convenção Europeia de Direitos Humanos, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos já reconhece que esse princípio deve ser aplicado na interpretação de casos sob vigilância estatal. Para a correta aplicação do princípio da proporcionalidade, as Cortes europeias estabeleceram mecanismos de salvaguarda legal para casos de interferência no direito à privacidade em contexto de vigilância, de forma a garantir equilíbrio necessário entre o interesse legítimo de autoridades de investigação e o direito à privacidade. Salvaguardas estas como o *oversight,* que se traduz na existência de um regime adequado de supervisão. Essa supervisão pode ser judicial ou extrajudicial - em alguns casos, mais dinâmica e célere.

No Brasil, essa supervisão extrajudicial se daria através da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, criada pelo artigo 55-A da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso leva o Lapin a ressaltar novamente a

necessidade da criação de uma autoridade técnica, administrativa e financeiramente independente.

Para concluir, humildemente o Lapin apresenta quatro recomendações a esta Corte no julgamento da ADC 51.

A primeira é a aplicação do MLAT na ausência de instrumento mais específico e, portanto, mais adequado.

A segunda é a aplicação dos princípios e direitos da LGPB, que, embora não se apliquem a contexto de segurança pública, devem balizar qualquer decisão relativa ao acesso a dados pessoais, enquanto não for criada legislação específica.

A terceira é a sugestão ao Congresso Nacional de adoção de legislação adequada ao contexto de tratamento internacional de dados pessoais na segurança pública.

E a quarta, a consideração do princípio da dignidade humana em conjunto com a necessidade e a proporcionalidade, sempre que analisados os direitos de privacidade e proteção de dados pessoais.

Por fim, agradecemos a oportunidade de contribuir mais uma vez com esta Corte e esperamos participar de debates futuros.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Obrigado!

Bem, estamos chegando ao fim da audiência, mas eu tenho algumas considerações que dirigiria aos representantes do setor privado.

Primeira questão, inicialmente se falou na possibilidade de fragmentação do conteúdo de dados e mensagens. Então, eu perguntaria se, com base nas exposições realizadas, especialmente a representante da GV, também a representante americana, considerando a possibilidade técnica de fragmentação do conteúdo de dados e mensagens e com base nas exposições realizadas, perguntaria se já houve caso similar e se a única opção jurídica seria, nesse caso, a hipótese de uma solicitação multilateral?

A SENHORA ANDREA KIRKPATRICK - Agradeço, Meritíssimo, a pergunta, espero ter entendido corretamente. Se não for o caso, a gente vai responder a correta. Peço que assim me informe.

Entendo que sua pergunta diz respeito a se é possível, quando produzimos dados para as autoridades de investigação criminal, separar metadados do conteúdo de comunicações, correto?

Sim, tecnicamente é correto e é assim que temos respondido aos pedidos oficiais ou aos funcionários de investigação criminal. Quando nossos funcionários entram nos sistemas para responder a uma requisição, respondemos de modo particularizado. Por exemplo, se o pedido solicitar metadados, poderíamos obter e responder unicamente com metadados. Se o

pedido solicitar apenas conteúdo, poderíamos, sim, extrair apenas o conteúdo efetivamente em resposta a essa requisição.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - (Ininteligível) ressaltaram que determinados dados que não envolvem o conteúdo das comunicações, como metadados e informações sobre empresas e usuários, podem ser divulgados pelas empresas com relativa facilidade. Isso também ocorreria em situações emergenciais, em que poderia haver comunicação espontânea por parte das empresas. Nessa perspectiva, pergunto aos representantes ou pediria aos representantes que aprofundassem um pouco mais este ponto, esclarecendo em quais situações o MLAT seria, de fato, mecanismo inafastável ao compartilhamento e em que situações ele poderia ser flexibilizado?

DOUTORA ANDREA KIRKPATRICK (FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.) - Agradeço a pergunta, Meritíssimo.

O Direito americano, conforme alguns aqui mencionamos, de modo geral, proíbe a divulgação do conteúdo de comunicações, na ausência de mandado de busca ou de outra exceção à proibição geral de divulgação. Uma dessas exceções é justamente a de emergência. A exceção, em caso de emergência, permite que os provedores, em caso de recebimento de pedido de autoridades de investigação criminal, com base na informação recebida, se há

crença razoável de risco iminente de morte ou lesão, divulguem conteúdo, metadados ou qualquer informação que ele, razoavelmente, creia ser necessário para evitar o risco. Nessas circunstâncias, um MLAT não é necessário ou inafastável. Além disso, o SCA permite que o provedor divulgue informações de metadados a terceiros sem processo legal, muito embora seja necessário obter intimação para atender o governo americano.

No meu entender, podemos oferecer metadados em resposta a ordens judiciais, porque o SCA nos permite fazê-lo sem incorrer em risco de...

(TRECHO SEM TRADUÇÃO)

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) - (inaudível) ...são elementos essenciais dos modelos de negócio explorados pelas grandes empresas de tecnologia. Garantir a privacidade e a segurança, nas comunicações, é, indubitavelmente, um importante ativo que essas empresas detêm. Considerando esse cenário, indaga-se: como as empresas de tecnologia têm buscado adaptar seus termos de uso com a finalidade de reforçar o cumprimento das leis penais? Em que medida o *enforcement* da legislação pode ser robustecido por mecanismos, por exemplo, de autorregulação privada?

O SENHOR ANDRÉ GIACCHETA (YAHOO! BRASIL) - Ministro, obrigado pela pergunta. Falando pela Yahoo Brasil, mas olhando para o mercado como um todo, acho que é uma preocupação cotidiana das empresas procurar estabelecer, nas relações contratuais com seus usuários, que a obediência à lei local - onde o serviço é prestado - seja atendida. A Yahoo Brasil, pelo menos, tem desenvolvido seus negócios com observância, aprimoramento e adaptação de seus termos de uso em observância à lei local.

A autorregulamentação ou autorregulação, como Vossa Excelência sugere, pode trazer parâmetros para que as empresas de tecnologia possam se espelhar, mas entendo que a necessidade é, em primeiro lugar, que a regra legal possa estabelecer o caminho a ser seguido nas solicitações e fornecimento de dados e de conteúdo. Sem dúvida alguma, os termos de uso e a política de privacidade - onde se esclarece, se informa e se estabelece a relação com os usuários - são o ponto de partida para essa finalidade - em observância, sempre, ao regramento local, como o caso que tive oportunidade de expor em relação à empresa que hoje represento nesta audiência pública.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Agradeço a todos os presentes pela participação nesta audiência pública.

No dia de hoje, foram apresentadas diversas questões fáticas e jurídicas relevantes, relativas à constitucionalidade e efetividade do

MLAT, ao surgimento de novas possibilidades de cooperação com a promulgação do CLOUD Act e à necessidade de interpretação sistemática da legislação brasileira sobre o assunto, inclusive sob a perspectiva da Constituição.

A requisição de dados eletrônicos de empresas estrangeiras demanda ajuste fino que possa equacionar questões de legitimidade de atuação dos Estados envolvidos, eficácia de requisições dos Poderes Públicos e observância aos direitos e garantias fundamentais. É ponto de encontro entre o Estado, novos modelos de negócio da economia digital e direitos dos cidadãos à privacidade.

O compromisso do Supremo e desta relatoria é dialogar com os importantes temas pelas partes do processo e amigos da Corte trazidos na data de hoje.

Reitero, a todos, meu agradecimento e declaro encerrada esta audiência pública. Obrigado!

****

Degravação realizada e revisada pelos servidores lotados na Gerência de Transcrição.